
S.a-exin .lines bros נ' S/interlego a 513/89 עא

, פ"ד מח(4) 133

--- סוף עמוד 133 ---

ערעור אזרחי מס' 513/89

S/interlego a

נגד

1.lines bros. S.a-exin.

2.גיא סוכנויות וצעצועים בע"מ

וערעור שכנגד

בבית המשפט העליון בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

[9.6.94]

לפני הנשיא מ' שמגר והשופטים ד' לוי, ד' דורנר

[חוק זכות יוצרים](#), 1911, חא"י כרך ג, (ע) 2633, (א) 2475, סעיפים 1, (1)1, 2, (2)2, (1)5 (א), 7, 22, (1)22, (1)35 (המונחים "יצירה אמנותית", "פיתוחים") - [פקודת הפטנטים והמדגמים](#), חא"י כרך ב, (ע) 1053, (א) 1076, סעיפים 2, 33, 36, 52 (ב) - [תקנות סדר הבין האזרחי](#), תשמ"ד-1984, ק"ת 2220, תקנות 72, 72 (ב) [חוק הפטנטים](#), תשכ"ז-1967, ס"ח 148 - [פקודת זכות יוצרים](#), חא"י כרך א, (ע) 364, (א) 389, סעיפים 4, (4)5 - אמנת ברן להגנת יצירות ספרותיות ואמנותיות, כ"א 21, עמ' 581, סעיף 6א - אמנת פאריס בדבר הגנת הקנין התעשייתי, כ"א 21, עמ' 495 - [חוק החוזים](#) (חלק כללי), תשל"ג-1973, ס"ח 118, סעיפים 12, 39, 61 (ב). המערכת הינה חברה דנית העוסקת בייצור משחקים לילדים. בשנות החמישים החלה המערכת בייצור ובשיווק של לבני משחק עשויות פלסטיק. מ-1969 משווקת המערכת קוביות המתאימות להרכבה בגיל הרך תחת השם "ופלו". בראשית שנות השבעים הגישה המערכת בקשה לרישום מדגמים על קוביות דופלו באנגליה, ונענתה על-ידי רשם הפטנטים האנגלי. המשיבה 1, חברה ספרדית שעוסקת בייצור צעצועים, מייצרת מ-1979 קוביות הרכבה גדולות לפעוטות המכונות, "טנטה אלפנט". לטענת המערכת, קוביות משחק אלה אינן אלא העתקה של קוביות הדופלו,

ולפיכך ייצורן על-ידי המשיבה 1 ושיווקן בישראל על-ידי המשיבה 2 מהווים הפרת זכויות יוצרים של המערערת. משתמה תקופת ההגנה על-פי דיני המדגמים, ביקשה המערערת, בתביעה שהגישה בישראל, לזכות בהגנה של זכות היוצרים, ולצורך כך טענה טענות הפוכות לטענות שטענה לפני רשם הפטנטים האנגלי. בית המשפט המחוזי קבע כי הקוביות ראיות להירשם כמדגם, ועל-כן מוצאות מגדרו של [חוק זכות יוצרים](#), 1911, על-ידי סעיף 22(1) שבו. מכאן הערעור. הערעור שכנגד נסב על הוצאות משפט.

בית המשפט העליון פסק:

א. (1) [חוק זכות יוצרים](#) מכיל בתוכו איזון מיוחד לצורכי יצירות פונקציונליות, שנועד

--- סוף עמוד 134 ---

התמודד עם הקשיים המיוחדים שמציבים מוצרים אלה. איזון זה חשוב, שכן אף שכלל דיני המדגמים מותאמים יותר לטיפול ביצירות פונקציונליות, עדיין קיים סוג של יצירות אשר מן הראוי לתמרץ אתו, אך הוא אינו זוכה להגנה במסגרת דיני המדגמים, ושליה מוחלטת של הגנת חוק זכויות יוצרים מיצירות פונקציונליות, פירושה הסרת ההגנה על יצירות זו (146-ז).

(2) סעיף 22 לחוק אינו שולל את התחולה באופן החלטי מכל מדגם, אלא מוציא סוגי מדגמים מן התחולה של סעיף 22 רישא (147 ב).

(3) אין הצדקה לשלילה אפרורית של הגנת זכות יוצרים ממוצרים פונקציונליים. עם זאת מציבים מוצרים אלו קשיים מיוחדים, שאינם קיימים ביצירות אחרות, ואלו מתבטאים בשניים: חשש שזכות יוצרים על צורה תהווה מונופול על הרעיון העומד מאחורי הביטוי המוגן, וחשש להגבלת יתר של עולם הצורות העתידי. היקף ההגנה שיינתן למוצרים פונקציונליים צריך להתחשב בקשיים מיוחדים אלו, מחד גיסא, וברצון לתת תמריץ ליוצרים פוטנציאליים להמשיך וליצור ביטויים מקוריים, ועל-ידי כך לגוון ולהרחיב את עולם הביטויים הקיים, מאידך גיסא (147 ז-148 א).

(4) תרגום השיקולים העיוניים ללשונו של [חוק זכות יוצרים](#) מגלה כי האיזון הרצוי, המתחשב בקשיים המיוחדים שמעורר מתן הגנה למוצרים פונקציונליים, בא לידי ביטוי בדרישה ל"אמנותיות" (148 ב).

(5) המבחן הראוי לבחינת היותה של יצירה "אמנותית", כמובנה שלדרישה זו [בחוק זכות יוצרים](#), הוא מבחן בן שני חלקים. המבחן מתמקד בכוונת יוצר היצירה, אך הוא גם מביא בחשבון את התוצאה הסופית (148 ב).

(6) יישום המבחן על המקרה דנן מראה כי אין מקום למתן הגנה של זכות יוצרים לקוביות הדופלו, שכן אין הן עומדות בדרישה ל"אמנותיות" (148 ד).

ב. (1) המכנה המשותף לכל היצירות הכלולות בהגדרת "פיתוחים" בסעיף 35(1) [לחוק זכות יוצרים](#) הוא שמדובר ביצירות העושות שימוש, לשם ייצורן, ב"קלישה" או בתבנית. מדובר בתהליך יצירה הכולל העתקה, שיכפול או שיעתוק (150 ד-ה).

(2) בגדר פיתוחים יש לכלול כל שלב בתהליך של פיתוח העושה שימוש בטכניקות שיש בהן תבנית. על-כן ייחשבו כפיתוחים לא רק הלוח המקורי שבו נעשו פעולות החריטה, החיתוך או ההטבעה, אלא גם הדגם שהוא תמונת הראי של התבנית, וגם המוצר הסופי, ובלבד שזה יוצר בשיטה של הטבעה או העתקה מהדגם (150 ו-ז).

(3) שיטה של הזרקה לתבנית אף היא בגדר פיתוח, אלא שבמקום שהדגם יטביע עצמו על מישטח, המישטח (קרי הפלסטיק הנוזלי) מטביע עצמו בתבנית (151 א).

(4) מטרתה של ההגנה על זכות היוצרים האמנותית היא הגנה על הצורה המקורית שהיא פרי עבודתו של היוצר. לשם כך יש להגן על כל גגול שלה בדרך אל המוצר הסופי. אולם אין להרחיב את ההגנה למוצר הסופי רק משום שתהליך הייצור שלו כלל שימוש בתבניות בשלב כלשהו (151 ב-ג).

(5) מטרתם של הדינים בדבר זכויות יוצרים למנוע העתקת יצירות מקוריות. הגנת הדין משתרעת הן על המוצר הסופי והן על שלבים מוקדמים בייצור, אם הביטוי המקורי בא

--- סוף עמוד 135 ---

לידי מימוש גם בהם (151 ג).

(6) שלבי הביניים בייצור שונים מהמוצר הסופי בכך שאין הם מהווים איום על יוצרים אחרים, ואין הם יוצרים סכנה של הגבלת יכולתם של אלו ליצור ביטויים מקוריים נוספים. על-כן יש לנהוג זהירות יתר במתן הגנה תחת סיווג זה למוצרים מוגמרים, ואין להקיש באופן ישיר מהרחבה של קטגוריה החלה על שלבי ביניים, להרחבה החלה על המוצר המוגמר. לא כל שכן כאשר מדובר במוצר פונקציונלי שבו קיימת גם דרישה של אמנותיות (151 ג-ד).

ג. (1) זכות יוצרים, שלא כפטנט, אינה מגינה על הרעיון אלא על הביצוע שלו (152 ג).
(2) לא ניתן, באמצעות זכות יוצרים, להגן על הרעיון של קוביות המתחברות אלו לאלו, אלא רק על הביצוע של הרעיון הבא לידי ביטוי בקוביות הדופלו (152 ג-ד).
(3) שלא כתמונה וכפסל, שה"שימוש" היחיד שנעשה בהם הוא התבוננות בהם, לדופלו יש ג תפקיד פונקציונלי הכרוך בשימוש בו. הוא נועד לשרת מטרה מסוימת, והיא השימוש ככלי משחק (152 ה).

(4) המונח "פונקציונלי" מתייחס לכל שימוש פיזי מעבר להנאה המופקת מעצם הצפייה במוצר (152 ה).

(5) מוצר אשר צורתו מוכתבת אך ורק משיקולים פונקציונליים אינו זכאי להגנה אלא בדיני הפטנטים (153 ג).

(6) אין כל סיבה א-פריוורית לשלול באופן מוחלט מאמן (שבמקרה של מוצר פונקציונלי ייקרא מעצב) את היכולת ליהנות מזכות יוצרים על הצורה של המוצר אך ורק משום שיש למוצר תפקיד פונקציונלי (153 ד).

ד. (1) דיני זכויות יוצרים הם דינים שנועדו ליצור תמריץ לייצורם של טובין ציבוריים, קרי: טובין אשר כוחות השוק כשלעצמם אינם נותנים תמריץ מספק ליצירתם (154 א).

(2) הטובין הציבוריים שאת יצירתם שואפים דיני זכויות יוצרים לקדם הם גיוון עולם הביטויים והעשרתו (154 א).

(3) בנוסף לכך שואפים דיני זכויות יוצרים ליצור איזון בין העידוד שמקנה זכות יוצרים ליוצר העכשווי לבין המגבלה שזו תטיל על יצירת ביטויים מקוריים בעתיד (154 א-ב).

(4) המבחנים הרגילים שנועדו לקדם השגתו של איזון זה הם מבחני היצירתיות והמקוריות (154 ב).

(5) לאור מטרותם של דיני זכויות יוצרי יש להכריע לטובת הגישה הרואה כמבחן המכריע להכרה בזכות יוצרים - את קיומה של יצירתיות, ולא די בעבודה בלבד כדי להעניק ליוצר הגנה על יצירתו (154 ג).

(6) השלב הקובע, שעליו צריך השופט לתת את דעתו, הוא שלב גיבוש הביטוי, ולא השוואה בדיעבד של הביטוי לעומת ביטויים קיימים (154 ג-ד).

(7) אם היצירה מתבססת על ביטוי קודם קיים, ניתן לצאת מההנחה שהאלמנטים הקיימים בביטוי הקיים אינם מקוריים ליוצר של הביטוי המאוחר (154 ד).

(8) כאשר זכות היוצרים אשר בה מבקשים להכיר היא זכות יוצרים בגין אלמנטים ויזואליים, לא תמיד די במבחני העזר האמורים; זאת לאור המספר המצומצם יחסית של אבני בניין

--- סוף עמוד 136 ---

המשתתפות בקביעת אלמנטים ויזואליים. מכאן נוצר קושי בזיהוי יצירה מקורית מחד גיסא, וחשש מיצירת הגבלה רחבה מדי על יצירות עתידיות, מאידך גיסא (154 ה).

(9) מבחן האמנותיות נועד להתמודד עם יצירות המשלבות הן את הקשיים האמורים המתלווים ליצירות ויזואליות, והן את הקשיים העולים בהקשר ליצירות פונקציונליות. ביצירות שבהן צורת המוצר היא פרי שיקולים משני הסוגים, יש להבחין בין סיטואציות שבהן השיקול ה"אמנותי" הוא תכתיב של הפונקציה לבין סיטואציות שבהן הוא בא ידי ביטוי למרות השימוש הפונקציונלי (154 ו).

(10) המבחן הראוי בשאלת הענקתה של הגנת זכות יוצרים לצורתו של מוצר פונקציונלי-תעשייתי מדגיש את כוונת היוצר, אף שיש להקפיד שכוונה זו מקורית ואמנותית כאחת. תי מדגיש את כוונת היוצר, אף שיש להקפיד שכוונה זו - מקורית ואמנותית כאחת - אינה מוכתבת על-ידי התפקיד הפונקציונלי של המוצר. בנוסף על כך, יש לבחון גם את התוצאה המתקבלת בפועל, כדי לוודא שבמתן זכות יוצרים לאלמנטים הצורניים שבהם היא מתבקשת אין משום יצירת מגבלה קשה מדיי על עולם הצורות העתידי (154 ז-155 א).

ה. (1) אם העיצוב הצורני עומד בדרישות וזכאי להגנה של זכות יוצרים, עצם העובדה שנעשה בו שימוש לצורך מוצר פונקציונלי או תעשייתי אינו מונע החלת ההגנה עליו (155 ז-155).

(2) עיגון בדין הישראלי לכך שלא הייתה כוונה לשלול הגנה ממוצרים שמוצרים באופן המוני מצוי בסעיף 5(א) (בחוק זכות יוצרים, המאפשר הגנה על קלישה של יצירה. במקרים רבים, קלישה קשורה למוצרים המיוצרים באופן סדרתי. באותו אופן החוק מגן על תקליטים והקלטות המשווקים כמוצר תעשייתי במספר עותקים רב (155 ז-156 א).

ו. (1) מתן זכות יוצרים פירושו מתן מעין מונופול על משא הזכות. אמנם אין מדובר במונופול מושלם כמו במקרה של פטנט או מדגם, אך במרבית המקרים, בפועל, הכרה בזכות יוצרים מגיעה לתוצאה קרובה מאוד לכך (156 ד).

(2) לאור זאת, קיים חשש שמתן זכות יוצרים על צורה מסוימת עשוי להגביל יצרנים מתחרים ולפגוע קשות בחופש היצירה, והבעיה מחריפה ככל שמדובר בצורה פשוטה ובסיסית יותר (156 ד-ה).

(3) הבעיה חריפה במיוחד כאשר מדובר במוצרים פונקציונליים. ראשית, משום שאלו, בדרך כלל, מוצרים המשווקים באופן המוני, ולכן להגבלה זו תהיה השלכה כלכלית משמעותית יותר, ומכאן שהשאיפה למנוע יצירת מונופול גדולה יותר; שנית, מדובר במוצרים תלת-ממדיים. במוצרים כאלו קשה ליצור הבחנה בין שיקולים פונקציונליים לבין שיקולים אמנותיים באשר לעיצוב המוצר; שלישית, היותו של המוצר פונקציונלי מגביל מראש את הצורות האפשריות, שכן היוצר יכול להביא בחשבון רק צורות היכולות להגשים את המטרה הפונקציונלית (156 ה, ז).

(4) קושי אחר הכרוך במתן זכות יוצרים על צורתו של מוצר פונקציונלי נעוץ לא במושא הזכות אלא במהות המוצרים שבהם היא מוענקת: מוצרים פונקציונליים. החשש הוא שדרך זכות היוצרים על הצורה יקבל בעל הזכות מונופול על הרעיון (156 ז-157 א).

(5) כנגד השגות אלה יש לציין שאין בהענקת מונופול בתחום הקניין הרוחני מעשה שהוא זר למערכת המשפטית, במיוחד בהקשרים שבהם מדובר: רעיונות וצורות (157 א-ב).

--- סוף עמוד 137 ---

(6) הדרישות המופיעות בבחוק הפטנטים, תשכ"ז-1967, כתנאי לקבלת הגנה על פטנט - חדשנות והתקדמות טכנולוגית - לא קיימות בבחוק זכות יוצרים, ועל-כן שימוש בו עשוי להעניק הגנה לרעיון שאינו תואם את האזון המצוי בחוק הפטנטים. דברים דומים ניתן לומר על ההגנה שמעניקה פקודת הפטנטים והמדגמים לצורות (157 ג-ג).

(7) צורת ההגנה, היקפה ואורכה שונים מחוק לחוק בהתאם למטרותיו. פטנט זוכה למונופול של עשרים שנים. מדגם זוכה אף הוא למונופול של עד חמש-עשרה שנים. זכות יוצרים אינה נהנית ממונופול, אך משך ההגנה היא שבעים שנה (157 ג-ד).

(8) בכל תחום קיים איזון בין הרצון לעודד יצירות חדשות על-ידי מתן תמריץ לייצור הרעיון, הביצוע המקורי או הצורה החדשה או המקורית, ומול זה השאיפה שלא להעניק הגנה רחבה מדיי שסופה שבעל הזכות זוכה במונופול המאפשר לו ליהנות על חשבון

הציבור ולמכור את המוצר ללא תחרות ובמחיר מופקע, כאשר המחיר החברתי של המונופול עולה על התועלת שבו (157 ד-ה).

(9) אין להשתמש בהגנה המבוססת על חוק פלוני לשם הגנה על מהות השייכת לחוק פלמוני (157 ו).

ז. (1) יש לראות את התיבה "אמנות" בסעיף 35(1) לחוק [זכות יוצרים](#) במסגרת הקטגוריה של "מלאכת אמנות" בהגדרת "יצירה אמנותית" כמשקפת דרישה נוספת על זו הקיימת ביצירות מסוג אחר - דרישה לאמנותיות (159 א-ב).

(2) המונח "אמנות" בהקשר שבו מדובר ב"יצירות אמנותיות" אינו בא להציב דרישה נוספת לגבי היצירות אלא רק לציין סוג של יצירות. בהקשר זה, להבדיל מן ההקשר של "מלאכת אמנות", המילה אמנות אינה משקפת דרישה איכותית אלא רק נועדה לתאר סוג מסוים של יצירות (159 ו-ז).

ח. (1) זכויות יוצרים הן חלק ממערך הדינים שנועדו להגן על קניינו הרוחני של אדם (160 ג-ד).

(2) [בחוק זכות יוצרים](#), שלא כבדינים אחרים, קיימת הבחנה בין הזכויות הכלכליות לבין הזכויות "המוסריות" בקניין הרוחני. הזכויות הכלכליות כוללות הוראות הנוגעות להענקת המוצר ולשיווקו על-ידי מי שאינו זכאי לכך. הזכויות המוסריות דנות בזכותו של המחבר שהיצירה תופיע תחת שמו, ובזכות המחבר למנוע את סילוף יצירתו (160 ד-ה).

(3) דיני זכויות יוצרים נועדו לתמרץ בעל זכות יוצרים להעשיר את עולם היצירות. דינים אלהם כלי שנועד להסדרת ייצור פרטי של טובין ציבוריים, כאשר הטובין הציבוריים שמדובר בו הוא עולם היצירות המקוריות (161 ה-ו).

(4) לטובין ציבוריים שני מאפיינים: (1) חוסר היכולת למנוע שימוש או הנאה ללא תשלום; (2) הנאתו של אדם אחד מהמוצר אינה גורעת מיכולתו של אדם אחר ליהנות ממנו (161 ז, 162 ג-ד).

(5) הזכויות הכלכליות (וגם המוסריות) שמעניק [חוק זכות יוצרים](#) נועדו להשיג את המטרה של עידוד ייצורם של טובין ציבוריים (162 ו-ז).

(6) מטרתם של זכויות יוצרים היא לעודד את הגיוון בביטויים ובידע הקיים ולהעשיר את

--- סוף עמוד 138 ---

עולם הביטויים. מעבר לגיוון במידע ובביטויים שיבואו לידי מימוש, שואף החוק גם לעודד את הפצתם ולהבטיח את הגעתם לציבור רחב ככל האפשר (163 א, ד).

(7) אין די בהשקעה בלבד כדי להצדיק הענקת הגנה של זכות יוצרים לביטוי. התפקיד המאזן של החוק נובע מכך שמתן זכויות יוצרים על ביטוי מסוים מגביל ביטויים עתידיים אפשריים (165 א).

(8) מטרתן של זכויות יוצרים היא להגן על יצירתו המקורית של היוצר, אך בד בבד לאפשר ולעודד פיתוח יצירות מקוריות חדשות הנבנות על הרעיון המצוי באותה יצירה, וההתפתחות בשדה הביטויים צריכה להשתקף בשדה ההגנה המשפטית עליהם ובאיזון בין ביטויים מוגנים לשאינם מוגנים (165 ו-ז).

(9) מעבר לשיקולי המדיניות, גם קריאת [חוק זכות יוצרים](#) תומכת בכך שאין להסתפק בהשקעה בלבד כדי להכיר ביצירה כזכאית להגנה. הפירוש הלשוני של הדרישה למקוריות מתיישב יותר עם דרישה לדבר מהותי מאשר עם דרישה להשקעה בלבד (166 ה-ו).

(10) אף שהקניין הרוחני שואף להגן על השקעתו המנטאלית של היוצר, הוא מגביל את תחולתו לאור מטרות חברתיות אחרות. ערכים כמו תחרות חופשית והגבלה אפשרית של יוצרים עתידיים צריכים להישקל כנגד השקעתו של היוצר, ולכן לא די בקריטריון המסתכל על צד אחד של כפות המאזניים, כפי שעושה מבחן ההשקעה (167 ב-ג).

ט. (1) כדי שביטוי יהיה זכאי להגנה עליו להיות יצירה. יצירה בעניין זה במובנה כwork - (167 ד).

- (2) בתרגום לעברית של [חוק זכות יוצרים](#) האנגלי נשמטה הדרישה שהופיעה במקור, שלפיה נדרש שהיצירה תהיה "מקורית". למרות זאת, אין ספק שדרישה זו אכן חלה גם בחוק הישראלי, שכן זהו לב לבו של [חוק זכות יוצרים](#) (167 ד-ה).
- (3) כדי שביטוי ייחשב כיצירה עליו ללבוש חזות ממשית ולהיות תוצר של עבודה אנושית (167ו).
- (4) תנאי נוסף המשויך לעתים לדרישת היצירה, אף כי יש שהוא מצג כדרישה עצמאית, הוא שההגנה שתינתן תתייחס לביטוי ולא לרעיון העומד מאחוריו. רעיונות יזכו להגנה במסגרת ההגנה על פטנטים (167 ז-168 א).
- (5) קיים קושי יישומי בתחום של הגנה על הצורה, שכן קו הגבול בין הרעיון לביטוי, במיוחד כאשר מדובר באספקט ויזואלי, הוא דק ביותר, והוא תלוי בסופו של דבר ברמת ההפשטה שבה בוחרים לתאר את הרעיון מחד גיסא ואת הביטוי מאידך גיסא. החשש כי היוצר יזכה למעין-פטנט עם אורך חיים של זכות יוצרים על הרעיון הפונקציונלי באמצעות הגנה על ביטוי הצורני, הוא אחד הקווים המנחים בקביעת תחום התפרסותם של דיני זכויות יוצרים בהקשר של המוצר הפונקציונלי (168 א).
- (6) המחלוקת בין גישת היצירותיות לגישת ההשקעה ניתנת לפתרון במידה רבה על-ידי ההבחנה בין שלב היצירה לבין השלב שבו קיים מוצר סופי. זכות יוצרים אינה יוצרת מונופול, ותפקידה הוא רק למנוע העתקה. על-כן ייתכן שאדם אחד ייצר מוצר זהה למוצר קיים בלא שיפר את זכותו של הראשון. מכאן, כי בבחינת מקורות אין כל מקום

--- סוף עמוד 139 ---

- לעשות השוואה בין היצירה המוגמרת לבין יצירות אחרות, וההתמקדות צריכה להיות בשלב הגיבוש של היצירה (170 ז-171 א).
- (7) הבחנה נוספת שעשויה להועיל היא ההבנה בין מצב שבו היצירה מתבססת על יצירה אחרת מוגדרת וקיימת, לבין שימוש באבני בניין כלליות המשמשות את היוצר. ככל שהיצירה מתבססת פחות על יצירות קיימות, קל יותר להניח שאכן מדובר ביצירה מקורית. ככל שיש דמיון רב יותר בין היצירה שבה מתבקשת זכות יוצרים לבין יצירה קיימת, כך עובר הדגש לבדיקת השוני בתוצר הסופי, כאשר ההנחה היא שהיצירה הקודמת מוכרת ליוצר המאוחר (171 ד-ה).
- (8) כאשר קיימת יצירה קודמת שעליה מבוססת היצירה שבה מתבקשת זכות יוצרים, קיימת נקודת מוצא שניתן להניח לגביה כי ביטוי הלוש את הצורה של אותה יצירה אינו מקורי, ואזי ניתן לבחון אם המוצר המפר שונה מהמוצר המקורי, והמקוריות נבחנת על-ידי בדיקת השוני בפועל בין שני המוצרים. לעומת זאת, כאשר אין הביטוי מעוצב על בסיס מוצר ספציפי קודם, לא ניתן לעשות השוואה כזו, ובמקרים כאלה תתמלא דרישת המקוריות, אלא אם התוצר הסופי עושה שימוש בדברים מובנים מאליהם, מוכרים ופשוטים הנמצאים בתחום הציבורי, כמו בעיגול או בקו פשוט. המחסום שעל היוצר, המתבסס על יצירה קיימת, לעבור הוא גבוה יותר, ודומה שהדבר הגיוני וגם עולה בקנה אחד עם המטרה של הרחבת צורות הביטוי הקיימות (171 ה-ז).
- י. (1) הקשר בין צורה לפונקציה מתבטא בשתי דרכים שונות, האחת שיש בה כדי לצמצם את הגנת זכות היוצרים והאחרת שיש בה כדי להרחיבה (177 ג).
- (2) כאשר הצורה מוכתבת על-ידי הפונקציה, דהיינו כאשר הפונקציה מצמצמת את הצורות האפשריות שבהן ניתן לעצב את המוצר, אזי אין הצדקה להענקת זכות יוצרים על הצורה שהיא תוצר של שיקול פונקציונלי-אמנותי, שכן ההגנה שתינתן מגינה על הפונקציה ולא על הבחירה המקורית של היוצר בצורה הספציפית (177 ג).
- (3) כאשר הצורה הספציפית נבחרת למרות התפקיד הפונקציונלי, יש מקום להגנה על היצירה כיצירה אמנותית, אף שהביטוי האמנותי המקורי בא לידי ביטוי באלמנטים אשר יש להם גם תפקיד פונקציונלי (177 ג-ד).
- יא. (1) על המבחן לדרישת האמנותיות של מוצר לצורך [חוק זכות יוצרים](#) לעמוד בשלושה תנאים: ראשית, עליו לשרת את המטרה שלשמה הוא נוצר, קרי: הצבת דרישה נוספת, מעבר לדרישות "הרגילות" (של מקוריות ויצירתיות) לקבלת הגנה על-פי החוק, אשר תצר את

תחום היצירות המוגנות, כאשר מדובר ביצירה מתחום המוצרים הפונקציונליים. כל זאת בלי לפגוע במטרתם של דיני זכויות יוצרים לעודד את גיוון הביטויים הבאים לידי מימוש. שנית, עליו להיות ישים. לישית, יש להימנע ככל האפשר ממבחן העשוי, במכוון או שלא במכוון, להעניק עדיפות לקבוצה מסוימת או להשקפת עולם מסוימת. חשש זה גדול במיוחד כשמדובר בעניין סובייקטיבי מטבעו כמו ביטויים בכלל ואמנות בפרט, ועל-כן רצוי לקבוע מבחן אובייקטיבי ככל האפשר (179 ו-ז).

(2) המבחן המתמקד בכוונת היוצר עונה על כל הדרישות (180 ג).

(3) יש לבסס את המבחן לא על כל כוונת היוצר ליצור מוצר אמנותי אלא על בדיקת

--- סוף עמוד 140 ---

השיקולים שהנחו אותו בעיצוב הצורה. יש לבדוק לפי המבחן אם היוצר, בעיצוב צורת המוצר, הביא בחשבון גם שיקולים שאינם מוכתבים על-ידי השיקול הפונקציונלי או השיקול התועלתני (180 ד-ה).

(4) העובדה שקיים שיקול מסחרי כלשהו איננה שוללת את ההגנה (180 ה).

(5) המבחן אינו בודק את תוכן השיקולים או את "איכותם" (180 ו-ז).

(6) די אם המרכיב האמנותי יהיה אחד השיקולים שהביאו לעיצוב צורת המוצר והשפיעו על צורתו הסופית. לא נדרש שהוא יהיה השיקול העיקרי או החשוב ביותר, אם כי ההגנה תינתן רק לאותו חלק של המוצר שצורתו מוכתבת על-ידי השיקול האמנותי (181 א).

(7) לא די בשיקולים בשלב גיבוש הצורה, ויש להתייחס גם לתוצאה, קרי ליצירה עצמה (181 ב).

(8) מבחן בחירה גם צריך להביא בחשבון את סוג היצירות שבהן מדובר, את מהות האלמנט שבו מתבקשת זכות היוצרים ואת מספר האלטרנטיבות הבאות בחשבון (181 ה).

(9) אין למנוע זכות יוצרים רק משום שמדובר באלמנט פשוט ולא מסובך (181 ה).

(10) הקריטריון המנחה הוא מידת ההגבלה שמתן זכות היוצרים תטיל על יצירות עתידיות (181 ה).

יב. בתחום של מוצרים פונקציונליים המשווקים באופן תעשייתי קיימות שתי מערכות דינים נפרדות: דיני מדגמים ודיני זכויות יוצרים. מכיוון שמדובר במוצרים פונקציונליים, יש תחולה גם לדיני הפטנטים במיוחד בנסיבות שבהן יש קרבה או זהות בין הרעיון לצורה שבה הוא בא לידי ביטוי (184 ג-ד).

(2) למערכות הדינים מטרות שונות, ולאור זאת גם "מבחני קבלה" שונים שנועדו להגשים אותן. זכויות יוצרים נועדו להרחיב ולגוון את יצירתם של ביטויים מקוריים ולהפיצם. לצורך זאת הם מציבים את מבחני היצירה, המקוריות והאמנותיות. מדגמים נועדו להגן על יוצר הצורה החדשנית של המוצר, ועל-כן המבחנים שהם מציבים הם מבחן משיכת העין וכן הדרישה שהמדגם יהיה "חדש או מקורי" (184 ד-ה).

(3) ההבדל במטרות ובמבחנים יוצר גם הבדל באופן ההגנה ובמשך ההגנה שנותנים הדינים. כויות יוצרים מתמקדות בהגנה על תהליך היצירה, ועל-כן עניינם העיקרי במניעת העתקה כדרך ליצירת האיוון הראוי בין עידוד ביטויים חדשים לאי-הרתעת ביטויים פוטנציאליים. על-כן, מה שאסור הוא ההעתקה ולא עצם היצירה של מוצר זהה. מכיוון שהעיקר הוא מניעת העתקה, משך התקופה שלה ניתנת הגנה הוא ארוך יחסית: משך חיי היוצר ועוד שבעים שנה. דיני המדגמים מגינים על הצורה עצמה ועל-כן מעניקים ליוצר מונופול מלא על הצורה, בלי כל קשר לדרך שבה הגיע אליה היוצר השני. משך ההגנה במדגם הוא חמש-עשרה שנים (184 ז-ז).

(4) דיני זכויות יוצרים נוצרו במקור לשם הגנת יצירות מתחום ה fine arts. דיני מדגמים נועדו לחול בתחום של applied arts ובמיוחד בתחום התעשייתי (184 ז-א).

(5) מדגמים מגינים על חדשנות בתוצר הסופי בעוד שזכות יוצרים מגינה על מקוריות בשלב גיבוש הצורה (186 א-ב).

יג. כאשר מדובר בזכות יוצרים ביצירה אמנותית, אם המוצר עצמו אינו זכאי להגנה של

--- סוף עמוד 141 ---

זכות יוצרים (וממילא לא תיתכן הפרה בהעתקתו), לא ניתן על-ידי העתקתו (להבדיל מהעתקת שלבי ביניים שלו) להפר זכות יוצרים בשלב הכנה כלשהו של המוצר ובכלל זה בשרטוטיו (189 ב-ג).

(2) ההפרדה בין האספק הספרותי לאמנותי של השרטוט מבהירה שכאשר מדובר במוצר שצורתו מוכתבת אך ורק על-ידי שיקולים פונקציונליים, למעשה אין בשרטוט כל אספקט "אמנותי", כמובנו של ביטוי זה ב**חוק זכות יוצרים**, וכל מטרתו של השרטוט היא העברת מידע בלבד. עם זאת, כאשר בוחנים את ערכו ה"אמנותי" של השרטוט כמבטא ביטוי ויזואלי הזכאי להגנה, הרי שכמו בעניין המוצר עצמו, אין ליצור הבחנה חדה בין האלמנטים הפונקציונליים לוויזואליים שבשרטוט (190 א-ב).

יד. (1) בעל דין שטען טענה בהליך אחד וטענתו התקבלה, מושק מלהתכחש לטענתו גם בהליך נגד יריב אחר (שבעניינו לא נוצר מעשה-בית-דין) ולטעון טענה הפוכה (194 ו).

(2) השתק מסוג זה חל לא רק במקרה כמו המקרה דנן, שבו זכות אחת מוציאה את הזכות האחרת, אלא גם כאשר לבעל דין נתון כוח לבחור, על-פי העדפתו, בין זכויות. משזכה בזכות אחת, אין הוא יכול לדרוש את הזכות האחרת (194 ו).

(3) ההשתק מלטעון טענה סותרת לטענה שמכוחה זכה התובע לסעד בהליך קודם חל במשפטנו מכוח חובת תום הלב הקבועה בסעיפים 12-39 ל**חוק החוזים** (חלק כללי), תשל"ג-1973. חובה זו הורחבה בסעיף 61(ב) לחוק אל כלל החיובים, והפסיקה הרחיבה אותה וראתה בה עיקרון אוניברסי, המתפרש על כל תחומי המשפט. מחובת תום הלב נובע האיסור על שימוש לרעה בהליכי משפט. העלאת טענות סותרות היא פן אחד של איסור זה (199 ג, ז).

(4) מטרתו של השתק זה היא כפולה: (א) במישור המשפט הציבורי, הוא נועד לשמור על טוהר ההליך המשפטי, ולמנוע מבעל דין לנצל לרעה את בתי המשפט ובכך לפגוע בהשלטת הצדק; (ב) במישור המשפט הפרטי, תכליתו היא למנוע תוצאות בלתי צודקות המתחייבות לכאורה על-פי הדין (בהנחה שהטענה המאוחרת היא הטענה הנכונה), וזאת על-ידי השתקת בעלי הדין מלטעון ומלהוכיח בבית המשפט טענות עובדתיות ומשפטיות גם אם הן נכונות (200 א).

(5) השתק זה, שביסודו גם שיקולים במישור המשפט הציבורי, רחב מן ההשתק מכוח מצג או הבטחה, שלהקמתו נדרשים הסתמכות בעל הדין על הטענה המקורית שבעטייה ניתן הסעד, ושינוי מצבו לרעה עקב כך (200 א).

(6) לנוכח המאטריה מושא הדין דנן - זכויות יוצרים לסוגיהן - הזכייה במדינה אחרת בסעד על סמך טענה סותרת אינה שוללת את תחולת ההשתק השיפוטי (200 ג-ד).

(7) תכליתה של אמנת פאריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי, שאליה הצטרפה ישראל, היא ליצור הרמוניה בין מערכות דיני זכויות היוצרים במדינות השונות (200 ד).

(8) אינטרס ברור במערכת דינים עולמית הרמונית יש גם למדינות, בתור שכאלה, שכן, אם מדינה אחת לא תכבד את זכויותיהם של יוצרים ממדינות אחרות, היא תהיה צפויה ליחס דומה בנוגע לזכויות של יוצריה. זאת ועוד: מדינה שלא תגן על זכויות יוצרים ממדינות אחרות, לא תזכה לקבל מידע ממדינות אלה (200 ה).

--- סוף עמוד 142 ---

(9) (אליבא דנשיא מ' שמגר): עקרונית - ומטעמים של תקנת הציבור ומדיניות משפטית ראויה - יש למנוע מניפולציות שבהן עולות לסירוגין טענות משפטיות סותרות. אך הנושא של השתק בשל טיעונים סותרים ראוי לסיווג מלא ומדויק יותר, ואת תחולתו במקרה דנן יש להשאיר בצריך עיון (147 א, ב, ה-ו).

פסקי-דין של בית המשפט העליון שאוזכרו:

- [1] [ע"א 594/80, 658 אליאב נ' "הסנה" חברה ישראלית לביטוח בע"מ וערעור שכנגד, פ"ד לו \(3\) 543.](#)
- [2] [ע"א 1393/92 נ' קוצ'קוב הבל נ' צ' קוצ'קוב, פ"ד מח \(4\) 353.](#)
- [3] [ע"א 360/63 סטרוסקי בע"מ ואח' נ' גלית ויטמן בע"מ ואח', פ"ד מ \(3\) 340.](#)
- [4] [ע"א 528/73 אטינגר נ' אלמגור ואח', פ"ד כט \(2\) 115.](#)
- [5] [רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י. אליהו בע"מ ואח', פ"ד מד \(2\) 309.](#)
- [6] [ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verres de saint Gobain פ"ד מה \(3\) 224.](#)
- [7] [ע"א 448/60 לב ואח' נ' המשביר המרכזי בע"מ ואח' ו-ערעור נגד, פ"ד טז 2.688.](#)
- [8] [ע"א 430/67 שרנע בע"מ ואח' נ' תנובה בע"מ ואח' וערעור שכנגד, פ"ד כב \(1\) 113.](#)
- [9] [ע"א 23/81 הרשקן ואח' נ' אורבך ואח', פ"ד מב \(3\) 749.](#)
- [10] [ע"א 132/86 גורי נ' מדינת ישראל ואח', פ"ד מב \(1\) 555.](#)
- [11] [ע"א 151/85 רודן נ' א' רודן, קטין באמצעות אמו ואח', פ"ד לט \(3\) 186.](#)
- [12] [ד"ר 7/81 פנידר, חברה להשקעות פיתוח ובנין בע"מ ואח' נ' קסטר, פ"ד לז \(4\) 673.](#)
- [13] [בג"צ 566/81 עמרני נ' בית הדין הרבני הגדול ואח', פ"ד לז \(2\) 1.](#)
- [14] [ע"א 700/81 מ' פז נ' א' פז, פ"ד לח \(2\) 736.](#)
- [15] [ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח', פ"ד מו \(5\) 454.](#)

פסקי-דין של בתי המשפט המחוזיים שאוזכרו:

- [16] [ת"א \(י-ם\) 41/92](#) קימרון נ' שנקס ואח', פ"מ תשנ"ג (3) 10.
- [17] [ת"א \(י-ם\) 673/90](#) - לא פורסם.

פסקי-דין אמריקניים שאוזכרו:

- 1142D . 2F . 834Brandir intern., inc. V. Cascade pacific lumber
[18]co
(1987).
- . 417U.s . 464Sony corp. Af america v. Universal city studios,
[19]inc
(1984).
- [20]harper 471row v. Nation enterprises& . 539U.s (1985).

---סוף עמוד 143---

- [21]1365D . 2F . 650Miller v. Universal city studios, inc (1981).

- [22]. S. 111 Feist publications, inc. V. Rural telephone service co., inc . 1282ct(1991)
- [23] 177 alva studios, inc. V. Winninger . 265F. Supp (1959).
- . Leon . F . 91 Telegraph co& pacific telephone 484D2 (1937).
- [24]v
- [25]national business lists v. Dun . F . 552Bradstreet, inc& .supp 89 (1982)
- . 49D . 2F 81 goldwyn pictures corporation- sheldon v.(1936).
- [26]Metro
- [27]kieselstein .cord v. Accessories by pearl, inc- 989D . 2F632 (1980).
- [28]. Carol barnhart inc. V. Economy cover corp 411D . 2F773 (1985).
- [29]. F. Supp . 259Ted arnold ltd. V. Silvercraft co 733(1966).
- [30]morrisey v. Procter 379gamble company& 675D . 2F (1962).
- [31]. Long v 292D . 2S.w 291knox (1956).
- [32]433finley v. Kesling 1112D . 2N.e (1982).
- [33]. Department of transp., state of iii .V 506D . 2N.e 445coe (1983).
- פסקי-דין אנגליים שאוזכרו:
- . Interlego a.g. v. Tyco industries[1988]. All e.r 3 949(p.c).
- [34]inc
- .283[35]interlego a.g. v. Alex folley (vic) . Proprietary ltd[1987]. F.s.r
- [36]. James arnold and co. Ltd .v. Miafern ltd[1980]. . 397R.p.c
- [37]. L.b (plastics)v. Swish products [1979]. R.p.c 551(h.l)
- press, limited v. University tutorial of londonUniversity limited[1916] . . 601Ch 2[38]press
- george hensher v. Restawile (.lancs) [1975]. 31R.p.c
- (h.l) .[39]upholstery
- [40]merlet v. Mothercare [1986]. 115R.p.c (.c.a).
- [41] . B.l.m.c v. Armstrong patents ltd[1986]. A.c .577
- [42]c h engineering v. F. Klucznik& . Son& .ltd[1992]. F.s.r 421(ch).
- [43]king features syndicate, inc. V. O . M& .kleeman, ld[1941]. A.c.417
- [44]hollinrake v. Truswell (1894). 420Ch 3 (.c.a).
- [45]. Catnic components ltd. V hill& hill . Smith ltd& [1982]. R.p.c.183
- [46]drigid foley ltd. V. Elliot [1982]. . 433R.p.c
- [47]ker v. Wouchope (1819).1R.r 20 (h.l).

[48]gandy v. Gandy (1885). 1154L.j. ch.d 54 (.c.a).

[49]bangu de moscou v. Kindersiey [1950]. All e.r 2 549(c.a).

[50] v. Wellsharrison [1966]. 524All e.r 3 (.c.a).

---סוף עמוד 145---

[51]. Industrial properities v .a.e.i. ltd[1977]. 293All e.r 2 (.c.a).

--- סוף עמוד 146 ---

פסקי-דין גרמניים שאוזכרו:

147case no. Izr 846iic89 23Q (1991).

[52] פסקי-דין הונג-קונגיים שאוזכרו:

. 409F.s.r

. Interlego a.g. v. Tyco industries inc and others[1987]

[53] (.c.a). פסקי-דין ניו-זילנדיים שאוזכרו:

. R.p.c

.o manufacturing co. V. Lincoln industries ltd- wham[1985]

127(c.a). [54]

מקורות המשפט העברי שאוזכרו:

[א] שו"ע, חו"מ, פא, כב-כג.

[ב] ש"ך, חו"מ, פא, ס"ק נז.

[ג] טור, חו"מ, פא, כח.

ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (הנשיא א' וינוגרד) מיום 13.6.89. [בת"א 331/85](#). הערעורים נדחו.

ד"ר א' גולדנברג - בשם המערערת (המשיבה בערעור שכנגד); ד"ר ש' כהן, ג' שושני - בשם המשיבות (המערערות בערעור שכנגד).

פסק-דין

הנשיא מ' שמגר: 1. ערעור וערעור שכנגד על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, שבו נקבע כי קוביות משחק להרכבה המיוצרות על-ידי המערערת אינן כשירות להגנה על-פי דיני זכויות יוצרים.

העובדות והליכים קודמים

2. המערערת, חברת S/ interlego (להלן - המערערת), הינה חברה דנית עוסקת בייצור משחקים לילדים. בשנות החמישים החלה המערערת בייצור ובשיווק של לבני משחק עשויות פלסטיק. לבנים אלו דמו בצורתן, וביחס בין מידותיהן השונות, ללבנים אמיתיות, ותוכננו כך שניתן יהיה לחברן זו לזו וליצור מבנים וצורות שונים, שאותם ניתן לפרק (ולארכיב אחר כך מחדש) בלי לפגוע בלבנים עצמן.

אפקט זה הושג על-ידי בליטות מעוגלות בחלקן העליון של הלבנים, אשר התאימו במידותיהן לחלל אשר מצוי בחלקן התחתון של לבנים מאותו סוג. בשלב מאוחר יותר (1958), שונה התכנון הבסיסי - אשר היה פרי העתקה מיחידות שתכנן אדם בשם הילרי פייג' ואשר שווקו על-ידי תחת השם

---סוף עמוד 147---

"קידיקרפט" - באופן שהחלק התחתון של הלבנים לא היה חלול עוד, אלא הכיל שורה בת שלושה גלילים חלולים; גלילים אלו תוכננו כך שהבליטות המצויות בחלק העליון של הלבנים יוכלו להיכנס ברווח בין לבין דופנותיה החיצוניות של הקובייה; בכך הושג שיפור ניכר בעוצמת החיבור בין הלבנים לבין עצמן. בשלב השלישי (1967) פיתחה המערערת קוביות המבוססות על עיקרון זה, אך נבדלות מהקודמות להן בממדיהן הגדולים יותר. קוביות אלו תוכננו כך שיתאימו יותר להרכבה בידי ילדים בגיל הרך וגם שניתן יהיה לחברן ליחידות הקטנות יותר. היחידות שווקו על-ידי המערערת תחת השם "דופלו". הקוביות שווקו לראשונה בחור"ל בשנת 1969 וזכו להצלחה מסחרית גדולה. קוביות אלו עומדות במרכזו של ההליך שהוא נושא ערעור זה.

המשיבה הראשונה, חברה ספרדית בשם line bros. S.a- (להלן - המשיבה), עוסקת אף היא בייצור צעצועים. בין השאר, מייצרת המשיבה, משנת 1979, קוביות הרכבה גדולות לפעוטות, המכונות "טנטה אלפנט". לטענת המערערת, קוביות משחק אלו אינן אלא העתקה של קוביות הדופלו, ולפיכך ייצורן על-ידי המשיבה ושיווקן בישראל על-ידי המשיבה השנייה מהווים, לפי טענתה, הפרת זכויות היוצרים של המערערת ומקימים עילת תביעה בגין הפרה זו.

3. (א) התביעה שלפנינו ניתנת לבחינה במספר דרכים. בפסק-דין הלך בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד הנשיא ד"ר א' וינוגרד) בעקבות פסקי-דין שניתנו באנגליה ובהונג-קונג ושעסקו בהפרת זכויות יוצרים בקוביות דופלו, ובעיקר פסק הדין בעניין [34] interlego a.g. v. Tyco industries inc (1988) (וראה גם [35] interlego a.g. v. Alex folley (vic)proprietary (1987) והתמקד בשאלת תחולתו של [סעיף 22\(1\) לחוק זכות יוצרים](#), 1911, על הנסיבות שלפנינו. סעיף זה קובע כי מקום שמדובר ב"סימני אמצאה הראויים להירשם על פי חוק הפטנטים וסימני האמצאה, 1907...", לא יחול [חוק זכות יוצרים](#). משמע, יצירה העונה לתנאי הנ"ל לא תהא זכאית להגנת [חוק זכות יוצרים](#). בית המשפט המחוזי מצא כי תנאי זה התקיים בקוביות נושא הדיון, ועל-כן קבע שאינן זכאיות להגנת [חוק זכות יוצרים](#).

(ב) [סעיף 22\(1\) הנ"ל](#) אינו קובע מתי יצירה זכאית להגנת זכות יוצרים, אלא הוא בא לשלול זכות זו מקום שהיצירה עומדת בתנאים הנדרשים כדי ליהנות מהגנה על-

פי [חוק זכות יוצרים](#), אך מיתוספת עליה זכות ליהנות מההגנה הניתנת ל"סימן אמצאה" לפי חוק הפטנטים וסימני האמצאה, 1907, או, בשמה הנוכחי, [פקודת הפטנטים והמדגמים](#) (המתייחסת ל"מדגמים" ולא ל"סימני אמצאה"). כלומר, מקום שיצירה זכאית להגנה הן לפי דיני זכויות יוצרים והן לפי דיני המדגמים, בא [סעיף 22\(1\)](#) ושולל את ההגנה שהיצירה זכאית לה לפי [חוק זכות יוצרים](#). המקרה שלפנינו מעורר שתי שאלות שונות, ובית המשפט המחוזי עמד על כך: לאחר שהוא סוקר את טענות הצדדים, כותב הנשיא הנכבד:

"סיכומו של הדיון עד כה הוא שעלינו לבחון אם יש לתובעת זכויות יוצרים

--- סוף עמוד 148 ---

בקוביות דופלו ובשרטוטיהן והאם הנתבעות מפירות אותן. כן עלינו לבחון אם יש תוקף למדגמי התובעת והאם הנתבעות מפירות אותם" (ההדגשות שלי - מ' ש').

בהמשך התמקד בית המשפט בשאלת המדגמים, ולאור המסקנה שאליה הוא מגיע אין הוא נזקק כלל לשאלת קיומה של זכות יוצרים בקוביות הדופלו.

לכאורה, דיון [בסעיף 22\(1\)](#) הנ"ל מניח כי התקיימו התנאים לקיומה של זכות יוצרים ביצירה, והסוגיה הנבחנת היא אם זכות יוצרים זו דינה להישלל עקב קיומה של חפיפה עם דיני המדגמים. דרכו של בית המשפט המחוזי אינה מתכוונת לענות על השאלה הראשונה שהציב בית המשפט, היינו קיומה או היעדרה של זכות יוצרים בקוביות הדופלו, אלא בית המשפט מכריע את גורל התביעה בכך שהוא קובע כי הקוביות ראויות להירשם כמדגם, ועל-כן ממילא מוצאות מגדרו של [חוק זכות יוצרים](#) על-ידי [סעיף 22\(1\)](#).

אין כל פסול בדרך שנקט בית המשפט המחוזי, והיא דרך אפשרית להכרעה במחלוקת. עם זאת, מהלך הדיון בערעור זה, שלא כדרכו של בית המשפט המחוזי, יהא לבחון תחילה את שאלת זכאותו של מייצר קוביות הדופלו לזכות יוצרים. מבחינה אנליטית זוהי, לטעמי, דרך מועדפת. אוסיף, כי דומה שבתי המשפט האנגלים בחרו ללכת בדרך החלופה הראשונה בפסקי הדין שהוזכרו, מתוך מחשבה שזו תהא דרך קצה ופשוטה יותר. עיון באורכם של פסקי הדין ובמחלוקות שנתגלעו בהם מצביע על-כך שלא הושג בכך פישוט, ועל-כן גם בכך אין טעם לסטות מן החלופה לבחינת הזכאות לזכות יוצרים, אשר בה בחרתי.

(ג) במה דברים אמורים: כאשר הבעיה העומדת לפני בית-משפט כרוכה בטיפול בהגנת הצורה ביצירות ובמוצרים הנמצאים על קו התפר בין דיני המדגמים ודיני זכויות יוצרים, ואשר מיוצרים באופן תעשייתי, קיימת נטייה להעדיף שימוש בדיני המדגמים, אשר מותאמים יותר לתחום של מוצרים פונקציונליים תעשייתיים. נטייה זו נובעת מהנחה, בלתי מוצדקת, כי חלוקת העבודה באשר לקניין רוחני במוצרים פונקציונליים נעשית רק על-ידי סיווג מוצרים לפי חוקים שונים ולא באמצעות איזון פנימי הקיים בתוך כל חוק. לפי גישה זו, החלוקה מתבטאת בכך שמוצרים מסוג מסוים (לא תעשייתיים) זוכים להגנה [בחוק זכות יוצרים](#), ומוצרים מסוג אחר (תעשייתיים) - להגנת מדגמים, חלוקה שאף באה לידי ביטוי [בסעיף 22\(1\)](#) הנ"ל. בערעור זה נבקש להצביע על כך שבנוסף על מנגנון החלוקה בין החוקים קיים מנגנון נוסף להתמודדות עם הנושא של מוצרים פונקציונליים. מנגנון זה מתבטא בכך שחוק יוצרים עצמו מכיל בתוכו איזון מיוחד לצורכי יצירו פונקציונליות, שנועד להתמודד עם הקשיים המיוחדים שמציבים מוצרים אלה. איזון זה חשוב, שכן אף שכלל דיני המדגמים מותאמים יותר לטיפול ביצירות פונקציונליות, עדיין קיים סוג של יצירות אשר מן הראוי לתמרץ אותן, אך הוא אינו זוכה להגנה במסגרת דיני

המדגמים, ושלילה מוחלטת של הגנת חוק יוצרים מיצירות פונקציונליות, פירושה הסרת ההגנה על יצירות זו.

--- סוף עמוד 149 ---

(ד) קראתי את דברי חברתי הנכבדה, השופטת דורנר, הסבורה כי המערכת מושקת מהעלאת הטענה כי נתקיימה בידה זכות יוצרים, הואיל והיא טענה בהליך משפטי באנגליה כי זכותה ראויה להגנה כמדגם; והרי נובע [מסעיף 22 לחוק זכות יוצרים](#) כי שתי הטענות אינן יכולות לדור בכפיפה אחת.

גירסתה המשפטית העקרונית של חברתי הנכבדה מקובלת עליי, אולם נותר בלבי ספק לגבי תחולתה במקרה שלפנינו, ועל-כן בענייננו הייתי משאיר את העניין בצריך עיון.

ראשית דבר, [סעיף 22](#) אינו שולל את התחולה באופן החלטי מכל מדגם, אלא מוציא סוגי מדגמים מן התחולה של [סעיף 22](#) רישא.

עיקרו של דבר, הנושא של השתק בשל טיעונים סותרים ראוי לסיווג מלא ומדויק יותר. כך איבחנו למשל [בתקנות סדר הדין האזרחי](#), תשמ"ד-1984, בין טענות עובדתיות חלופיות לין טענות משפטיות חלופיות ([תקנה 72\(ב\)](#)). זאת, כמובן, באשר לטענות באותו הליך.

גם בהליכים נפרדים יש מקום להבחנה בין מעמדן של הטענות: [בע"א 594/80](#), 658 אליאב נ' "הסנה" חברה ישראלית לביטוח בע"מ וערעור שכנגד [1], שהוזכר על-ידי חברתי, וכן גם [בע"א 1393/92](#) נ' קז'קוב הבל נ' צ' קז'קוב [2], היה מדובר על טענות שהיו בעיקרן עובדתיות; כך עניין הקשר של מחלה לשירות הצבאי, דבר המחייב מימצא בעניין אופי השירות והשפעתו של בריאותו של פלוני; כך גם בקשר לשאלה אם פלוני המצווה היה במועד מסוים מסוגל לצוות או שמא לא ידע מה עמו.

זאת ועוד, יש נסיבות שבהן אין לשלול מכול וכול את העלאתן של גירסאות משפטיות בעלות לבוש שונה; כך יכול פלוני לטעון כהליך אחד, בנסיבות מסוימות, לקיומו של חוזה המקנה לו זכות כספית, ומשנדרת טענתו, היינו משהועמד על טענתו, אינני רואה מדוע בהליך נוסף, שסב על אותה פרשה, לא יוכל לטעון (למשל במסגרת הגנתו) כי חלים על העניין דיני עשיית עושר.

כאמור, עקרונית - ומטעמים של תקנת הציבור ומדיניות משפטית ראויה - יש למנוע מניפולציות שבהן עולות לסירוגין טענות משפטיות סותרות, אך, כפי שצינתי, הנושא ראוי לדיון מקיף לשם סיווג מדויק יותר של הנושא, ועל-כן הייתי משאירו בצריך עיון.

מהלך פסק הדין

4. עיקרו של פסק הדין שלפנינו עוסק בבחינת הצורה וההיקף של ההגנה שמעניק [חוק זכות יוצרים](#) לצורתם של יצירות או מוצרים פונקציונליים. נקודת המוצא היא כי אין הצדקה לשלילה אפריורית של הגנת זכות יוצרים ממוצרים פונקציונליים.

עם זאת מציבים מוצרים אלו קשיים מיוחדים, שאינם קיימים ביצירות אחרות, ואלו מתבטאים בשניים:

חשש שזכות יוצרים על צורה תהווה מנופול על הרעיון העומד מאחורי הביטוי המוגן, וחשש להגבלת יתר של עולם הצורות העתידי. היקף ההגנה שיינתן למוצרים פונקציונליים צריך להתחשב בקשיים מיוחדים אלו, מחד גיסא, וברצון לתת תמריץ ליוצרים פוטנציאליים להמשיך וליצור ביטויים מקוריים, ועל-ידי כך לגוון ולהרחיב את עולם הביטויים הקיים, מאידך גיסא. החיפוש אחר האיזון הראוי בין החסרונות שבמתן הגנה לביטוי, קרי, הגבלת יוצרים עתידיים, ובין היתרונות שבמתן הגנה, המתבטאים בעידוד יצירתיות, הוא עיקרו של הדיון במקרה שלפנינו.

תרגום השיקולים העיוניים ללשונו של [חוק זכות יוצרים](#) מגלה כי האיזון הרצוי, המתחשב בקשיים המיוחדים שמעורר מתן הגנה למוצרים פונקציונליים, בא לידי יטוי בדרישה ל"אמנותיות". לגישתי, המבחן הראוי לבחינת היותה של יצירה "אמנותית", כמובנה של דרישה זו ב[חוק זכות יוצרים](#), הוא מבחן בן שני חלקים. המבחן מתמקד בכוונת יוצר היצירה, אך הוא גם מביא בחשבון את התוצאה הסופית. בעוד שחלקו הראשון של המבחן מתמקד בעידוד יצירות מקוריות עתידיות, חלקו השני מונע מתן הגנה לביטויים במקרים שבהם יש במתן ההגנה משום הגבלת יתר של עולם הרעיונות והצורות. על-ידי כך יוצר מבחן האמנותיות, בתוך [חוק זכות יוצרים](#), מבחן המאפשר טיפול ביצירות פונקציונליות, וזאת עוד בטרם מגיעים לשערו של [סעיף 22\(1\)](#) הנ"ל.

יישום המבחן על המקרה שלפנינו מראה כי אין מקום למתן הגנה של זכות יוצרים לקוביות הדופלו, שכן אין הן עומדות בדרישה ל"אמנותיות". לאור זאת אין צורך לדון בתחולתו של [סעיף 22\(1\)](#) הנ"ל על העניין שלפנינו.

פסק הדין דן גם בטענות המערערת כי היא זכאית להגנת זכות יוצרים בגין שרטוטי קוביות הדופלו ובגין קוביות הדופלו כ"פיתוחים". טענות אלו, מעבר לכך שיש בהן כדי למתוח את תחום פריסתן של קטיגוריות אלו מעבר למטרתן המקורית, הרי שיש בקבלתן כדי לייתר את דרישת האמנותיות ואת האיזון שאליו היא שואפת.

לאור זאת, נדחות טנות המערערת גם בנקודה זו.

זכות יוצרים בקוביות הדופלו

5. [סעיף 1\(1\)](#). [לחוק זכות יוצרים](#) מקנה הגנה ליצירות "ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואמנותיות...".

המערערת מבססת את זכאותה לזכות יוצרים על שני ראשים עיקריים:

- (א) קוביות הדופלו הן יצירות אמנותיות, כמובנו של מונח זה ב[חוק זכות יוצרים](#);
 - (ב) שרטוטי הקוביות הן יצירות אמנותיות וספרותיות.
- זכות יוצרים ביצירה מופרת, בין היתר, על-ידי מכירתה או הפצתה לצורכי מסחר של יצירה מוגנת ([סעיף 2\(2\)](#) [לחוק זכות יוצרים](#)).

לטענת המערערת, פעולותיה של המשיבה בכל הקשור לקוביות ה"טנטה אלפנט" מהווה הפרה של זכות היוצרים שלה בקוביות הדופלו, הן במוצרים

wham, שניתן בבית המשפט לערעורים בניו-זילנד. באותו מקרה היה מדובר במשחק של צלחות פלסטיק מעופפות (frisbees), אשר דרך ייצורן, בדומה לדרך שבה מיוצר הלגו, היא על-ידי יצירת תבנית שאליה מוזרק חומר פלסטי חם המתקשה ומגיע לצורה הרצויה. בית המשפט הכיר בקיומה של זכות יוצרים לגבי דמות frisbeen - מכוח היצירה המוגמרת, קרי הצלחת המעופפת עצמה, תוך שקבע שבשני המקרים מדובר בפיתוחים.

המילה engraving טומנת בחובה התייחסות למוצר שהוא תוצר של חריטה, חיתוך

או כתיבה על מצע קשה כלשהו, והצורה הנוצרת כתוצאה מכך The new encyclopedic dictionary of (new york, edited by v.s webster 1971, tatcher ad e. Mcintosh)289 english language engraving: In its widest sense, the art of cutting designs, writing, "hard substance etc., on any" כפי שצוין בע"א 360/83 [3] הנ"ל, בעמ' 350, המכנה המשותף לכל היצירות הכלולות בהגדרת "פיתוחים" הוא שמדובר ביצירות העושות שימוש, לשם ייצורן, ב"קלישה" או בתבנית. בדרך כלל, השלב הבא לאחר שנעשו פעולות החריטה, החיתוך או ההדפסה על המישטח שנבחר, הוא שממנו עושים דגם על-ידי מילוי החלקים שנחתכו או שנחקקו. בצורה זו הדגם הוא תמונת ראי של המישטח שעליו נעשו החיקוקים, והחלקים השקועים בתבנית הם החלקים הבולטים בדגם. מדגם זה מייצרים לאחר מכן את המוצר הסופי. כלומר, מדובר בתהליך יצירה הכולל "העתקה, שיכפול או שיעתוק..." (ע"א 360/83 [3] הנ"ל, בעמ' 351). בית המשפט בפרשת manufacturing- wham no הנ"ל לא ראה קושי ליישם גישה זו למוצרים שנוצרו על-ידי שיטות של הזרקה לתבנית.

זאת על-ידי הרחבת המושג פיתוחים בשני אופנים:

(א) בגדר פיתוחים יש לכלול כל שלב בתהליך של פיתוח העושה שימוש בטכניקות שיש בהן תבנית. על-כן ייחשבו כפיתוחים לא רק הלוח המקורי שבו נעשו פעולות החריטה, היתוך או ההטבעה, אלא גם הדגם שהוא תמונת הראי של התבנית, וגם המוצר הסופי, ובלבד שזה יוצר בשיטה של הטבעה או העתקה מהדגם. הרחבה זו מוצדקת לאור הרצון למנוע מצב שבו ניתן יהיה לעקוף את זכות היוצרים על המוצר הסופי על-ידי העתקה של התבנית או של הדגם שמהם הוא מיוצר (Ltd. V. miafern ltd(1980) [36]403, at james arnold and co.) יש לציין שהחוק האנגלי משנת 1988 כלל את המונח

---סוף עמוד 153---

Engraving כחלק מההגדרה של עבודה גרפית, ועל-כן ספק אם כיום באנגליה תינתן הגנה ליותר מן המישטח המקורי שבו נעשו פעולות החיתוך, החריטה או ההטבעה. (113) tootal, the law of industrial (1990, london) (design).

(ב) שיטה של הזרקה לתבנית אף היא בגדר פיתוח, אלא שבמקום שהדגם יטביע עצמו על מישטח, המישטח (קרי הפלסטיק הנוזלי) מטביע עצמו בתבנית (O-)

man. manufacturing co[54]154, at wham (הרחבה זו מנומקת בכך שאין ליצור מצב שבו ההגנה על המוצר מותנית בסוג התהליך שבו נוצר (שם, בעמ' 155).

קיים אי-דיוק במסקנותיו של בית המשפט בפרשת o manufacturing[54]. wham מטרתה של ההגנה על זכות היוצרים האמנותית היא הגנה על הצורה המקורית שהיא פרי עבודתו של היוצר. לשם כך ש להגן על כל גלגול שלה בדרך אל המוצר הסופי, כפי שאכן עושה ההרחבה הראשונה שנעשתה בפסק-דין [36]. Co. Ltd & james arnold הנ"ל. אולם אין להרחיב את ההגנה למוצר הסופי רק משום שתהליך הייצור שלו כלל שימוש בתבניות בשלב כלשהו, ודברים אלו אמורים גם לגבי השימוש בתהליך ייצור של הזרקה לתבניות. מטרתם של הדינים בדבר זכויות יוצרים למנוע העתקת יצירות מקוריות. הגנת הדין משתרעת הן על המוצר הסופי והן על שלבים מוקדמים בייצור, אם הביטוי המקורי בא לידי מימוש גם בהם. אך שלבי הביניים בייצור שונים מהמוצר הסופי בכך שאין הם מהווים איום על יוצרים אחרים, ואין הם יוצרים סכנה של הגבלת יכולתם של אלו ליצור ביטויים מקוריים נוספים. על-כן יש לנהוג זהירות יתר במתן הגנה תחת סיווג זה למוצרים מוגמרים, ואין להקיש באופן ישיר מהרחבה של קטגוריה החלה על שלבי ביניים, להרחבה החלה על המוצר המוגמר. לא כל שכן כאשר מדובר במוצר פונקציונלי שבו קיימת גם דרישה של אמנותיות.

קשה לראות מוצר כמו קוביית לגו בגדר "פיתוח", גם אם תהליך ייצורו כלל שלב של תבנית שלתוכה הוזרקה דיו. בין המונח "פיתוח" לבין קוביית הלגו אין כל קשר, ואין גם כל סיבה להרחיב את ההגדרה ל "פיתוח" לנוכח קיומן של אלטרנטיבות מתאימות יותר. על-כן במקרה של מוצר המיוצר תוך שימוש בתבניות, כפי שתואר לעיל, התבנית עצמה תזכה להגנה תחת ההגדרה של "פיתוחים", בעוד שלמוצר הסופי יועדו האכסניות של פיסול או מלאכת אמנות. ההבדל בין פסק-דין james arnold & [36] Co. Ltd. למקרה של o manufacturing co-[54]. wham הוא בכך שבראשון דובר על תהליך שבו תוצר תהליך ההטבעה (ה- engraving) היה הדגם שממנו יוצר המוצר הסופי, ועל-כן הייתה הצדקה להגן עליו, אחרת היה חסר כל אכסניה אפשרית, ובפסק הדין השני תוצר ה"הטבעה" היה המוצר הסופי, שלו מיועדת אכסניה אחרת בחוק. על-כן, לדעתי, אין לקבל את הטענה כי המוצר הסופי של תהליך הוא בגדר פיתוח (על ההבחנה בין תהליכים שונים לעניין קבלת הגנה על מוצר כ"פיתוח" ראה גם [ע"א 360/83 \[3\] הנ"ל](#), בעמ' 352). ראוי להעיר, שהדגש הוא על שלב הייצור של המוצר, ולא על השלב שבו הוא מועבר הלאה. ייתכן שאדם יקנה מן היוצר את התבנית ולא את המוצר הסופי. עצם העברת התבנית מהיוצר לאדם אחר אינה שוללת את האפשרות שזו תוגן כ"פיתוח", כפי שאינה

--- סוף עמוד 154 ---

יוצרת אפשרות, אם זו לא הייתה קיימת קודם לכן, שזו תהא זכאית להגנה כ"מלאכת אמנות.

נימוק נוסף למסקנה זו, שחשיבותו עולה מהמשך הדברים, הוא שאחרת מתאפשר למוצרים פונקציונליים ופונקציונליים-תעשייתיים לעקוף את דרישת האמנותיות הקיימת בקטגוריה של "מעשה אמנות" ולקבל הגנה מכוח [חוק זכות יוצרים](#). לדעתי, כפי שתפורט בהמשך, דרישה זו משמשת נדבך חשוב באיזון הראוי, שאותו מעמיד [חוק זכות יוצרים](#), בין תחרות חופשית מזה לבין עידוד יוצרים מזה,

ואין לאפשר עקיפתה על-ידי קבלת הגנה בערוץ אחר. מכאן שההגנה על צורתם של מוצרים פונקציונליים במסגרת [חוק זכות יוצרים](#), צריך שתיעשה במסגרת הקטגוריה של "מלאכת אמנות" בלבד.

סיכומו של עניין: קוביות הדופלו אינן נכללות בקטגוריה של "פיתוחים". מכאן, שאם רוצה המערער לזכות בהגנה על צורתן של קוביות הדופלו כיצירה אמנותית, על הצורה להיכלל בקטגוריה של "מלאכת אמנות".

קוביות הדופלו כ"מלאכת אמנות"

8. המערער מבקש ליהנות מהגנת זכות יוצרים על קוביות הדופלו. זכות יוצרים, שלא כפטנט, אינה מגינה על הרעיון אלא על הביצוע שלו. מכאן שלא ניתן, באמצעות זכות יוצרים, להגן על הרעיון של קוביות המתחברות אלו לאלו, אלא רק על הביצוע של הרעיון הבא לידי ביטוי בקוביות הדופלו. במילים אחרות, המערער מבקש הגנה על הביטוי הספציפי של הרעיון הבא לידי ביטוי בקוביות הדופלו. ההגנה המתבקשת היא בהיות הקוביות מוצר אמנותי, ופירושו של דבר שהמערער מבקש הגנה של זכות יוצרים על הצורה של הדופלו.

אלא שקוביות הדופלו אינן יצירה אמנותית כמו תמונה או פסל שנועדו ל"ראותם בלבד". שלא כתמונה וכפסל, שה"שימוש" היחיד שנעשה בהם הוא ההתבוננות בהם, לדופלו יש גם תפקיד פונקציונלי הכרוך בשימוש בו: הוא נועד לשרת מטרה מסוימת, והיא השימוש ככלי משחק. המונח "פונקציונלי" מתייחס לכל שימוש פיזי מעבר להנאה המופקת מעצם הצפייה במוצר. הגדרה זו רחבה מהגדרת המוצר בר השימוש (useful), שהחוק האמריקני נוקט אותה, המצמצמת את השימושים הנוספים שיש להתחשב בהם לשימושים המקנים תועלת גשמית. בעבר רווחה ההנחה כי מוצרים פונקציונליים זכאים להגנה על הרעיון בלבד באמצעות פטנט, בעוד שמוצרים "אמנותיים" שמטרתם היא שהצופה יפיק הנאה מעצם הצפייה בהם ללא כל שימוש אחר, רק הם זכאים להגנת זכויות יוצרים. לפי גישה זו גם מוצרים אשר להם תפקיד כפול, היינו, שיש להם אפקט אמנותי אך משמשים גם לצורך פונקציונלי כלשהו, אינם זכאים להגנת זכויות יוצרים. יוצא שהפונקציונליות שוללת א ההגנה גם כאשר למוצר יש שימושים מעורבים, אמנותיים וגם אחרים. זכות יוצרים יש להעניק רק ליצירות השייכות לfine arts - ולא לאלו הנמנות עם ה-applied arts. זו הייתה הגישה בחוק זכויות היוצרים האמריקני עד 1909 (סעיף 86 לחוק משנת 1870).

--- סוף עמוד 155 ---

הגישה המתוארת אינה מקובלת כיום. ההתקדמות הטכנולוגית מחד גיסא, והרעיונית מאידך גיסא, הובילו לטשטוש ניכר של קו הגבול בין יצירות אמנותיות לפונקציונליות ולהכרה גוברת בערכם האמנותי האפשרי של מוצרים ויצירות מכל הסוגים, ובכלל זה פונקציונליים (ראה בעניין זה R.M. Polakovic, "Should Rethinking Conceptual Art Be in the Copyright Doghouse?", 1993 U. Colo. L. Rev. 64(888-886, 871)). Separability כתוצאה מכך, גבר הרצון לעודד השקעה בצורתם של מוצרים אלו: התפיסה המודרנית היא שגם אם מדובר במוצר פונקציונלי אין כל סיבה שיהיה מכוער, ועל-כן יש לעודד גם את מי שמשקיע בשיפור המראה החיצוני של מוצרים

If... We are to 'end the divorce' between our industry and our culture" we must assimilate the machine aesthetically as well as economically " we must make him beautiful- , as quoted by not only (Museum of modern art, new york, machine art (1969 reprint ed) must we bind frankenstein כפי polakovic, supra, at; 'מ' ש' 889 שאראה בהמשך, מוצר אשר צורתו מוכתבת אך ורק משיקולים פונקציונליים, אינו זכאי להגנה אלא בדיני הפטנטים, אך הבעיה מתעוררת כאשר הצורה היא תוצר של שיקולים מעורבים, פונקציונליים ואמנותיים, שכן פונקציונלי ואמנותי אינם מוציאים זה את זה (r.c. denicola, "applied art and industrial design", 1. Rev. Minn 67" a suggested approach to copyright in useful articles 712, 707, (1982-83) מכאן שאין כל סיבה א-פריורית לשלול באופן מוחלט מאמן (שבמקרה של מוצר פונקציונלי ייקרא מעצב) את היכולת ליהנות מזכות יוצרים על הצורה של המוצר אך ורק משום שיש למוצר תפקיד פונקציונלי.

ממסקנה זו נובעת הבעיה העומדת במרכזו של ערעור זה. הרצון להגן על הצורה של מוצר פונקציונלי מחייב הבחנה בין אותן נסיבות שבהן יש אינטרס להגן על צורת המוצר לבין אותן נסיבות שבהן אין אינטרס כזה. בהנחה שעומד לפנינו מוצר פונקציונלי אשר יוצריו מעוניינים לקבל הגנה של זכות יוצרים על צורתו - מתי תוענק הגנה זו? כיצד מבחינים בין צורה של מוצר הראויה להגנה לכזו שאינה ראויה לה? הדרך בה בחרנו לבדוק שאלה זו היא הבאה: (א) בשלב ראשון יש לתחום את מסגרת הדיון העובדתית והמשפטית. על-כן נפתח בזיהוי התכונות המיוחדות למוצרים תעשייתיים ולמוצרים פונקציונליים-אמנותיים, והבעיות המיוחדות שאלו מעוררים בהקשר של זכויות יוצרים. עיון בפסיקה באנגליה ובישראל מגלה כי מערכות משפט אלו, שלא כמערכת האמריקנית, בחרו להתמודד עם בעיות אלו באמצעות הדרישה לכך שהמוצר יהיה "אמנותי".

(ב) לפני שניגשים לבדיקת תוכנו של מבחן האמנותיות, יש צורך לבדוק את מטרות דיני זכויות יוצרים. בדיקה זו מעלה מספר מסקנות:

--- סוף עמוד 156 ---

(1) דיני זכויות יוצרים הם דינים שנועדו ליצור תמריץ לייצורם של טובין ציבוריים, קרי: טובין אשר כוחות השוק כשלעצמם אינם נותנים תמריץ מספק ליצירתם.

(2) הטובין הציבוריים שאת יצירתם שואפים דיני זכויות יוצרים לקדם הם גיוון עולם הביטויים (expressions) והעשרתו.

(3) בנוסף לכך שואפים דיני זכויות יוצרים ליצור איזון בין העידוד שמקנה מתן זכות יוצרים ליוצר העכשווי לבין המגבלה שזו תטיל על יצירת ביטויים מקוריים בעתיד.

(ג) המבחים הרגילים שנועדו לקדם השגתו של איזון זה הם מבחני היצירתיות והמקוריות.

(ד) לאור מטרותם של דיני זכויות יוצרים יש להכריע לטובת הגישה הרואה כמבחן המכריע להכרה בזכות יוצרים - את קיומה של יצירתיות (creativity), וכי

לא די בעבודה (work) בלבד כדי להעניק ליוצר הגנה על יצירתו.

מכאן ניתן להסיק שתי מסקנות לגבי ניתוח המתבצע על-פי [חוק זכות יוצרים](#):
(1) השלב הקובע, שעליו צריך השופט לתת את דעתו, הוא שלב גיבוש הביטוי, ולא השוואה בדיעבד של הביטוי לעומת ביטויים קיימים.

(2) עם זאת, אם היצירה מתבססת על ביטוי קודם קיים, ניתן לצאת מההנחה שהאלמנטים הקיימים בביטוי הקיים אינם מקוריים ליוצר של הביטוי המאוחר.

(ה) כאשר זכות היוצרים אשר בה מבקשים להכיר היא זכות יוצרים בגין אלמנטים ויזואליים, לא תמיד די במבחני העזר הנ"ל; זאת לאור המספר המצומצם יחסית של אבני בניין המשתתפות בקביעת אלמנטים ויזואליים. מכאן נוצר קושי בזיהוי יצירה מקורית מחד גיסא, וחשש מיצירת הגבלה רחבה מדיי על יצירות עתידיות, מאידך גיסא.

(ו) מבחן האמנותיות נועד להתמודד עם יצירות המשלבות הן את הקשיים הנ"ל המתלווים ליצירות ויזואליות, והן את הקשיים העולים בהקשר ליצירות פונקציונליות. ביצירות שבהן צורת המוצר היא פרי שיקולים משני הסוגים, יש להבחין בין סיטואציות שבהן השיקול ה"אמנותי" הוא תכתיב של הפונקציה לבין סיטואציות שבהן הוא בא לידי ביטוי למרות השימוש הפונקציונלי.

(ז) המבחן הראוי בשאלת הענקתה של הגנת זכות יוצרים לצורתו של מוצר פונקציונלי-תעשייתי מדגיש את כוונת היוצר, אף שיש להקפיד שכוונה זו - מקורית ואמנותית כאחת - אינה מוכתבת על-ידי התפקיד הפונקציונלי של המוצר. בנוסף על כך, יש צורך לבחון גם את התוצאה המתקבלת בפועל, כדי לוודא שבמתן זכות יוצרים

--- סוף עמוד 157 ---

לא אלמנטים הצורניים שבהם היא מתבקשת אין משום יצירת מגבלה קשה מדיי על עולם הצורות העתידי.

(ח) למרות החפיפה הקיימת בין התחומים, הרי שהמטרות השונות של דיני זכויות יוצרים מחד גיסא, ודיני מדגמים מאידך גיסא, והמבחנים השונים שאותם הם מציבים, אינם מאפשרים הותרת הגנת צורתם של מוצרים פונקציונליים לדיני המדגמים בלבד.

(ט) יישום המבחן הראוי על קוביות הדופלו מראה שאין אלו זכאיות להגנת זכות יוצרים.

המוצר התעשייתי

9. מעבר לקושי ההיסטורי הנובע מהיותן של קוביות הדופלו מוצר פונקציונלי, מציבות קוביות הדופלו קושי נוסף. לא רק שמדובר במוצר פונקציונלי אלא שמדובר גם במוצר המיוצר באופן המוני. לכאורה, אין להכיר בזכות יוצרים במוצרים מעין אלו משום שהם מיוצרים על-ידי מכונה ולא בידי אדם. בניגוד ליצירת אמנות כמו תמונה או מלאכת אמנות פונקציונלית אחרת, במקרה של מוצר תעשייתי הפועל היוצר את המוצר אינו משתמש בכישרונו וביצירתיותו בתהליך הייצור אלא משקיע את המשאב האנושי של עבודה בהפעלת המכונה, ועל-כן, כך הטענה, אין כל מקום לדבר על יצירתיות ובוודאי לא על אמנותיות.

דומה שאף טענה זו אינה עומדת במבחן הביקורת, כי ניתן לטעון שיותר משהיא משקפת טענה עניינית, היא משקפת רתיעה מטכנולוגיה ומן השינויים החברתיים שזו מביאה בעקבותיה, שייתכן שהיה לה מקום בעבר אך אין לה כל מקום בעולמנו המודרני (885polakovic, supra, at). שלא כבתקופות שקדמו למהפכה התעשייתית, בתהליך גיבוש צורת המוצר אין אחדות בין המעצב ליוצר. תפקיד העיצוב מסתיים לפני שמתחיל תהליך הייצור. המעצב נותן הוראות שאותן מבצעות מכונות. אך השינוי באמצעי הייצור או בתהליכי הייצור אינו משנה לא את הצורך ולא את התפקיד שממלא עיצוב הצורה בתהליך היצירה. אותם הדברים ניתן לומר לגבי השינוי בחלוקת העבודה. כל אלה אינם משפיעים על קיומו של עיצוב צורני ועל השקעת מאמצים וכישרון ביצירתו. ניתן לומר שתפקידו של המעצב בעידן המודרני הוא ללמד את המכונה לעשות אמנות. השינויים בתהליכי הייצור והעובדה שמדובר במוצר שנועד לייצור תעשייתי המוני אינם משנים, כשלעצמם, את היותו יצירה אמנותית (e. Feldman, varieties 152, 142 of visual experience). העיצוב הצורני עומד בדרישות וזכאי להגנה של זכות יוצרים, עצם העובדה שנעשה בו שימוש לצורך מוצר פונקציונלי או תעשייתי אינו מונע החלת ההגנה עליו. V. Brandir intern., inc. (1987) [18]1147at, cascade., pacific lamber co אפילו בחוק הישראלי, המבוסס, כאמור, על החוק האנגלי משנת 1911, ניתן למצוא עיגון לכך שלא הייתה כוונה לשלול הגנה ממוצרים שמיוצרים באופן המוני. עיגון זה מצוי בסעיף 5(א) לחוק, המאפשר הגנה על קלישה של יצירה. במקרים רבים,

--- סוף עמוד 158 ---

קלישה קשורה למוצרים המיוצרים באופן סדרתי. באותו אופן החוק מגן על תקליטים והקלטות המשווקים, כדרכו של עולם, כמוצר תעשייתי במספר עותקים רב.

מוצר פונקציונלי-אמנותי

תיחום הסיטואציות שבהן יזכה מוצר פונקציונלי להגנת זכות יוצרים מעורר את

שאלת היחס בין המונחים "פונקציונלי" ו"אמנותי". עצם ההכרה בכך שמוצר פונקציונלי יכול לזכות בהגנה של זכות יוצרים כמוצר אמנותי מעידה שאין אלו מושגים המוציאים זה את זה. מוצר פונקציונלי יכול שיהיה אמנותי, כמשמעותו של מושג זה בחוק זכויות יוצרים.

למרות זאת, אין להתעלם מכך שהשיקולים וההשלכות של מתן זכות יוצרים על מוצרים פונקציונליים אינם זהים לאלו המובאים בחשבון, כאשר מדובר בזכות יוצרים במוצרים שאינם פונקציונליים. לא לחינם דורשים החוק הישראלי ואביו מולידו האנגלי את דרישת האמנותיות דווקא במוצרים אלו. לא לחינם זוכים מוצרים תועלתניים, שחופפים במידה רבה את הקטיגוריה של מוצרים פונקציונליים, לטיפול שונה ומיוחד בחוק האמריקני. מוצרים אלו מציבים קשיים ייחודיים הדורשים טיפול מיוחד, השונה מהטיפול שיצירות אמנותיות רגילות זוכות לו. שתי בעיות עיקריות עולות, כאשר מדובר במתן הגנה של זכות יוצרים למוצרים פונקציונליים: האחת נעוצה בכך שמדובר בזכות יוצרים בצורה. השנייה בכך שמדובר במוצרים פונקציונליים.

10. (א) מתן זכות יוצרים פירושו מתן מעין מונופול על מושא הזכות. אמנם אין מובר במונופול מושלם כמו במקרה של פטנט או מדגם, אך במרבית המקרים, בפועל, הכרה בזכות יוצרים מגיעה לתוצאה קרובה מאוד לכך. לאור זאת, קיים חשש שמתן זכות יוצרים על צורה מסוימת עשוי להגביל יצרנים מתחרים ולפגוע קשות בחופש היצירה, והבעיה מחריפה ככל שמדובר בצורה פשוטה ובסיסית יותר. בעיה זו היא בעיה כללית בהקשר של זכות יוצרים הנותנת הגנה לאספקט ויזואלי של מוצר. עם זאת, היא חריפה במיוחד כאשר מדובר במוצרים פונקציונליים. ראשית, משום שאלו, בדרך כלל, מוצרים המשווקים באופן המוני, ולכן להגבלה זו תהיה השלכה כלכלית משמעותית יותר, ומכאן שהשאיפה למנוע יצירת מונופול גדולה יותר. שנית, עניין לנו במוצרים תלת-ממדיים. במוצרים כאלו קשה ליצור הבחנה בין שיקולים פונקציונליים לבין שיקולים אמנותיים באשר לעיצוב המוצר. שיקול זה הוא שהביא בזמנו לחקיקת סעיף 86 לחוק האמריקני משנת 1870 שהגביל זכות יוצרים רק ל-arts fine ונחקק לאור הוספת מוצרים תלת-ממדיים לתחום ההגנה של חוק זכות יוצרים (כאמור, סעיף זה בוטל ב-1909). שלישית, היותו של המוצר פונקציונלי מגביל מראש את הצורות האפשריות, שכן היוצר יכול להביא בחשבון רק צורות היכולות להגשים את המרה הפונקציונלית. בעיה כזו אינה קיימת במוצר שאינו פונקציונלי.

(ב) קושי אחר הכרוך במתן זכות יוצרים על צורתו של מוצר פונקציונלי נעוץ לא

--- סוף עמוד 159 ---

במושא הזכות אלא במהות המוצרים שבהם היא מוענקת: מוצרים פונקציונליים. החשש הוא שדרך זכות היוצרים על הצורה יקבל בעל הזכות מונופול על הרעיון. כך, למשל, כאשר צורתו המקורית של המוצר נובעת מפיתוח של טכנולוגיה חדשה. במקרים אלה, כתוצאה מההגנה על הביטוי הספציפי באמצעות זכות יוצרים יקבל היוצר מונופול על הרעיון העומד מאחורי התפקיד הפונקציונלי של המוצר, בין משום שזו הדרך היחידה לבטא אותו ובין משום שדרכים אחרות יקרות מדי, או שאינן מקובלות על הציבור.

כנגד השגות אלה יש לציין שאין בהענקת מונופול בתחום הקניין הרוחני מעשה שהוא זר למערכת המשפטית, במיוחד בהקשרים שבהם מדובר: רעיונות וצורות. פטנטים מעניקים מונופול על רעיונות. מדגמים מעניקים מונופול על צורה. מדוע להירתע ממתן הגנה של זכות יוצרים מטעמים אלו? התשובה מצויה בשני מישורים. ראשית, לכל חוק מטרות משלו ומבחנים משלו לסיטואציות שעליהן הוא פורש את הגנתו. לא כל רעיון זכאי להגנה במסגרת דיני הפטנטים. הדרישות המופיעות בחוק הפטנטים, תשכז-1967, כתנאי לקבלת הגנה על פטנט - חדשנות והתקדמות טכנולוגית - לא קיימות בחוק זכות יוצרים, ועל-כן שימוש בו עשוי להעניק הגנה לרעיון שאינו תואם את האיזון המצוי בחוק הפטנטים. דברים דומים ניתן לומר על ההגנה שמעניקה פקודת הפטנטים והמדגמים לצורות. שנית, צורת ההגנה, היקפה ואורכה שונים מחוק לחוק בהתאם למטרותיו. פטנט זוכה למונופול של עשרים שנים. מדגם זוכה אף הוא למונופול של עד חמש-עשרה שנים. זכות יוצרים אינה נהנית ממונופול, אך משך ההגנה הוא שבעים שנה (ראה סעיף 5 לפקודת זכות יוצרים). בכל תחום קיים איזון בין הרצון לעודד יצירות חדשות על-ידי מתן תמריץ לייצור הרעיון, הביצוע המקורי או הצורה החדשה או המקורית, ומול זה השאיפה שלא להעניק הגנה רחבה מדי שסופה שבעל הזכות זוכה במונופול המאפשר לו ליהנות על חשבון הציבור ולמכור את המוצר ללא תחרות ובמחיר מופקע, כאשר

craftmanship (C) כלומר, כאשר מדובר במוצרים שימושיים, אלו נתפסים בגדרה של פיסקה (C), וכפי שניתן ללמוד על דרך השלילה מהסיפא של פיסקה (ב), נדרשת בהם דרישת האמנותיות. בלי להיכנס בשלב זה למשמעותה של דרישה זו, דומה שמטרתה היא לשמש את המסגרת הנוספת שנועדה להתמודד עם הקשיים שמעוררים מוצרים פונקציונליים.

--- סוף עמוד 161 ---

החוק הישראלי דומה, מבחינת הפתרון שהוא נוקט, לחוק האנגלי. למעשה, אין פלא בכך שכן החוק הישראלי הוא תרגום, בשינויים קלים, של חוק זכות יוצרים האנגלי משנת 1911. כזכור, [סעיף 1\(1\)](#) לחוק מעניק הגנה ל"יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואמנותיות...". [סעיף 35\(1\)](#) מגדיר כיצירה אמנותית -

"עבודות ציור, שרטוט, פיסול ומלאכת אמנות ומעשי-אמן אדריכליים ופיתוחים וצילומים."

דומה שיש לראות את התיבה "אמנות" במסגרת הקטגוריה של "מלאכת אמנות" כמשקפת דרישה נוספת על זו הקיימת ביצירות מסו אחר - דרישה לאמנותיות. יש לציין שהחוק האנגלי משנת 1911 לא הכיל את התוספת המצויה בסיפא של [סעיף 4\(1\)\(ב\)](#) הנ"ל. זו הוספה לחוק האנגלי רק בשנת 1956. על-כן ניתן לטעון שאין לקרוא את דרישת האמנותיות לתוך החוק הישראלי, שכן זה מתבסס על החוק האנגלי משנת 1911, ובו לא קיימת ההבחנה המצויה בסיפא של הסעיף האנגלי. לדעתי, פרשנות זו מוטעית, ואין להסיק דבר משינוי הנוסח האנגלי לעניינו. [ב"ע"א 360/83 \[3\] הנ"ל](#), בעמ' 348, מביעה השופטת נתניהו את דעתה שהשינוי בהגדרה בחוק משנת 1956 לא מהווה שינוי בדין אלא שהוא רק בא לתת ביטוי למצב המשפטי שהיה קיים ממילא. כלומר, השינוי בעניין זה אינו מהותי אלא לשוני גרידא. מעבר לכך, כפי שכבר ציינתי, דרישת האמנותיות ממלאת תפקיד של מסגרת נוספת ונחוצה כאשר מדובר ב"מלאכת אמנות" (artistic craftsmanship). דרישה זו עולה בקנה אחד עם תכלית החוק השואף לאיזון הראוי בין עידוד יצירתיות על-ידי מתן תמריץ כלכלי ליוצרים מחד גיסא, ואי-מתן זכות בלעדית גורפת מדיי הפוגעת ביצירתיות ומעניקה יתרונות כלכליים לא מוצדקים ליוצר, מאידך גיסא. בשנת 1911 בעיה זו לא עמדה לנגד עיניהם של כותבי החוק, שכן הוויכוח על עצם מתן זוויות יוצרים במוצרים פונקציונליים והיקפה עלה מאוחר יותר. אך מכאן אין להסיק שיש לפרש את החוק תוך התעלמות מההתפתחות הטכנולוגית והכלכלית שחלה בשמונים השנים האחרונות, במיוחד אם הדבר מוצא עיגון בלשון החוק.

המסקנה היא שהחוק הישראלי הולך בעקבות האנגלי ועושה שימוש בדרישת ה"אמנותיות" כדי להתמודד עם הקשיים המיוחדים שאותם מציבים מוצרים פונקציונליים.

ראוי להבהיר שהמילה אמנות מופיעה פעמיים בחוק הישראלי (כמו גם באנגלי): פעם אחת [בסעיף 1](#) בהגדרת סוג היצירות הזכאיות להגנה, ופעם שנייה בקטגוריה של "מלאכת אמנות". הניתוח שנעשה לעיל לגבי תפקיד דרישת האמנותיות מתייחס אך ורק להופעת דרישה זו בהקשר של "מלאכת אמנות". נכונה טענת המערערת שהמונח

"אמנות" בהקשר שבו מדובר ב"יצירות אמנותיות" אינו בא להציב דרישה נוספת לגבי היצירות אלא רק לציין סוג של יצירות. אמנותיות נאמר שם, לא להבדיל מ-לא אמנותיות אלא להבדיל מדרמטיות או מספרותיות. כלומר, בהקשר זה (להבדיל מן ההקשר של "מלאכת אמנות") המילה אמנות אינה משקפת דרישה איכותית אלא רק נועדה לתאר סוג מסוים של יצירות, המפורטות בסעיף ההגדרות. סוג זה של יצירות מאופיין בכך שהוא מתמקד באספקטים

--- סוף עמוד 162 ---

חזותיים של היצירה (interlego a. G[34] 372, at) וייתכן ששימוש במונח יצירות "חזותיות" או "ויזואליות" מתאים יותר מהשימוש במונח יצירות אמנותיות המצוי בחוק. מסקנה זו עולה הן מנוסח החוק משנת 1911, הן מהתיקון שהוזכר בחוק האנגלי, והן מהצורך במסגרת הנוספת, שקיימת במוצרים פונקציונליים אך איננה קיימת באחרים. על-כן, אין סיבה לדרוש דרישת אמנותיות לגבי קטגוריות נוספות מעבר לזו של artistic craftsmanship גם הפרשנות למונח יצירות אמנותיות במשפט האנגלי London, 13th ed. (e.p. skone james, on th 13, london) ed., by e.p. skone(1991,others)29 w.a copinger)copyright& james and [ב"ע"א 360/83](#)

[3] הנ"ל (שם, בעמ' 346).

סיכום ביניים מראה כי כעיקרון אין סיבה לשלול ממוצרים פונקציונליים ואף פונקציונליים-תעשייתיים את האפשרות ליהנות מהגנה של זכות יוצרים. עם זאת, מוצרים אלו מציבים מספר בעיות ייחודיות הנוגעות לאיזון שאליו שואף [חוק זכות יוצרים](#). כדי להתמודד עם קשיים אלו מצויה בחוק הדרישה שיצירות אלו יהיו אמנותיות ("מלאכת אמנות"). אך כדי לבדוק מה תפקידה של דרישה זו, יש צורך לעמוד תחילה, בקצרה, על מטרותיהם של דיני זכויות יוצרים.

מטרת דיני זכויות יוצרים

11. זכויות יוצרים הן חלק ממערך החוקים שנועדו להגן על קניינו הרוחני של האדם. ההצדקה להגנה על קניין רוחני זהה להצדקה להגנה על קניין מסוג אחר, ואין טעם להאריך בעניין זה. עם זאת, בבדיקת [חוק זכות יוצרים](#) יש להדגיש שתי נקודות ייחודיות: (א) בחוק זכות יוצרים, שלא כבחוקים אחרים, קיימת הבחנה בין הזכויות הכלכליות לבין זכויות "המוסריות" בקניין הרוחני. הזכויות הכלכליות כוללות הוראות הנוגעות להעתקת המוצר ולשיווקו על-ידי מי שאינו זכאי לכך. זכויות אלו מוגדרות [בסעיפים 1 ו-2 לחוק זכות יוצרים](#), ומרבית החוק הישראלי עוסק בהן. לעומתן קיימות הזכויות ה"מוסריות" הדנות בזכותו של המחבר שהיצירה תופיע תחת שמו, ובזכות המחבר למנוע את סילוף יצירתו. המינוח "זכות מוסרית" בהקשר זה אינו בא להבדיל מזכות חוקית אלא להבדיל מזכות כלכלית (ראה [ע"א 528/73](#) אטינגר נ' אלמגור ואח' [4], בעמ' 118). זכויות אלו מעוגנות [בסעיף 4 לפקודת זכות יוצרים](#). שתי מערכות זכויות אלו זוכות לטיפול נפרד במסגרת חוקים המטפלים בזכויות יוצרים. נקודה זו כבר באה לידי ביטוי באמנת ברן להגנת יצירות ספרותיות ואמנותיות כנוסחה משנת 1928, ושם, מוכרת לראשונה הזכות המוסרית.

סעיף 6 לאמנה פותח במילים-

Independently of the authors copyright, and even after right the said copyright, the author shall have the right to transfer of" claim authorship of "...the work

--- סוף עמוד 163 ---

ונוסח מאוחר יותר של האמנה משנת 1948 נוקט לשון: (ההדגשה שלי -מ' ש') "independently of the author's economic rights" בחינת ההתפתחות ההיסטורית של דיני זכויות היוצרים מגלה שבעוד שמערכות המשפט האנגלו-אמריקניות התמקדו, עד לאחרונה, בהגנה על הזכויות הכלכליות, התמקדו מערכות המשפט הקונטיננטליות בהגנה על הזכויות המוסריות, ורק לאחרונה החלו יסודות מכל שיטה לחדור אל האחרת. הזכויות המוסריות חדרו למשפט האנגלי החרות רק בשנת 1988 (הפרק הרביעי לחוק), ולזה בארצות-הברית בשנת 1989. במשפט הישראלי נקלטו הזכויות המוסריות בשנת 1981.

ערעור זה דן אך ורק בזכויות הכלכליות. על-כן, כאשר ייבחן ההסדר הראוי לעניין מוצרים פונקציונליים, מן הראוי להביא בחשבון רק אותם נימוקים ואותן מטרות והצדקות הנוגעים למתן זכויות כלכליות ולא לזכויות מוסריות.

(ב) המאפיין השני של זכויות יוצרים חל למעשה על מרבית התחומים של קניין רוחני. הוא כרוך בכך שקיים שוני בין קניין רוחני לבין קניין גשמי. שוני זה מוצג בבהירות בדברים הבאים: When an author or inventor creates something which we call intellectual property, he is adding to the total sum of human knowledge property, he is not taking something from the common domain Of limited duration, the author or creator will ultimately be adding to and expression. Since legal rights to intellectual property are "the common when his intellectual(rufus c. King generally cardozo art 9"the 'moral rights' of property rights expire & 871, as quoted by polakovic,). creators of intellectual property" ent. L.j (91-1990)supra, at 288, 267. בעל זכות יוצרים, אם כן, מעשיר את עולם היצירות שלנו. דיני זכויות יוצרים נועדו לתמרץ אותו לעשות זאת. דינים אלו הם כלי שנועד להסדרת ייצור פרטי של טובין ציבוריים (public goods), כאשר הטובין הציבוריים שמדובר בהם הם עולם היצירות המקוריות.

לטובין ציבוריים שני מאפיינים:

(1) חוסר היכולת למנוע שימוש או הנאה ללא תשלום. מרגע שהטובין הציבוריים מיוצרים, קשה מאוד לגבות תשלום בעבור ההנאה מהם. כך, לדוגמה, "ביטחון" הוא מוצר אשר מרגע שהוא קיים, נהנים ממנו כלל האזרחים במדינה וקשה לחלקו באופן סלקטיבי, אף אם יש כאלו ש"שילמו" (בכסף או בגופם) בעבורו יותר. "אוויר" הוא דוגמה נוספת לעניין זה, אף שאין הוא מיוצר בידי גוף כלשהו. כאמור, במקרה שלפנינו הטובין

--- סוף עמוד 164 ---

הציבוריים הם הצורה המקורית הגורמת הנאה (ולא המוצר השימושי הנושא אותה). מרגע שהצורה המקורית קיימת בשוק, הועשר עולם הצורות, וכל אחד מן הנמנים על החברה האנושית יכול ליהנות מצורה זו, בלי שהיוצר יוכל להגביל את הנהנים רק לאלו שמשלמים בעבור הנאתם. זאת, להבדיל מיכולתו לדרוש תשלום מכל מי שנהנה מהתכונות הפונקציונליות של המוצר (ואז הנהנים יהיו רק אלו שקנו אותו).

טענה זו, כטענה כללית בהקשר של זכויות יוצרים, אינה כה פשוטה. יכול אדם להחביא את הציור בביתו או לדרוש תשלום מכל המבקרים בגלריה שבה הציור מוצג. גם ההנאה מספר מוגבלת לאלו שקנו אותו, וממחזה לאלו שקנו כרטיס כניסה לאולם שבו הוא מוצג. שאלה קשה היא אם די בכך שהורחב עולם הביטויים הפוטנציאלי או שכדי לקבוע שאדם נהנה מהרחבת עולם הביטויים יש צורך שיחווה את הביוי המקורי בפועל. מכל מקום, ויכוח זה אינו רלוואנטי למקרה שלפנינו. כאשר מדובר במוצר המיוצר בצורה תעשייתית, אין ספק שפתרונות של הסתרת המוצר אינם רלוואנטיים. כמו כן, מכיוון שמדובר בהנאה חזותית, ברור גם שלא ניתן להגביל את זו רק למי שרכש את המוצר. תהא אשר תהא המסקנה הכללית בקשר להתקיימות תנאי זה בהקשר לזכויות יוצרים, אין ספק שהוא מתקיים בעניין מוצרים פונקציונליים-תעשייתיים כשזכות היוצרים המתבקשת מתייחסת להיבטים החזותיים של המוצר.

(2) התנאי השני הנדרש כדי שמוצר יחשב כטובין ציבורי הוא כי הנאתו של אדם אחד מהמוצר אינה גורעת מיכולתו של אדם אחר ליהנות ממנו. העובדה שפלוגי נהנה מהמוצר אינה מפחיתה את הכמות או האיכות של הטובין הציבורי העומד לרשות הכלל, ועל-כן אינה פוגעת ביכולתם של אחרים ליהנות ממנו. מובן שאדם שנהנה מההיבט הוויזואלי של מוצר אינו גורע מההנאה האפשרית של אחרים ממנו.

הבעיה העיקרית שמציבים טובין ציבוריים היא בעיה המכונה בעיית ה"טרמפיסט". כולם רוצים ליהנות מהמוצר, אך אף אחד אינו רוצה להיות זה שישקיע את כספו, זמנו או כישורו בייצורו. לכן, לכאורה, אין לשום פרט בודד תמריץ לייצר אותם. מאידך גיסא, מדובר דרך כלל במוצר המקדם את רווחת החברה ככלל, וכל אחד מהפרטים בחברה מעדיף מצב שבו המוצר קיים על פני מצב שבו הוא לא קיים. מכאן שיש לחברה אינטרס לעודד ייצורם של טובין ציבוריים אף שלו היה הדבר נותר לשליטתו של השוק החופשי, לא היו אלו באים לעולם. שני פתרונות מקובלים בספרות לבעיה זו: הפתרון הראשון הוא בחלוקה כפויה של עלויות הייצור. כך, למשל, מחלקים באמצעות מיסוי את עלויות הייצור של הטובין הציבורי "ביטחון". הפתרון השני הוא על-ידי מציאת דרך לתת לקבוצה מסוימת (לפחות) באוכלוסייה את התמריץ לייצר את המוצר הציבורי. הזכויות הכלכליות (וגם המוסריות) שמעניק [חוק זכות יוצרים](#) נועדו להשגת מטרה זו. על-ידי מתן מעין מונופול, ומניעת אחרים מהעתקת המוצר, ניתן ליוצר הפוטנציאלי תמריץ לייצר הטובין הציבוריים. שכן אף שאינו יכול למנוע מהציבור הרחב הנאה מהצורה שייצר, יש ביכולתו ליהנות באופן כמעט בלעדי מן הרווחים שיופקו מהשימוש המסחרי במוצר (ראה בעניין זה: w.j. gordon, "A structural and fair use as economic: market failure

. Colum. L. Rev 82"analysis of the betamax case and its predecessors 1600, 1610 (1982)) מטרתם של זכויות יוצרים יא לעודד את הגיוון בביטויים ובידע הקיים ולהעשיר את עולם הביטויים. אלה הם הטובין הציבוריים שאת יצירתם נועדו דיני זכויות יוצרים לעודד. מתן תמריץ כלכלי נועד לשפר את כמות המידע והביטויים ואת האיכות שלהם בלי להתייחס לתועלת שניתן להפיק מהמידע החדש או מהביטוי החדש, ובכך נבדלים דיני זכויות יוצרים מדיני הפטנטים שנועדו לעודד רק מידע יעיל או תועלתני (Vol 1, at. 64) (p. Goldstein copyright(1989,london) ולדרישות המינימאליות של יצירותיות ומקוריות הקיימות בחוק זכויות יוצרים. כעיקרון, די בכך שהיצירה מעשירה את העולם הספרותי, הדרמטי, המוסיקלי או האמנותי כדי שחוק זכויות יוצרים יעניק לה הגנה.

חשוב לעמוד על ההבחנה בין המטרה, שהיא גיוון עולם הביטויים, לבין הכלי שבו עושה חוק זכות יוצרים שימוש כדי להשיג את המטרה, הטמונה בזכויות הכלכליות של היוצר. אף שהזכויות של היוצר שעליהן שואפים להגן הן זכויותיו הכלכליות, הרי שהטובין הציבוריים שהציבור מרוויח אינו גשמיים, אלא רווח של צורות ביטוי מקוריות, ומגוונות יותר.

מעבר לגיוון במידע ובביטויים שיבואו לידי מימוש, שואף החוק ם לעודד את הפצתם ולהבטיח את הגעתם לציבור רחב ככל האפשר. קיומן של תמונות בחדרי חדרים, או הגבלת הצופים בסרט לאלו הנוכחים בהקרנת הסרט המקורי בלבד, לא די בהם כדי להבטיח את העשרת עולם הביטויים של הציבור הרחב. הזכויות הכלכליות שהחוק נותן מעודדות הן את ייצור היצירות והן את הפצתן.

אלא שבכך לא מתמצה תפקידו של החוק. אף שמתן זכות יוצרים ליוצר על יצירתו יש בו כדי לעודד פיתוחן של יצירות מקוריות, הרי שיש בו גם אלמנט שלילי המתבטא בהקטנת מרחב התמרון של יוצרים עתידיים. מאלו נשללת היכולת להשתמש במרכיבים שזכו להגנת זכויות יוצרים אצל יצרן אחר, או לחלופין הם נדרשים לשלם בעבור זכות זו ובכך מתייקר תהליך הייצור שלהם. מכאן שהשיקול אם להעניק זכות יוצרים אינו מתמצה בכך שיש בו כדי לעודד את היצרן הספציפי לייצר, אלא שיש לשקול אם אין במתן זכות יוצרים משום פגיעה קשה מדי ביצרנים פוטנציאליים עתידיים; 4at. Competition policy and intellectual; Property rights, organisation for economic (1goldstein, supra, vol cooperation and development (1989)11 report) . ככל שהיצירה שלה מוענקת זכות יוצרים פשוטה ובסיסית יותר, כך גם עולה הסכנה הכרה בזכות יוצרים בה. דרישות חוק זכות יוצרים שעליהן אעמוד בהמשך, נועדו לסנן את היצירות הטריטוריאליזם. כאשר מדובר במתן זכות יוצרים בגין אספקטים חזותיים העניין קשה יותר, שכן אבני הבניין של יצירה חזותית: צבע, גוד, צורה גיאומטרית ופרופורציה, זהים בכל היצירות, והאמן עניינו שינוי ההרכב והסידור שלהם (150.-at. 149, goldstein, supra, vol 1) אם יוענקו

--- סוף עמוד 166 ---

זכויות יוצרים ביד רחבה מדי, עשויים אלו לצמצם את אבני הבניין שהם הבסיס ליצירות עתידיות, ואזי עשוי שכרו של מתן הזכות לצאת בהפסדו.

הצורך במציאת האיזון הראוי מצריך עיון במחלוקת באשר להצדקה למתן הגנה על זכויות יוצרים. לעניין זה קיימות שלוש גישות עיקריות. אחת מהן, גישת

ה"אישיות", אינה מציבה כל בעיה. גישה זו רואה את ההצדקה העיקרית למתן זכות קניינית בנימוקים העוסקים באישיות היוצר, הווי אומר, בהיות היצירה ביטוי לאישיותו של האדם ולהגשמתו העצמית. נימוקים אלו מקומם בדיון על הזכויות המוסריות ולא הכלכליות. מרגע שהיצירה יצאה אל העולם נוצר נתק בינה לבין היוצר, ובמידה רבה יש לה חיים משלה. הזכויות הכלכליות עניינן בשלב שהיצירה כבר נפרדת מהיוצר, ולכן דומה שהצדקות העוסקות באישיות המחבר אינן בעלות משקל רב בהקשר זה.

לעומת זאת נטוש ויכוח קשה בין מצדדי התיאוריה שהזכות קשורה לעבודה שהשקיע היוצר (להלן - גישת ההשקעה) לבין אלו המבססים את הזכות על השאיפה להשגת מטרה חברתית כלשהי, ובענייננו, הרחבת מעגל הביטויים (להלן - גישת היצירתיות). מצדדי גישת ההשקעה גורסים שאדם זכאי לפירות עמלו ואין לאפשר לאדם אחר ליהנות מעבודת הזולת, ובעניין זה אין להבחין בין עבודה פיזית לעבודה רוחנית. אמר על כך Sterne: "... The sweat of a man's brows, and the exsudations of a man's brains" "I. Sterne, Tristram Shandy iii, as quoted by h. Laddie, p. Precott, are as much a man's own (1980, London) 1). (property, as the breeches upon his backside m. Vitoria, the modern law of copyright the sweat theory גישת ההשקעה בארצות-הברית לפי גישה זו, שבה תומכת המערכת, עצם ההשקעה של מאמץ, זמן או כישרון הוא שמצדיק הענקת זכות יוצרים על יצירה, והדגש בבחירה בין ביטויים שזכאים ושאינם זכאים הוא על השאלה אם מדובר בכמות מספקת של השקעה.

גישה אחרת לעניין זה אינה מסתפקת בהשקעת מאמץ ושואפת להעניק זכויות יוצרים רק כשיש במתן זכות יוצרים כדי לקדם את המטרה החברתית של הרחבת עולם הביטויים והפצתו. על-פי גישה זו לא די ב"זיעה" ויש צורך במשהו מעבר לזה כדי להקנות הגנה למאמץ המנטאלי של היוצר. יש צורך במקוריות. הדגש הוא על סוג ההשקעה (יצירתיות) ולא על הכמות שבה. ההחלטה אם מוצר זכאי או אינו זכאי להגנה תיחתך לפי השאלה אם מתן הגנה תורם למטרה החברתית שבבסיסן של זכויות יוצרים (לסקירה של המחלוקת, ראה consequences of: the legacy of a.c. yen "feist",

"the weak connection between copyright and the economics
1344, 1343 of public goods (Ohio st. L.j52(1991)).

--- סוף עמוד 167 ---

לאור מטרתם של דיני זכויות יוצרים, כפי שהוצגה לעיל, ברור כי המסקנה היא שאין די בהשקעה בלבד כדי להצדיק הענקת הגנה של זכות יוצרים לביטוי. מסקנה זו נתמכת הן בכך שדיני זכויות יוצרים מהווים איזון בין צרכים חברתיים מתחרים והן בהיקף ההגנה שבעל הזכות זוכה לה. התפקיד המאזן של החוק נובע מכך שמתן זכויות יוצרים על ביטוי מסוים מגביל ביטויים עתידיים אפשריים. גישה הרואה את הזכות כנובעת מעצם ההשקעה אינה רגישה דיה לאיזון חשוב זה העומד בבסיסם של דיני זכויות יוצרי. אמנם, גישת "ההשקעה" היא גישה מקובלת להצדקתם של דיני הקניין הגשמי, ועל-כן יש הרואים אותה כמתאימה גם לדיני הקניין הרוחני (70) xt. Black, intellectual property in industry (1989, London) דומה שההבדל בין שני התחומים אינו מאפשר את אימוצה בתחום הקניין הרוחני. הרחבת

עולם הביטויים אינה חשובה רק לביטוי העצמי של יוצר הביטוי אלא גם לעולם הביטויים של כלל הציבור והחברה. בעלות על פירות העץ אינה דומה לבעלות על הזרעים העתידים להצמיח את עצי העתיד. אף שבשני המקרים מתן בעלות מגבילה את יכולת הניצול של שאר העולם בהווה, הרי כשמדובר בבעלות על הזרעים, יש לכך השלכה גם על הגוון והכמות של העצים בעתיד, ובמקרה של בעלות על ביטוי יש לכך השלכה מרחיקת לכת על עולם הביטויים העתידי. בעניינים אלו אין לאזן רק בין שאיפותיהם של הפרטים, אלא יש גם להתחשב בטובתה של החברה כולה (corp. Of america v. Universal city (1984) [19]429, at sony studios, inc) קניין רוחני עוסק במאטריה שהיא כר למימוש שאיפות האדם, אך היא גם תחום שבו מפתחים את שאיפותיו ואופקיו העתידיים. על כן יש חשיבות רבה לא רק למתן תגמול על השקעה אלא גם למידת ההגבלה על התפתחות עתידית שמתן הזכות עשוי לגרור בעקבותיו.

המערערת טוענת כי האיזון הרצוי מושג על-ידי צורת ההגנה המוענקת **בחוק זכות יוצרים**. אין מדובר במתן מונופול אלא רק בזכות למניעת העתקה, ועל-כן הפגיעה באחרים היא פחותה. טענה זו אין די בה. ראשית, בפועל התוצאה אינה שונה בהרבה. מתן זכות יוצרים מעניק במקרים רבים מונופול דה-פקטו על הביטוי. שנית, טענה זו אינה עונה על הבעייתיות הנובעת מכך שמתן זכות יוצרים על ביטוי אחד משליכה על ביטויים אחרים אפשריים הנבנים ומפותחים מתוך הביטוי המוגן או בהסתמך עליו.

גם ביטויים אלו, אף שיש בהם כדי לפתח את עולם הביטויים, אסורים למימוש או שהם דורשים קבלת הסכמתו של בעל הביטוי המוגן, וגם את הגבלתם של ביטויים אלו יש להביא בחשבון. בעניין זה ראוי להתחשב בכך שלעולם קיימת נטייה להשתמש בביטויים קודמים ביצירת ביטויים חדשים או מקוריים. כך, למשל, אמנות הפופ הבנויה רובה ככולה על שימוש בביטויים קיימים. מטרתן של זכויות יוצרים היא להגן על יצירתו המקורית של היוצר, אך בד בבד לאפשר ולעודד פיתוח יצירות מקוריות חדשות הנבנות על הרעיון המצוי באותה יצירה (row v. (1985) 556, at (Nation enterprises&, harper) [20]556) וההתפתחות בשדה הביטויים צריכה להשתקף בשדה ההגנה המשפטית עליהם ובאיזון בין ביטויים מוגנים לשאינם מוגנים.

הנימוק השני אשר בשלו אין להסתפק בהשקעה לצורך מתן זכות יוצרים על יצירה,

--- סוף עמוד 168 ---

קשור ישירות להיקף ההגנה שמעניקה הזכות לבעליה. כאמור, זכות יוצרים מעניקה מעין מונופול לביטוי המוגן. ההצדקה למתן מונופול, או עמדת כוח אחרת הקרובה לו בתחום דיני הקניין הרוחני, נובעת מההשקפה שאף-על-פי שידוע שכתוצאה מכך יוכל היוצר למכור את תוצרתו במחיר הגבוה מהמחיר שהיה מוכר, לו היה נמצא בתחרות, ויתור זה "שווה" לחברה בשל כך שהיא מרוויחה ביטוי מקורי שלא היה קיים קודם לכן. החברה "משלמת" על יצירת ביטוי מקורי בכך שהיא מאפשרת ליוצרו לגבות מחיר גבוה מזה שהיה גובה אילו היה מצוי בתנאי תחרות, על כל ההשלכות הכלכליות השליליות הכרוכות בכך (כמות לא אופטימלית, היעדר תמריצים לשיפור ועוד). התשלום החברתי ה"מופקע" בהווה מקבל פיצוי במתן תמריץ ליצירת ביטויים מקוריים בעתיד, competition policy and, at intellectual property right, supra 12 זוהי הדרך לתמרץ את יצירת הטובין

הציבורי על מיגוון עולם הביטויים שלהם. נימוק זה אינו מתקיים כאשר המבחן למתן הכות הוא ההשקעה ולא קיומו של ביטוי, המצדיק מחיר חברתי כאמור. עצם השקעת מאמץ, זמן או כישרון אינו יכול להבטיח שמדובר בביטוי אשר שווה ערך למחיר החברתי. דוגמה קלאסית לכך היא המקרה שבו מדובר בהעתקה הדורשת כישרון ומאמץ. לא יעלה על הדעת להגן על יצירה כזו, אולם לו אמות המידה היו המאמץ וההשקעה בלבד, הייתה יצירה כזו זוכה להגנה.

ניתן לומר שההבדל בין שתי הגישות הוא בכך שהאחת מעוניינת להגן ולעודד השקעה ביצירת ביטויים, והאחרת שואפת להגנה על יצירת ביטויים מקוריים. בהפשטה מסוימת, הגישה הראשונה מקדמת את תעשיית הביטויים והגישה השנייה את היצירות (במובן של creativity) אשר בביטויים (Miller v. Universal, 1372-1368, at city studios [21] (1981).inc) אמנם, גם גישה הדורשת יצירות אינה מבטיחה עצמה מפני הגנה על יצירות זהות, דומות או משניות בחשיבותן, שכן המקוריות שהחוק דורש אותה מתייחסת לא למוצר הסופי אלא לשלב היצירה; משמע, אם שני אנשים יגיעו לתוצאה זהה בדרך מקורית, יזכו שניהם להגנה. עם זאת, דומה שאירוע כזה הוא נדיר מאוד, ומכל מקום, לטווח ארוך, יש בגישת היצירות כדי לעודד את גיוונו של עולם הביטויים, כך שהמחיר לחברה כדאי.

מעבר לשיקולי המדיניות, דומה שגם קריאת החוק תומכת בכך שאין להסתפק בהשקעה בלבד כדי להכיר ביצירה כזכאית להגנה. הפירוש הלשוני של הדרישה למקוריות מתיישב יותר עם דרישה לדבר מהותי מאשר עם דרישה להשקעה בלבד.

המחלוקת בין גישת היצירות לבין גישת ההשקעה עלתה לאחרונה לדיון בבית המשפט העליון האמריקני בהקשר של יצירות עובדתיות (יצירות שזכות יוצרים מתבקשת לגבי סידור העובדות שהן מכילות. המקרה שנדון התייחס לספר טלפונים), והוכרעה פה אחד לטובת גישת היצירות תוך דחיית גישת ההשקעה באופן מפורש [22] (1991).feist publications, inc. V. Rural telephone service co., יש להתייחס לטענות המערערת שלפיהן דיני זכויות יוצרים נועדו לתת הגנה

--- סוף עמוד 169 ---

מלאה על כל מידע והשקעה מנטאלית. טענה זו איננה מקובלת עליי. לא כל השקעת מאמץ, ואפילו מנטאלי, מעניקה לאדם זכויות קניין או זכויות אחרות. גם דיני הקניין הרוחני מסויגים במפורש הן בעצם מתן הזכות והן ביצירת החריגים, כאשר מדובר על אינטרס חברתי לגיטימי: כך לעניין האפשרויות לתקוף פטנט, כך לעניין השימושים המותרים בדיני זכויות יוצרים. גם הטענה בעניין מעשה של תחרות בלתי הוגנת אינה מועילה כאן. החוק הישראלי אינו מכיר בעוולה כללית כזו. ההלכה היא שעצם הפגיעה באינטרס מסחרי של בעל חוזה לא די בה כדי להוכיח קיומה של העוולה. תחרות חופשית מחייבת מתן חופש פעולה, גם אם כתוצאה מכך יגרמו פעולותיו של אחד להפרת חוזה בין שניים אחרים (נ' כהן, התערבות ביחסים חוזיים (רמות, תשמ"ו) 360). באופן דומה נפסק שעצם הפגיעה בציפייה המסחרית של פלוני על-ידי אלמוני, אף אם אלמוני התעשר עקב זאת תוך גריעת רווחיו של פלוני, לא די בהם כדי להפוך את ההתעשרות להתעשרות "שלא כדין" (רע"א 371/89 ליכוביץ נ' א. י. אליהו בע"מ ואח' [5], בעמ' 328). ראה גם בעניין עוולת גניבת העין את ע"א 18/86 מפעלי זכויות ישראליים פניציה בע"מ verreies

Verreies de saint gobain les[6]de saint gobain
הרוחני שואף להגן על השקעתו המנטאלית של היוצר, הוא מגביל את תחולתו לאור
מטרות חברתיות אחרות. ערכים כמו תחרות חופשית והגבלה אפשרית של יוצרים
עתידיים צריכים להישקל כנגד השקעתו של היוצר, ולכן לא די בקריטריון המסתכל
על צד אחד של כפות המאזניים, כפי שעושה מבחן ההשקעה.

האיזון הרגיל - מבחני יצירתיות ומקוריות

12. זכאים להגנה על-פי [חוק זכות יוצרים](#) "יצירות.. אמנותיות". מכאן שכדי
שביטוי יהיה זכאי להגנה עליו להיות יצירה: קרי יצירה, בעניין זה, במובנה כ-
work, להבדיל מיצירותיות במובן של דעובפיציפיש. בתרגום לעברית של החוק
האנגלי נשמטה הדרישה שהופיעה במקור, שלפיה נדרש שהיצירה תהיה "מקורית".
למרות זאת, אין ספק שדרישה זו אכן חלה גם בחוק הישראלי, שכן זהו לב לבו של
[חוק זכות יוצרים](#). בהתאם לכך הלכה גם הפסיקה שהשלימה את אשר השמיטו
המתרגמים (ע"א 306/83 [3] הנ"ל, בעמ' 346).

עולה מכאן שבאופן רגיל קיימות שתי דרישות שביטוי צריך למלא על-מנת
שיזכה להגנה לפי [חוק זכות יוצרים](#): א. יצירה; ב. מקוריות.

באשר לתנאי הראשון, הרי שהוא מביע שתי דרישות, החלות על כל הביטויים
המוגנים במסגרת זכות יוצרים: שהביטוי ילבש חזות ממשית, ושיהיה תוצר של
עבודה אנושית. לא די בכך שהביטוי ישכון בראשו של היוצר, אלא צריך שהוא
יתגשם במציאות, כדי שניתן יהיה לתת לו הגנה. הביטוי גם צריך להיות תוצר של
מאמץ אנושי, קל וקטן ככל שזה יהיה. אין זכות יוצרים לא על צורה טבעית וגם לא
על ביטוי לא ממומש j. Philips and a. Firth, introduction to intellectual
property law (1990, london) 115 (intellecual) ככל שהן
נוגות לערעור זה, אינן מעוררות קשיים מיוחדים.

תנאי נוסף המשויך לעתים לדרישת היצירה, אף כי יש שהוא מוצג כדרישה
עצמאית,

--- סוף עמוד 170 ---

הוא שההגנה שתינתן תתייחס לביטוי ולא לרעיון העומד מאחוריו. רעיונות יזכו
להגנה במסגרת ההגנה על פטנטים. גם תנאי זה אינו מעורר קושי ברמה העקרונית.
עם זאת, קיים קושי יישומי בתחום של הגנה על הצורה, שכן קו הגבול בין הרעיון
לביטוי, במיוחד כאשר מדובר באספקט ויזואלי, הוא דק ביותר, והוא תלוי בסופו של
דבר ברמת ההפשטה שבה בוחרים לתאר את הרעיון מחד גיסא, ואת הביטוי מאידך
גיסא. החשש כי היוצר יזכה למעין-פטנט עם אורך חיים של זכות יוצרים על הרעיון
הפונקציונלי באמצעות הגנה על ביטוי הצורני, הוא אחד הקווים המנחים בקביעת
תחום התפרסותם של דיני זכויות יוצרים בהקשר של המוצר הפונקציונלי.

כאשר מדובר על הדרישה ל"מקוריות", המחלוקת אינה רק יישומית (יישום
ההבחנה) או עובדתית (האם היא קיימת), אלא עקרונית. כאן באה לידי ביטוי
המחלוקת בדבר מטרותיהן של זכויות יוצרים. יש הטוענים כי הדרישה ל"מקוריות"
מתמלאת אם ביצירה הושקעו כמות מינימאלית של זמן, מאמץ או כישרון. לעומתם
יש הגורסים כי מקוריות מבטאת את הדרישה כי היצירה תה מקורית של היוצר, הווי
אומר, שמקורה נעוץ בו ולא ביצירות אחרות או ביוצרים אחרים. במקרים רבים
המחלוקת לא התחדדה מספיק, והגישות השונות לא נתפסו כגישות חלופיות זו לזו.

כתוצאה מכך התפתחה גישה, המתנה את זכאותו של ביטוי להגנת זכות יוצרים בעמידה בשתי הדרישות (ע"א 3306/83 הנ"ל, בעמ' 346).

גישה "דואלית" זו הולידה התפתחות נוספת, לפיה שתי הדרישות אינן בלתי תלויות זו בזו. עמדה זו, המוצאת אחיזה הן בפסיקה והן בספרות, גורסת כי שתי הדרישות משלימות זו את זו. כלומר, השקעה מרובה יכולה לפצות על היעדר מקוריות ולהפך (2-16 m.b. nimmer, on copyright (1963, new york), והפסיקה שהוא מביא שם). בדרך כלל, הקושי במשפט העוסק בזכויות יוצרים מתעורר בעיקר עם דרישת היצירתיות, ואכן בפסיקה הסתמנה גישה שאיפשרה עקיפת דרישה זו. כך הכירו בתי המשפט בזכות יוצרים בהעתק מדויק, אף כי בגודל שונה, של "יד האלוהים" של רודן (rodin), בטענה כי נדרשות מיומנות גבוהה ועבודה רבה לשם יצירת העתקה מדויקת של יצירה בעלת איכות [33] (1959) (alva, studios inc. V. Winninger) (267at) מכאן כי יצירה שיצירתה דרשה השקעה רבה, מרכיב המקוריות בה יכול שיהיה קט. באופן דומה ניתנה הגנה ליצירות כמו מדריכי טלפונים, כאשר הדגש הוא על העמל שהושקע [24] (1937). (Telegraph co& leon pacific telephone) בחלק מפסקי-דין אלו נשחקה הדרישה ליצירתיות כמעט כליל. פסק-דין מאלף להדגמת מגמה זו הוא פסק הדין (1982) national business lists v. Dun Brdstreet, inc&. [25] בפסק-דין זה התובעת הייתה חברה שפירסמה רשימות שכללו מידע על בתי-עסק שונים, ובכלל זה שמותיהם וכתובותיהם. הנתבעת עסקה ביצירת רשימות מכותבים (mailing lists), ולצורך זה עשתה שימוש במידע שהיה כלול במוצרה של התובעת. יש להדגיש שהשימוש שנעשה לא היה של העתקה מלאה אלא חלקית בלבד, ואף נערכו בה שינויים. למרות זאת הכיר בית המשפט בזכות היוצרים של התובעת, כאשר ההנמקה העיקרית נובעת מכך שהנתבעת עשתה שימוש בפירות עבודתה של התובעת.

--- סוף עמוד 171 ---

שתי הגישות הגיעו לעימות חזיתי בפסק הדין בפרשת Feist publications, inc [22] שהוזכר לעיל. באותו מקרה היה מדובר בחברה (feist), שהוציאה לאור מדריך טלפונים אזורי שעשה שימוש ברשימת הלקוחות של חברות הטלפון שפעלו באותו אזור, ושפורסמו על-ידיהן כנדרש על-פי החוק בתור מדריך טלפונים. באזור היו אחת-עשרה חברות טלפון, ומעשר מהן רכשה הנתבעת את זכויות השימוש במידע המצוי במדריכים שלהן. חברה אחת (rural telephone) סירבה למכור את זכויותיה, אך הנתבעת בכל זאת עשתה שימוש במידע שבמדריך שלה, מעשה שגרר בעקבותיו תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים. גם במקרה זה לא היה מדובר בהעתקה בלבד, אלא שמוצרה של הנתבעת כלל, בנוסף לטלפונים של המנויים באחד-עשר האזורים, גם פירסום דוגמת "דפי זהב" בארץ, הכולל רשימות עסקים לפי תחומי עיסוק, וכן פרסומות. במקרה זה לא ניתן היה לחמוק מעימות בין שתי הגישות, שכן אם המבחן הקובע הוא מבחן ההשקעה, ניתן היה, כנראה, להצליח בתביעה, ואילו לפי גישה הדורשת יצירתיות, ספק אם היה בגין מה לתבוע. בית המשפט העליון האמריקני דן בסוגיה תוך התייחסות מפורשת לגישת ההשקעה, ודחה את הטענה כי תיתכן זכות יוצרים ללא כל יצירתיות. כדברי בית המשפט, בעמ' 1294: originality requires... That it display some minimal level of creativity" there remains a narrow category of works in which the creative spark is . Utterly lacking or so trivial as to be

virtually nonexistent... Such works"are incapable of sustaining a valid copyright מסקנה זו, תוך הסתמכות על פסק-דין feist, publications לאחרונה בארץ בפסיקה המחזית (ת"א (י-ם) 41/92 קימרון נ' שנקס ואח' [16] - (פסק-דינה של השופטת ד' דורנר).

בפסיקה האנגלית ניתן להבחין בהתפתחות דומה אם כי קיצונית פחות. גם באנגליה ניכרה מגמה לשחוק את דרישת היצירותיות ולנוע לכיוון דרישת ההשקעה. כך הוכרו זכויות יוצרים בגין טופסי בחינות, טופסי הימורים ולוח זמני רכבות (copinger & skone james, supra, at 21) ואף שדוגמאות אלו מקורן בהגנה על יצירות ספרותיות דווקא, הרי שהן מראות על המגמה של דגש על ההשקעה של משאבים אנושיים: זמן, עבודה, כישרון, ידע ועוד. אמנם, בתחום של יצירות אמנותיות הפגינה הפסיקה האנגלית יתר זהירות (supra, at 59 skone james, copinger & v. Swish products (plastics).l.b (at 568, [37] עם זאת, דומה שמעולם לא נזנחה לחלוטין הדרישה ליצירותיות, לפחות להלכה אם לא למעשה.

בפסיקה האנגלית נעשה שימוש שונה במקצת בגישת ההשקעה מאשר זה שדובר עליו עד עתה. ההשקעה אינה באה להחליף את היצירותיות אלא כאינדיקטור לקיומה של זו.

ההנחה היא כי ם קיימת רמה מינימאלית של השקעה, הרי יש בכך כדי להעיד על קיומה של יצירותיות הנדרשת לשם סיפוק דרישת המקוריות. זו גם הגישה בחלק מהפסיקה האמריקנית. הטעם לכך נובע מהרצון לעקוף את הצורך בשיפוט ערכי בהכרעה באשר

--- סוף עמוד 172 ---

לזכאות להגנה. בדיקת מקוריות על-ידי מבחן של השקעה היא בדיקה הנדרשת פחות לקריטריון אסתטי הניזון במידה רבה מעמדה סובייקטיבית בנושא. למרות זאת, קיימת סכנה כי בכך נעקפת הדרישה ליצירותיות, ועיון בפסיקה האנגלית מראה על שחיקה מסוימת במעמדה של דרישה זו.

בהערת אגב, ראוי לציין שלפי כל הגישות אין מדובר אלא במבחנים מינימאליים, הן לעניין ההשקעה והן לעניין היצירותיות הנדרשת. באשר ליצירותיות, הרי שמוסכם על הכול שאיננה קיימת דרישה לחדשנות כמו שמציבים דיני הפטנטים. מקובל בעניין זה להביא את דברי הלורד פיטרסון (The word(lord peterson) : "be 'original' does not in this connection mean that the work must" the expression of original or inventive thought. Copyright acts not Concerned with the originality of ideas, but with the expression of The expression of the thought. But the act does not require that the thout... In print or writing. The originality which That it should originate from the expression is required relates to must be in an original or novel form, but that the work must- not be copied from another work ,universuty of london press, limited (1916) [38]609- 608, at) ". Author(v. University tutorial press limited הלכה זו אומצה על-ידינו:

יוצרים לבין יצירה קיימת, כך עובר הדגש לבדיקת השוני בתוצר הסופי, כאשר ההנחה היא שהיצירה הקודמת מוכרת ליוצר המאוחר (61skone james, supra, at& copinger). במילים אחרות, כאשר קיימת יצירה קודמת שעליה מבוססת היצירה שבה מתבקשת זכות יוצרים, קיימת נקודת מוצא שניתן להניח לגביה כי ביטוי הלוכש את הצורה של אותה יצירה אינו מקורי, ואזי ניתן לבחון אם המוצר המפר שונה מהמוצר המקורי, והמקוריות נבחנת על-ידי בדיקת השוני בפועל בין שני המוצרים. לעומת זאת, כאשר אין הביטוי מעוצב על בסיס מוצר ספציפי קודם, לא ניתן לעשות השוואה כזו, ובמקרים כאלה תתמלא דרישת המקוריות אלא אם התוצר הסופי עושה שימוש בדברים מובנים מאלהם, מוכרים ופשוטים הנמצאים בתחום הציבורי (public domain), כמו בעיגול או בקו פשוט. המחסום שעל היוצר, המתבסס על יצירה קיימת, לעבור הוא גבוה יותר, ודומה שהדבר הגיוני וגם עולה בקנה אחד עם המטרה של הרחבת צורות הביטוי הקיימות.

עמדתי לעיל על הקושי המיוחד המאפיין יצירות חזותיות. יצירות אלה הן כולן בעלות

--- סוף עמוד 174 ---

אותן אבני בניין, ובעצם כל ביטוי הוא רק סידור או הרכב שונה של אבני הבניין הידועות. מובן עתה מדוע התמודדות דיני זכויות יוצרים עם יצירות אלה קשה במיוחד, שכן ממילא בחינת השקולים המנחים ביצירה היא מסובכת, אך זאת במיוחד אם אבני הבניין שלהן משותפות, שכן בכך נשללת האינדיקציה הטובה ביותר להיותו של משהו מקורי. התוצאה בפועל היא שכאשר מדובר על ביטוי ויזואלי שאינו מתבסס על יצירה קודמת ספציפית, רק במקרים בודדים היא תיכשל מלעמוד בדרישת המקוריות. הפן השני של קושי זה ביצירות ויזואליות הוא שדווקא משום שמדובר באותן אבני בניין קבועות לכול, עולה החשש שמתן זכות יוצרים על יצירה אחת יגביל את התהוותן של יצירות עתידיות. מכיוון שהגמישות באלטרנטיבות קטנה יותר, קיימת סיבה טובה שלא להעניק הגנה במקרים גבוליים.

החוק והפסיקה האמריקניים ניסו להתמודד עם הקושי שמציבות יצירות ויזואליות בשתי דרכים. דרך אחת, שעליה נתעכב בהמשך, על-ידי צמצום משמעותי בהגנה הניתנת למוצרים תועלתניים ובמיוחד למוצרים תועלתניים-תעשייתיים. הדרך השנייה היא ביצירת סף גבוה יותר לדרישת המקוריות, כאשר מדובר בסוגים של יצירות שבהן יש חשש שמתן הגנה לפי הקריטריונים הרגילים עשוי להביא לתוצאות לא רצויות. על-ידי כך בתי המשפט משתדלים להגיע לאיזון הרצוי במוצרים אלו, כאשר גישה זו חלה על מוצרים ויזואליים ופונקציונליים. גולדסטיין מסכם גיה זו ואת הבעייתיות שהיא מעלה: Some courts have resolved the problem of a novelty fact works, functional originality in cases involving" threshold, a works, and works of visual art by engrafting one or quantitative threshold, and an expenditure of labor threshold more of three requirements onto the basic originality standard These judicial additions may contradict congress' apparent intent That- copyrightable elements be original only in the sense that to they are not confine the originality standard to its traditionally Act, congress copied from another source. On the other low level hand, since these modifications 1976of the traditional originality

May have intended to incorporate them in standard antedate the the act, at least to the extent that they conform to the overriding object of the originality - the production of the widest possible requirement „ Encouraging "musical and(65, at. 1goldstein, supra, vol)variety of literary artistec expression של זכות יוצרים, הוא כדלקמן: (1) ביטוי לגביו מתבקשת הגנת זכות יוצרים צריך לעמוד בתנאים הבאים: (א) צריך שיהיה, לפחות בחלקו, מעשה ידי אדם.

--- סוף עמוד 175 ---

- (ב) הוא צריך ללבוש חזות ממשית.
- (ג) הוא צריך להיות תוצר של השקעה מינימאלית של משאב אנושי כלשהו.
- (ד) יצירתו צריך שתיעשה תוך שימוש מינימאלי של יצירות מקוריות, כאשר "מקורית" פירושה שהיצירות היא פרי עמלו הרוחני של היוצר, אך לא דווקא שהיא מהווה חידוש על פני יצירות קיימות.
- (ה) על היצירות המחשבתית ללבוש צורת ביטוי ולא רק רעיון העומד מאחוריו.
- (2) בחינת מקוריות היצירה צריכה להתמקד בשלב גיבוש הביטוי ולא בשלב המוצר המוגמר.
- (3) יש להבחין בין בדיקת מקוריותה של יצירה המתבססת על יצירה קודמת ספציפית לבין בדיקת מקוריותה של יצירה העושה שימוש רק באלמנטים כלליים. יצירה מהסוג השני תעבור את מחסום המקוריות בקלות יחסית.
- (4) במקרה של יצירות ויזואליות, מסקנה זו יוצרת קושי רב, שכן קיים חשש שהמעבר הקל של מחסום המקוריות יפר את האיזון בין עידוד יצירות על-ידי מתן תמריץ לייצר, לבין פגיעה ביכולת הייצור של יצירות על-ידי שלילת אבני הבניין שלהן מיוצרים אחרים.
- (5) פתרון אפשרילקושי זה הוא על-ידי יצירת קריטריון גבוה יותר של מקוריות, בין איכותי ובין כמותי.

מטרתו של מבחן האמנותיות

13. כדי שביטוי יזכה להגנה על-פי החוק הישראלי כ"מלאכת אמנות", מתחייבת, כמובן, התמודדות עם המחסום העולה מניה וביה מן המהות האמורה. כפי שעולה מהדיון לעיל, כאשר מדובר במוצרים פונקציונליים, לא די במבחן המקוריות כדי לבסס מתן זכות יוצרים. נוסף להגבלות הן על צורה והן על רעיונות, נזקק החוק למסגרת נוספת בנסיבות אלה, והיא נמצאת כאמור בדמותו של מבחן האמנותיות. דרישה נוספת זו באה למנוע הענקת הגנה מביטויים שעוברים את מבחן המקוריות, אך יש בהכרח בזכות יוצרים בהם כדי לצמצם את הביטויים האפשריים במידה לא רצויה, או שיש בה כדי להגן על רעיון בלבד במסווה של הגנה על זכות יוצרים. המבחן שיתקבל, אף שיצמצם את הביטויים הזכאים להגנה, עדיין צריך לעלות בקנה אחד עם המטרה של מתן תמריץ לגיוונו של עולם הביטויים ולהפצתו.

בישראל נדונה פירושה של דרישת האמנותיות בע"א 448/60 לב ואח' נ' המשביר המרכזי בע"מ ואח' ו-ערעור נגדי [7]). פסק הדין דן באמנותיות בהקשר לבניינים כיצירה

--- סוף עמוד 176 ---

ארכיטקטונית. דעת המיעוט קבעה כי האמנותיות קיימת כאשר "הרעיון האמנותי הגלום בבנין יתפוס אותך, כאילו, בציציות ראשך ויוציא אותך מעולם החולין לעולם רוחני ונשגב" (שם, בעמ' 2695). דעה זו לא התקבלה על דעת הרוב, שגרסה שהדרישה לאמנותיות פירושה דרישה ל"רמה אמנותית" (שם, בעמ' 2699). יצירה בעלת רמה אמנותית היא "יצירה שהיא ממין היצירות הגורמות הנאה 'אסתטית' ומשקפות את ה'פה...'" (שם). השופט אגרנט, שביטא את דעת הרוב, מציין שאין בהגדרה זו משום מבחן ממשי ושהיא בעייתית נוכח היותה סובייקטיבית מאוד (שם, בעמ' 2699). בהמשך הוא מביע דעתו שהדרך לבחינת קיומה של רמה אמנותית היא בהיווצרות במומחים.

סוגיית האמנותיות, והבעיות שהיא מעוררת, נדונו ביתר הרחבה באנגליה בפסק הדין המנחה בפרשת (1975). *george hensher v. Restawile(Lancs)* [39]upholstery נדונה שם זכות היוצרים שלה זכאית חברה המייצרת ספות ישיבה. בית המשפט לא הגיע למסקנה אחידה באשר למבחן הראוי לבדיקת אמנותיות לפי חוק זכות יוצרים. באותו מקרה היה ברור שהתובעים השקיעו רבות בבחירת עיצוב שיקלע לטעמו של הקהל (דבר שאכן הוכיח את עצמו). היה ברור גם שהנתבעים העתיקו עיצוב זה בלי שהכניסו כל שינוי משמעותי בספה. עם זאת, נפסק שאין הספה זכאית לגנה. פסק-דין זה מחזק את התיזה שלפיה לא די בהשקעה בלבד כדי לאפשר קבלת זכות יוצרים.

למרות הדיון הארוך, פסק הדין לא פיזר את הערפל סביב תוכנה של דרישת האמנותיות. ניתן לתאר את המחלוקת השונות כמסתכמות בשלוש שאלות: (א) מה צריך לבדוק כשקובעים שמשווא הוא אמנותי; (ב) האם נדרשת רמה מינימאלית של אמנותיות, ואם כן מהי; (ג) איך על השופט לקבוע את מימצאיו - האם בהסתמך על שיפוט סובייקטיבי או אולי נדרשות עדויות מומחים בנדון. בית הלורדים נחלק בשלוש הסוגיות: (א) בנושא הראשון (נושא הבדיקה): דעה אחת גרסה שיש להתרכז בכוונת היוצר. דעה שנייה שמה את הדגש על הדעה הרווחת בציבור. דעה שלישית גרסה שיש להשתמש בקריטריון אובייקטיבי כלשהו. מכל מקום, נדחתה כליל הגישה שהנחתה את בית המשפט לערעורים ואשר שמה את הדגש בנכונות הציבור לשלם בעבור האספקט האמנותי, להבדיל מן הפונקציונלי.

(ב) בנושא השני (רמה מינימאלית) לא נקבעה גם כן הלכה מפורשת. עצם העובדה שהשופטים הכירו בייחודיות הצורה של כיסאות התובעת ולמרות זאת לא הכירו במוצר כעומד בדרישת האמנותיות, מעידה כנראה על כך שהשופטים סברו שנדרש כי המוצר יעמוד בדרישה מינימאלית כלשהי, אף שהדבר לא נאמ במפורש.

(ג) בנושא השלישי (אופן הקביעה) גם כן נחלקו הדעות. יש שסברו שזו שאלה שבחוק שעל השופט להכריע בה. יש שסברו שזו שאלה שבעובדה. אחד השופטים הדגיש בהקשר זה את חשיבותן של עדויות מומחים לצורך העניין.

--- סוף עמוד 177 ---

הצורה. זכות יוצרים במקרה של מוצר תעשייתי מותנית ביכולת לעשות הפרדה בין האלמנטים התועלתניים והאלמנטים הצורניים של המוצר.

14. בנוסף לבעייתיות הנובעת מכך שגישה כזו מתמקדת בהתייחסות למוצר הסופי ולא לשיקולים שבשלב של גיבוש צורת היצירה, מעוררת גישה זו קושי הקשור בעצם טיבו של המוצר האמנותי-פונקציונלי. אחד ממאפייניו של המוצר הפונקציונלי המודרני הוא שהאמנותיות אינה מנותקת מהפונקציונליות. קיים קשר בין השניים, במובן זה שההיבט האמנותי אינו בא רק להיוסף על הפונקציונלי כקישוט, אלא שהשיקולים האמנותיים נגזרים בין היתר מן התפקיד שאותו נועד המוצר למלא. ניתן לומר שהפונקציה שאותה נועד המוצר למלא מגבילה את הצורה שאותה ילבש המוצר לא רק משיקולים פונקציונליים אלא גם משיקולים אמנותיים-אסתטיים.

The notion of expressing function through form differs in an important" respect from the more primitive requirement that form be compatible with . Function, since the former is itself a "one(740denicola, supra, at)purely aesthetic concern, expressing conception of 'good' design כשטבע את האמרה "Function follows" form כלומר, יש קשר בין התפקיד הפונקציונלי לצורה שאותו הוא צריך ללבוש, גם אם מבחינה פונקציונלית אין למלא את התפקיד בצורה הטובה ביותר גם בעיצוב אחר. נדמה שהדברים מובעים היטב בקטע הבא: ... These examples illustrate that in our society, we express logical" of the industrial designer is part of the interest of our whole society relations as structure, and we express structure This is why: like other great ages, we are in shape. The interest still looking for our own taste... In an ...our age is, like all great ages, an age of transformation Age of transformation, it is clearer Essays in the arts, aesthetic must than at other times that a sound grow from the actions that are practised and the things:j.) 41) "... That are used .(Bronowski, the visionary eye literature, and science(1978,mass בצ"א 448/60 [7] הנ"ל. כותב השופט אגרנט, בעמ': 2701

---סוף עמוד 179---

"דין זה חל - ואולי ביתר שאת - גם בשטח היצירה הארכיטקטונית, בה עשויים האספקטים התועלתניים והאסתטיים לשמש בערכוביה. הלא, כדי שהבנין, שהוא מתכננו, ייצור רושם אסתטי, אין האדריכל-האמן נזקק אך ורק או תמיד לאמצעי הקישוט, האורנמנטצי והצבע, אלא הוא סומך גם - ולעתים בעיקר על אותם העקרונות והמידות - בין מכניים ובין אחרים - העשויים להקנות לבניין את 'צורתו' המיוחדת, כגון, למשל, העקרונות של גודל, הרמוניה, פרופורציה, סימטריה, אור וצל, וכיוצא בהם. זאת ועוד, המידות (רוחב, גובה וכו') הבאות לענות, בראש וראשונה, לדרישות תועלתיות - לדרישות המוכתבות על-ידי תנאי הסביבה וצרכי האיש שלמענו מוקם הבנין - בכוחן לעתים לגרום, הן עצמן, גם לאפקט אסתטי."

וכן ראה שם, בעמ' 2702, 2703.

הקשר בין צורה לפונקציה מתבטא אפוא בשתי דרכים שונות, האחת שיש בה כדי לצמצם את הגנת זכות היוצרים והשנייה שיש בה כדי להרחיבה. כאשר הצורה מוכתבת על-ידי הפונקציה, דהיינו כאשר הפונקציה מצמצמת את הצורות האפשריות שבהן ניתן לעצב את המוצר, אזי אין הצדקה להענקת זכות יוצרים על הצורה שהיא תוצר של שיקול פונקציונלי-אמנותי, שכן ההגנה שתנתן מגינה על הפונקציה ולא על הבחירה המקורית של היוצר בצורה הספציפית. זוהי נסיבה שבה הצורה של המוצר נקבעת בגלל התפקיד הפונקציונלי שלו. לעומת זאת, קיימות נסיבות, דוגמת זו שתוארה בע"א 448/60 [7] הנ"ל, שבהן אף-על-פי שהצורה היא תוצר של שיקולים אמנותיים-פונקציונליים מעורבים, הצורה הספציפית נבחרת למרות התפקיד הפונקציונלי (889polakovic, supra at). במקרים כאלו יש מקום להגנה על היצירה כיצירה אמנותית, אף שהביטוי האמנותי המקורי בא לידי ביטוי באלמנטים אשר יש להם גם תפקיד פונקציונלי (וראה ע"א 448/60 [7] הנ"ל, בעמ' 2702).

עיון בפסיקה האמריקנית מעלה שזו התמקדה בעיקר בדרך הראשונה, ועל-כן הביאה לצמצום ניכר בהגנה על יצירות פונקציונליות. למעשה התעלמה הפסיקה האמריקנית כמעט כליל מן האפשרות ל"הפרדה קונספטואלית" והתמקדה בדרישה ל"הפרדה פיסית" בין האלמנט האמנותי לאלמנט הפונקציונלי. דהיינו, שהאלמנט האמנותי יהיה בלתי קשור לפונקציונלי - גישה אשר דומה שעבר זמנה. כך בעניין קישוטים שהופיעו על גבי אבזמי חגורות (1980) cord v. Accessories by. [27]pearl, inc- kieselstein שבו נקבע שקיימת הפרדה בין האלמנטים הפונקציונליים והאמנותיים, שכן הקישוט לא היה הכרחי לפונקציה, וכך בשני עניינים שבהם נקבע שלא קיימת הפרדה שכזו, האחד שעסק בבובה פלסטית המשמשת לתליית בגדים בחנויות בגדים (1985) [28] carol barnhart inc. V. (Economy cover korp) והאחר שעסק במיתקן לאופניים (bicycle rack). במקר השני אמר בית המשפט את הדברים הבאים: While the ribbon rack may be worthy of admiration for its aesthetic qualities alone, it remains nonetheless the product of industrial design

---סוף עמוד 180---

Design being as much the result of utilitarian pressures as aesthetic form and function are inextricably intertwined in the The rack represent design changes made in rack, its ultimate response to functional concerns. Choices. Indeed, the visually Brandir has acheived pleasing proportions and symetricality of with the ribbon rack the highest goal of modern judging from the awards the rack has received, it would seem in fact that Industrial design, that is, the harmonious fusion of function and Aesthetics. Thus there remains no artistic element of the ribbon , of, the utilitarian aspects of the article'. Accordingly, we rack must affirm that can be identified as separate an 'capable of (brandir intern., inc [18]1148- 1147, at)existing endependently . "on the copyright claim (ההדגשות שלי - מ' ש') אם כן, בית המשפט מציין במפורש כי צורת המוצר מוכתבת גם משיקולים אמנותיים, אך דוחה את הערעור בשל כך שלא קיימת, לשיטתו, הפרדה בין האלמנטים האמנותיים והאלמנטים הפונקציונליים - המכתיבים את הצורה.

ההתמקדות ב"שוני פיזי" הביאה לשימת דגש על שיקולים אמנותיים המשפיעים על הצורה בגלל התפקיד הפונקציונלי שלו, והתעלמה מן האפשרות שיהיה מדובר בשיקולים אמנותיים הבאים לידי ביטוי למרות אותו תפקיד. דומה שאין דרך אחרת להסביר את התוצאה בפסק-דין [18] Brandir intern., inc. הנ"ל, לאור הקטע שהובא לעיל.

אף שגישה זו היא הגישה השלטת בפסיקה האמריקנית, הרי שלאחרונה הובעה שם גם דעה אחרת. בפסק-דין בעניין Carol barnhart inc[28]. הנ"ל הצביע השופט Newman בדעת מיעוט על הצורך לשים את הדגש על "הפרדה קונספטואלית". המבחן שהוא מציב לכך מתקרב מאוד להכרה בשיקולים אמנותיים הבאים לידי ביטוי למרות התפקיד הפונקציונלי: "How, then, is 'conceptual separateness' to be determined? in my view, the answer derives from the word 'conceptual features' to that embodies the design, the article must stimulate in the mind be 'conceptually separate' from the utilitarian aspects of the Of the beholder a concept that is separate from the useful Utilitarian function. The test turns on what concept evoked by its . To be occurring in the mind of may reasonably be understood "mind's(422ibid., at)the beholder or, as some might say, in the eys' of the beholder משורות אלה עולה, שאכן תיתכן זכות יוצרים באלמנטים אמנותיים גם אם אלו אינם ניתנים להפרדה פיזית מהאלמנטים הקובעים את תפקידו הפונקציונלי של המוצר. השופט

---סוף עמוד 181---

Newman ממשיך וקובע שקנה המידה לקביעה אם המוצר מעורר במוחו של הצופה תפיסה השונה מזו הפונקציונלית - על-פי קנה המידה של האדם הסביר. הוא אמנם מודע לכך שקריטריון כזה מחייב שיפוט אסתטי סובייקטיבי כלשהו מצד בית המשפט, אך לגישתו שיפוט זה הוא בלתי נמנע. עם זאת, הוא מדגיש כי הקביעה באשר לקיומו של "קונספט אמנותי" מוגבלת להכרעה על קיומו של קונספט כזה ואינה מתייחסת לאיכותו.

המבחן הראוי

אם כן, מהו המבחן הראוי שצריך לבוא לידי ביטוי בדרישת האמנותיות? נציין תחילה מה הם המבחנים האפשריים העולים מהפסיקה ומהספרות.

(1) מבחן הבחירה: אחד המאפיינים של אמנות הוא שהיא משקפת את היכולת לבטא רעיון במיגוון של דרכים. לענייננו זהו מבחן רחב מאוד, שכן הוא יתקיים כל עוד יש ליוצר המוצר הפונקציונלי יכולת לבחור בין מספר אופציות.

(2) מבחן כוונת היוצר.

(3) מבחן קבלת הדבר בציבור: האם הציבור רואה במוצר אלמנט אמנותי כלשהו.

4. נכונות הציבור לשלם כסף: הטענה היא שהמוצר הוא אמנותי אם הציבור מוכן לשלם בעבור המוצר סכום כסף העולה על הערך הפונקציונלי שלו (ראה לדוגמה

האסתטית המינימאלית. [29]- ted arnold ltd. V. Silvercraft co(1966) ..5. מבחן הרמה

6. מבחן האמנות לשמה.

15. בבודקו אם המוצר שלפנינו ממלא אחר דרישת "משיכת העין" הנדרשת כדי לעמוד בתנאים לצורך הכרה במוצר כ"מדגם הכשיר לרישום" עשה בית המשפט המחוזי שימוש הן בדעתו הסובייקטיבית של בית המשפט, הן במבחן קבלת המוצר על-ידי הציבור, קרי בנכונותו לשלם, והן במבחן כוונת היוצר. ניתן לאמץ דרך שונה לשם קביעת האמנותיות של מוצר לצורך חוק זכות יוצרים. על המבחן הנבחר לעמוד בשלושה תנאים: ראשית, עליו לשרת את המטרה שלשמה הוא נוצר, קרי: הצבת דרישה נוספת, מעבר לדרישות "הרגילות" (של מקוריות ויצירתיות) לקבלת הגנה על-פי החוק, אשר תצר את תחום היצירות המוגנות, כאשר מדובר ביצירה מתחום המוצרים הפונקציונליים. כל זאת בלי לפגוע במטרתם של דיני זכויות יוצרים לעודד את גיוון הביטויים הבאים לידי מימוש. שנית, עליו להיות ישים. שלישית, יש להימנע ככל האפשר ממבחן העשוי, במכוון או שלא במכוון, להעניק עדיפות לקבוצה מסוימת או להשקפת עולם מסוימת. חשש זה גדול במיוחד כשמדובר בעניין סובייקטיבי מטבעו כמו ביטויים בכלל ואמנות בפרט, ועל-כן רצוי לקבוע מבחן אובייקטיבי ככל האפשר.

--- סוף עמוד 182 ---

מבחני "קבלת הדבר בציבור" ו"נכונות הציבור לשלם" אינם עומדים בתנאי הראשון, שכן הם מתרכזים בדרך שבה הציבור מקבל את המוצר הסופי בדיעבד ולא במתן תמריצים ליוצר מראש. כדי לתת תמריץ לייצור של ביטויים מגוונים, הדגש צריך להיות על שלב עיצוב המוצר ולא על ניחושיו של היוצר באשר לדרך שזה יתקבל בדיעבד בחברה. בנוסף לכך, התמריץ במבחנים אלו ניתן לביטויים התואמים את התפיסה החברתית הקיימת, ומטרת החוק היא דווקא עידוד של המיוחד והשונה מתוך מטרה לחרוג מהתבנית של הביטויים המוכרים. שני נימוקים אלה גם מסבירים מדוע לא די בגישה, הבאה לידי ביטוי ב"א 360/83 [3] הנ"ל, בעמ' 348, הרואה את הפתרון לבעיה בהגדרה מרחיבה של המושג "ציור" ככולל כל מיגזר שולי בציבור. לעומת זאת, שני המבחנים האחרונים, הנתלים בדרישה אמנותית כלשהי, לוקים בהיותם מבחנים סובייקטיביים מאוד וגם בלתי צפויים במידה רבה. מבחן ה"אמנות לשמה" לוקה גם בהיותו מבחן מצמצם יתר על המידה. באשר למבחן הבחירה, הרי זהו מבחן המציב קריטריון רחב ואין בו כדי לשרת את המטרה של יצירת איזון מתאים.

לעומת זאת, המבחן המתמקד בכוונת היוצר עונה על כל הדרישות. הוא ממלא את המטרה של מתן תמריץ ליוצרים הפוטנציאליים לייצר ביטויים מקוריים. הוא מתרכז בשלב גיבוש הצורה של המוצר ולא בתוצאות. האמנותיות הנדרשת היא בשלב העשייה ולא במוצר עצמו not the work itself- but, the must, in- addition, be[39]67, at craftsmanship" George hensher ltd.: . artistic התמריץ ניתן בדיוק למי שמעוניינים לתמרץ (היוצרים), בשלב שבו יש עניין לתמרץ (שלב גיבוש הצורה), ויש קשר ישיר בין התמריץ הניתן לבין התוצאה הרצויה (בניגוד למבחן המתבסס על קבלת המוצר בציבור).

עם זאת, המונח "כוונת היוצר" הוא מונח קשה להגדרה וקשה לבדיקה. יש לבסס את המבחן לא על כוונת היוצר ליצור מוצר אמנותי אלא על בדיקת השיקולים שהנחו אותו בעיצוב הצורה. בחנת השיקולים קלה יותר ליישום והיא גם אובייקטיבית.

יש לבדוק לפי המבחן אם היוצר, בעיצוב צורת המוצר, הביא בחשבון גם שיקולים שאינם מוכתבים על-ידי השיקול הפונקציונלי או השיקול התועלתני. העובדה שקיים שיקול מסחרי כלשהו איננה שוללת את ההגנה. חשוב להדגיש כי המבחן אינו בודק את תוכן השיקולים או את "איכותם". דומה שמבחינה זו מבחן "שלילי" (אילו שיקולים לא נשקלו), שמוצע, עונה יותר על דרישה זו ממבחן "חיובי" (מהם השיקולים שכן נשקלו), שכן אז אין צורך להגדיר מהו שיקול אמנותי. הבעיה הגדולה ביותר שמציב מבחן זה היא ביישומו. השימוש במבחן שלילי ובמבחן המתמקד בשיקולים ולא בכוונה, יש בו כדי להקל, אך הוא אינו יכול לפתור לחלוטין את הקושי היישומי. לא קל לבסס מבחן על דברים שבלב או בראש. זו הסיבה לגישה האמריקנית המתמקדת בביטוי החיצוני. אך דומה שהשיקולים השונים מוליכים כולם למבחן זה, ובסופו של דבר עניין לנו בתחום הקניין הרוחני, ומטרת דיני זכויות יוצרים היא הענקת הגנה לתוצר מאמציו המנטליים של האדם ולא ליציר כפיו, כך שדומה שאין להימלט מכך.

--- סוף עמוד 183 ---

שאלה נוספת נוגעת ליחס בין השיקול ה"אמנותי" לשיקולים אחרים. עד כמה צריך המרכיב ה"אמנותי" ליות דומיננטי. נראה, שדי אם המרכיב האמנותי יהיה אחד השיקולים שהביאו לעיצוב צורת המוצר והשפיעו על צורתו הסופית. לא נדרש שהוא יהיה השיקול העיקרי או החשוב ביותר, אם כי ההגנה תינתן רק לאותו חלק של המוצר שצורתו מוכתבת על-ידי השיקול האמנותי.

בדיקת השיקולים האמנותיים היא גורם חשוב בהשגת האיזון הראוי, אך לא די בכך כדי להתמודד עם הבעיה של צמצום מרחב האפשרויות של יוצרים עתידיים.

על-כן, יש לקבוע כי לא די בשיקולים בשלב גיבוש הצורה, ויש להתייחס גם לתוצאה, קרי ליצירה עצמה. אם לא כן, קיימת סכנה שאם כי צורת היצירה היא פרי שיקולים מקוריים ואמנותיים, עדיין יהיה במתן זכות יוצרים משום הטלת מגבלה משמעותית על יצירות עתידיות. למעשה, שילוב שתי הדרישות הללו קרוב מאוד לתוצאה שאלה הגיע בית המשפט בפסק-דין [40] merler. המושפט נמנע שם מלהכריע בשאלה מהו שיידרש מהיצירה עצמה (שם, עמ' 124). נדמה שלאור המטרות של זכויות יוצרים כפי שהוצבע עליהן, ולאור העקרונות לפתרון כפי שגובשו, יש לראות במבחן הבחירה מבחן ראוי, בהקשר של בדיקת המוצר הסופי. כלומר, כל זמן שהצורה המתקבלת היא אחת מתוך מספר צורות אלטרנטיביות. האלטרנטיבות צריכות להיות אפקטיביות. אלטרנטיבה אפקטיבית היא זו שלא רק ממלאת את התפקיד הפונקציונלי של המוצר, אלא גם עונה על צמצום האופציות הצורניות הקיימות לגבי יצירות עתידיות הנובע מן הקשר הקיים בין פונקציה לצורה. צריכות להיות אלטרנטיבות אשר, בנוסף לתפקיד הפונקציונלי, עומדות במגבלה הצורנית הנובעת מתפקידו הפונקציונלי של המוצר, ובמילים אחרות, צריכות להיות מספר אלטרנטיבות אשר כולן עומדות במגבלות צורניות הנובעות מן התפקיד הפונקציונלי. כך, למשל, לא תינתן זכות יוצרים על האלמנטים המקנים למכונת צורה אווירודינאמית (אף שייתכן שכן תתאפשר זכות יוצרים על אלמנטים ויזואליים אחרים). מבחן הבחירה גם צריך להביא בחשבון את סוג היצירות שבהן מדובר, את

מהות האלמנט שבו מתבקשת זכות יוצרים ואת מספר האלטרנטיבות הבאות בחשבון. אין למנוע זכות יוצרים רק משום שמדובר באלמנט פשוט ולא מסובך *morrissey v. gamble company* & (1967) [30]678, at Procter הקריטריון המנחה הוא מידת ההגבלה שמתן זכות היוצרים תטיל על יצירות עתידיות.

When the uncopyrightable subject matter is very narrow, so ...'topic that 'the" if not only one form of expression, at A party or parties, by copyrighting a mere necessarily requires handful of forms, could best only a limited number, to permit copyrighting would mean that Exhaust all possibilities of future Necessary to say that the subject use of the substance. In such matter would be appropriated by form of expression comes from the subject matter. However, it is circumstances it does not seem accurate to say that any particular Permitting the copyrighting of

---סוף עמוד 184---

. Its expression. We cannot recognize copyright as a game of chess in which the public can be checkmated (ibid) הדברים נאמרו על יצירה "ספרותית" (כללים לתחרות), אך הם רלוואנטיים, וביתר שאת, גם ליצירה אמנותית. דומה שדברים אלו ישימים במיוחד לתחום של יצירות פונקציונליות. משמעותה של בדיקת המוצר הסופי היא שייתכן שאספקט צורני, שגובש על בסיס שיקולים אמנותיים (קרי: לא תועלתניים ולא פונקציונליים), לא יזכה להגנה משום שהוא מצמצם יתר על המידה את האפשרויות העומדות בפני יצרנים אחרים של אותו מוצר. אמנם הדברים נכונים בכל סוג של יצירות, אך החשש שמתן זכות יוצרים לצורתו של מוצר אכן תגיל מפלה לציבור, חזקה במיוחד במוצרים פונקציונליים. על-כן בתחום זה תידרש בדיקה של המוצר הסופי והשוואתו לאלטרנטיבות קיימות, בעוד שבמתן זכות יוצרים שאין בה דרישה לאמנותיות לא נדרשת בדיקה זו אלא במקרים חריגים. מאליו יובן אפוא שטענת המערערת שקוביות הדופלו מעוצבות אך ורק מטעמים פונקציונליים, גם אם תתקבל, אין בה כדי להושיעה. מוצר פונקציונלי אשר מעוצב אך ורק מטעמים פונקציונליים, לא רק שאינו זכאי להגנת מדגם (צ"א [430/67](#) שרנוע בע"מ ואח' נ' תנובה בע"מ וערעור שכנגד [8], בעמ' 116, 117), אלא הוא גם אינו זכאי להגנת זכות יוצרים, או לפחות לא להגנה הכלכלית שזו מעניקה.

דוגמה יפה לפסק-דין המייצג את הגישה המשלבת בין כוונת היוצר לצורך בקיומן של אלטרנטיבות אפקטיביות מצויה בפסק-דין שניתן לא מזמן בגרמניה בעניין זה. פסק-דין זה עוסק בתרשימים המתארים הוראות שימוש במסור חשמלי. זכות היוצרים נטענה באשר לאלמנטים הוויזואליים של ההוראות, ועלתה השאלה אם תיתכן מקוריות בהוראות מעין אלו. בקבלו ערעור על הערכאה הנמוכה קובע בית המשפט הפדרלי העליון של גרמניה (bundesgerichtshof): In the case at issue, a comparison with the operating instructions" submitted for the records reveals that the first plaintiff indeed Limited by the technical nature of the device and the purpose of the exploited the scope available for individual design, even if this Hatching and gray shading for emphasis, and the indication was of different types of line, the choice of section and perspective,

the device and the purpose of the drawings. It is particularly in the use- use of cruss Of direction, that the first plaintiff has The application and combination of adopted more than a mere the design techniques avialable to routine and mechanical Like approach, but approach, and instead has used originality in are rather the individual result of the the graphic artist. These drawings are not the result of a more or less-craftsman Design into a technical illustration, using technical and creative translation of certain elements of an object derived from a technical Art in representational skills in conjunction with the techniques of graphic

---סוף עמוד 185---

Comprehensibly and visually to the reader of the operating instrctions such a way as to reveal the use and operation of the In any event the small amount of personal device in question creative sytly as is sufficient by means of appropriate pictorial information. Consequently they achieve For the assumption that Of the copyright act a technical illustration within the meaning of 1991, . 2Case sec- (1)(7)is entitled to the protection afforded " by copyright(10federal supreme court decisions, october (ההדגשות שלי - מ' ש' 52]850at I zr [147/89no. דרישת האמנותיות מגביהה אפוא את הרף בשניים: ראשית, היא דורשת שהשיקולים שיישקלו יהיו שיקולים אמנותיים (כפי שאלו התפרשו לעיל) ולא רק מקוריים. שנית, היא דורשת גם בדיקה של התוצאה ולא רק של שלב היצירה, וזאת מעבר לדרישה החלה על כל יצירה, שלפיה אין מגינים על הרעיון אלא על ביטויו בלבד.

מבט על המוצר הפונקציונלי-תעשייתי

16. בטיעוניהם לפנינו הקדישו הצדדים רבות לשאלת אופן ההגנה הראוי של

הצורה במוצרים תעשייתיים. אמנם, הערעור אינו מצריך דיון ממצה בסוגיה זו, אך פטור בלא כלום אי-אפשר, מה גם שבעיוב המדיניות הראויה לעניין הגנה על מוצרים פונקציונליים במסגרת זכויות יוצרים, אין להתעלם מההגנה שאלו זוכים או לא זוכים לה במסגרת דינים אחרים העוסקים בהגנה על קניין רוחני.

שני הצדדים דנו בנושא תוך התרכזות בהיקף תחולתו של [סעיף 22 לחוק זכות יוצרים](#), ובשאלה מהו בגדר מדגם הכשיר לרישום לצורך סעיף זה. בכל הקשור ליחס בין הדינים, הבעיות שעולות הן אותן הבעיות. כפי שעולה מן הערעור שלפנינו, ומהספרות הרבה הנוגעת ל-industrial design, תחום זה, שהוא חדש יחסית, נמצא בעיצומה של התפתחות ועיצוב לא רק בארץ אלא גם בשיטות משפט אחרות. תחום זה מהווה נקודת מפגש בין דיני פטנטים, דיני זכויות יוצרים ודיני מדגמים, ומעורר מחלוקות רבות הן בשל האינטרסים הכלכליים הכבדים המעורבים בו, והן בשל השאלות המשפטיות והמטה-משפטיות הקשות שהוא מעורר.

עמדת המערערת היא שיש להגן על כל מאמץ מחשבתי של אדם. לשיטתה, אין ספק שצורה שגיבושה הוא פרי יצירתו של אדם תזכה להגנה במסגרת אחת ממערכות ההגנה שאותן מעניק החוק, והשאלה העיקרית היא באיזה דין תשובץ

הגנה זו. לעומת זאת, המשיבה טוענת שהמוצר הפונקציונלי-תעשייתי מוצא את הגנתו בדיני המדגמים והפטנטים בלבד ולא תיתכן בו כלל זכות יוצרים. לשיטתה, המבחן הקובע הוא כוונת היוצר בעת ייצור המוצר. התכוון ליצור מוצר תעשייתי - זכאי הוא, אם יעמוד בתנאים האחרים, להגנת מדגם, ואינו זכאי להגנת זכות יוצרים. השקפתי בעניין זה שונה. באשר לדעת המערערת, הרי שכבר ציינתי שאין כוונה להגן

--- סוף עמוד 186 ---

על כל פרי מאמץ מחשבתי באשר הוא. האינטרס הציבורי הוא שאלו יהיו נחלת הכלל דווקא, וההגנה הכלכלית ניתנת להם מתוך מטרה לתמרץ ייצור ופיתוח נוספים.

שלא כלמתן זכות בקניין גשמי, הרי שלמתן זכות בקניין רוחני יש השפעה משמעותית על מיגוון הביטויים העתידיים ולא רק על הכמות העתידית שלהם, ועל-כן האינטרס הציבורי גובר על אינטרסים של הפרט. על-כן מסקנתו של בית המשפט המחוזי בעניין זה מקובלת עליי, וכפי שציין הנשיא הנכבד, ה"איום" של המערערת, שעשוי להיווצר מצב שלפיו מאמצו המחשבתי של האדם לא יזכה להגנה, אינו מטה את הכף לטובתה.

גם עמדת המשיבה אינה מקובלת עליי. אין כל סיבה א-פרוורית שלא להגן על צורתו של מוצר פונקציונלי-תעשייתי באמצעות זכות יוצרים. כפי שצוין לעיל, הסיבה לכך היא היסטורית, ואין לה הצדקה עניינית. השיקולים העומדים בבסיס מתן הגנה של זכות יוצרים לצורה הקיימת ביצירות "רגילות" קיימים גם במוצרים פונקציונליים-תעשייתיים, ואף כי קיימים שיקולים התומכים בצמצום הגנה זו, אין הם שוללים אותה לחלוטין. ראוי לציין שאין זהות בין המונחים "פונקציונלי" ו"תעשייתי", וייתכן שמוצר שהוא פונקציונלי אינו תעשייתי, ולהפך. עמדות הצדדים וערעור זה מתייחסים לתחום ה-industrial design, העוסק במוצרים שהם גם פונקציונליים וגם תעשייתיים.

התחום industrial design -הוא התחום העוסק בהגנת אספקטים צורניים של

מוצרים פונקציונליים המשווקים באופן תעשייתי. בתחום זה קיימות שתי מערכות דינים נפרדות: דיני מדגמים ודיני זכויות יוצרים. מכיוון שמדובר במוצרים פונקציונליים, יש תחולה גם לדיני הפטנטים, במיוחד בנסיבות שבהן יש קרבה או זהות בין הרעיון לצורה שבה הוא בא לידי ביטוי. כבר ציינתי שיתכן שאספקטים צורניים יישארו ללא הגנה. למערכות הדינים מטרות שונות, ולאור זאת גם "מבחני קבלה" שונים שנועדו להגשים אותן. זכויות יוצרים נועדו להרחיב ולגוון את יצירתם של ביטויים מקוריים ולהפיצם. לצורך זאת הם מציבים את מבחני היצירה, המקוריות והאמנותיות. מדגמים נועדו להגן על יוצר הצורה החדשנית של המוצר, ועל-כן המבחנים שהם מציבים הם מבחן משיכת העין ([סעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים](#)) וכן הדרישה שהמדגם יהיו "חדש או מקורי" (המילה מקורי נמחקה מהחוק האנגלי בשנת 1988).

ההבדל במטרות ובמבחנים יוצר גם הבדל באופן ההגנה ובמשך ההגנה שנותנים הדינים. זכויות יוצרים מתמקדות בהגנה על תהליך היצירה, ועל-כן ענייני העיקרי במניעת העתקה כדרך ליצירת האיוון הראוי בין עידוד ביטויים חדשים לאי-הרתעת ביטויים פוטנציאליים. על-כן מה שאסור הוא ההעתקה ולא עצם היצירה של

מוצר זהה. מכיוון שהעיקר הוא מניעת העתקה, משך התקופה שלה ניתנת הגנה הוא ארוך יחסית: משך חיי היוצר ועוד שבעים שנה. דיני המדגמים מגינים על הצורה עצמה, ועל-כן מעניקים ליוצר מונופול מלא על הצורה, בלי כל קשר לדרך שבה הגיע אליה היוצר השני (מבחינה כרונולוגית). משך ההגנה במדגם הוא חמש-עשרה שנים.

קיים הבדל נוסף בין זכויות יוצרים למדגמים, הבדל המסביר במידה רבה את הרתיעה מהענקת זכות יוצרים למוצרים פונקציונליים ופונקציונליים-תעשייתיים.

דיני זכויות

--- סוף עמוד 187 ---

יוצרים נוצרו במקור לשם הגנת יצירות מתחום fine arts. דיני מדגמים נועדו לחול בתחום של applied arts, ובמיוחד בתחום התעשייתי, שכן זה התחום שבו יש חשיבות להגנה רחבה על צורה כצורה ולא על הצורה כביטוי. על-כן מובנת הרתיעה משימוש בזכויות יוצרים בתחום של מוצרים פונקציונליים-תעשייתיים. מובן שרתיעה זו אינה במקומה בעולם שבו קו הגבול בין מוצר פונקציונלי לשאינו פונקציונלי הוא דק, ושבו עולם הביטויים מועשר במידה רבה דרך מוצרים פונקציונליים, עולם שבו ההבחנה בין אמנות ואומנות אינה קיימת (polakovic, 886supra, at), על-כן, יש להכיר בכך שההכרה בזכות יוצרים במוצר פונקציונלי אינה משנה את היותו של המוצר פונקציונלי. התחום הוא עדיין התחום של מוצרים פונקציונליים-תעשייתיים, והמוצר עצמו נותר בתחום זה. המבחן צריך להתמקד במקורם של השיקולים תיים, והמוצר עצמו נותר בתחום זה. המבחן צריך להתמקד במקורם של השיקולים שהביאו לעיצוב הצורה: האם השיקולים שגרמו למוצר להיראות כפי שהוא נראה מקורם בעולם הפונקציונלי-תעשייתי או שמקורם בתחום אחר (741denicola, supra, at) פיתוחו של תחום המדגמים נבע, בין היתר, מאי-התאמתם של דיני זכויות יוצרים להגנה על צורות של מוצרים פונקציונליים בכלל ומוצרים פונקציונליים-תעשייתיים בפרט. התחושה היא כי הגנה המותנית במקוריות ולא בחדשנות והגנה שהיא לתקופת זמן ארוכה אוד אינן תואמות תחום מסחרי-דינמי. הן אינן יוצרות את האזיון הראוי כדי לקיים עידוד השקעה בצורה המונעת פגיעה בתחרות חופשית. הצעות החוק לעניין הגנת הצורה במוצר הפונקציונלי-תעשייתי בשוק האירופי שהוגשו לאחרונה משקפות מסקנה זו: הדרישה לשם קבלת הגנה בתחום ה-industrial design מתמקדת בהשפעת הצורה הסופית על החושים, ודוחה את ההתחשבות במאמץ האינטלקטואלי שהושקע ביצירתה כקריטריון למתן הגנה. Eur. Intell 12" the future of A. Prop. Rev(1991)442 europe:industrial design law", horton. זאת, בעבר, בהיעדר הגנת מדגם או הסדר אחר המתאים לתחום זה, הייתה זו הדרך היחידה להגן על צורתם של מוצרים פונקציונליים-

תעשייתיים (ראה: בארצות-הברית-Ff88; 2,nimmer, supra at ; d.i. bainbridge, intellectual property; Ff (1992,london)309 tootal at 1101). וכתוצאה מכך הביאה להרחבה ניכרת בהגנה שניתנה על-ידי זכות יוצרים הן באנגליה והן בארצות-הברית. יצירתה של זכות המדגם פתרה חלק מבעיה זו, ולאור החפיפה האפשרית, קובע [סעיף 22](#) לחוק הישראלי (והסעיף המקביל בחוק האנגלי) כי יש לשלול את הגנת זכות היוצרים, במקרים שבהם המוצר הספציפי זכאי להגנת שני הדינים. זאת לאור הגישה כי כאשר מדובר בהגנה על מוצר פונקציונלי-

תעשיית, הגנת המדגם מבטאת את האיזון הראוי. מסקנה זו נובעת גם מהסעד הקיצוני שאותו מעניק [חוק זכות יוצרים](#) ליוצר שזכות היוצרים שלו הופרה: קבלת פיצויים מלאים על כל מוצר מפר, או קבלת המוצרים עצמם ([סעיף 7 לחוק](#)), ולא רק פיצויים בגין הנזק שנגרם כתוצאה מההעתקה. סעד זה תואם מוצרים אשר ערכם הבלעדי או העיקרי נובע מצורתם, ולא מוצרים אשר צורתם מהווה גורם משני ולעתים (אף כי לא תמיד) שולי בקביעת מחירם [41], at b.l.m.c. v.(1986). b.l.m.c. v.(1986) 617 623, Armsrong patents ltd עם זאת, מכיוון שהדינים מונעים על-ידי מניעים שונים ונוקטים מבחנים שונים, אין

--- סוף עמוד 188 ---

חפיפה מלאה בין השניים גם לא בתחום העיקרי שלו נועדה הגנת המדגם, הוא תחום היצירות הפונקציונליות. עדיין תיתכן יצירה אשר אינה ממלאת אחר דרישת משיכת העין וממלאת אחר הדרישות של יצירה, מקוריות ואמנותיות. [סעיף 22](#) אינו מונע את כל הכפילויות האפשריות (at 635 [41] b.l.m.c.) ובמקרה של כפילות אין לשלול מהיצירה את הגנת זכות היוצרים.

הדיון בערעור זה מבהיר מדוע יש חשיבות גם להגנה של זכות יוצרים בתחום של מוצרים פונקציונליים: מדגמים מגינים על חדשנות בתוצר הסופי בעוד שזכות יוצרים מגינה על מקוריות בשלב גיבוש הצורה. ניתן להניח שההוראות לשימוש במסור, שזכו להגנה בפסק הדין שהוזכר לעיל, לא היו זכות להגנה במסגרת דיני מדגם. יתרה מכך, דיני מדגמים, כמו פטנטים, אינם מעודדים גיוון לשמו אלא חדשנות - שהיא פרי קבלת הצורה בקהל יותר משהיא פרי המקוריות היצירתית של היוצר. מדובר בסוג אחר של שיקולים גם אם שני הסוגים באים לידי ביטוי, בסופו של דבר, בצורתו של המוצר. עמדנו בפירוט רב על החשיבות שבעידוד הגיוון בצורות המוצרים, גם הפונקציונליים, מטרה אשר לא תושג אם ההגנה על צורות תוגבל להגנה שמעניקים דיני המדגמים בלבד (ראה בעניין זה, r. S. Brown, 1341(87-1986). "an overview: design protection". Ucla l. Rev 34).

ייתכן כי האיזון הראוי מצוי לא בהגבלת השיקולים למתן הגנה, אלא בהגבלת היקף ההגנה וצורתה, במקרים שבהם מדובר על שיקולים אמנותיים בתחום המוצרים התעשייתיים. החוק האנגלי הולך בדרך זו כאשר הוא קובע (בסעיף 52 לחוק משנת 1988) כי כאשר נעשה שימוש תעשייתי ביצירה שיש בה זכות יוצרים בגין אספקטים ויזואליים שלה, תוגבל תקופת ההגנה ל-25 שנים.

יישום המבחנים על קוביות הדופלו

17. האם קוביות הדופלו עומדות בתנאים הנדרשים לצורך קבלת זכות יוצרים? אין ספק שהקוביות ממלאות אחר דרישת היצירה והמקוריות, כמובן של דרישות אלו בחוק זכויות יוצרים. נותרת שאלת האמנותיות.

באשר לכוונת היוצר, הרי שדומה שבצורת הקוביות קיימים שיקולים אסתטיים, שאינם מוכתבים רק מהמטרה הפונקציונלית. לאור מסקנתי באשר לחלק השני של המבחן איני רואה מקום לקבוע קביעה נחרצת בעניין זה, אך יש להעיר שככלל מוצר המעוצב במטרה להיות כלי משחק, מעוצב בדרך כלל מתוך שיקולים שאינם רק פונקציונליים אלא גם אסתטיים (ראה סקירת העובדות בפסק הדין שניתן בעניין אותן קוביות בהונג-קונג, וכן ההתייחסות לכך בערעור במועצת המלך

industries inc. And others- a.g. (1987) [53]interlego;442- 433, at Interlego a.g.[34]357, at v. Tyco הרעיון שבא לידי ביטוי בקוביות הוא של קוביות המתחברות ליצירת בניינים ומבנים דומים, אין רעיון זה מכתוב במידה רבה את הצורה של הקוביות, היינו, האם אין מדובר בצורה המוכתבת על-ידי התפקיד הפונקציונלי. כך,

--- סוף עמוד 189 ---

למשל, קשה להתאים לרעיון זה קוביות בעלות צור משולשת או עגולה אף שטכנית הדבר אפשרי. דומה שהאספקט של הצורה המרובעת או המלבנית אינו זכאי להגנה מטעם זה.

אך דינו של ערעור זה נחתך בעיקר על סמך הדרישה המתמקדת בתוצאה הסופית ולא בשיקולים שבשלב גיבוש הצורה. יש במתן זכות יוצרים משום הטלת הגבלה קשה מדי על התחרות אם תינתן למערערים זכות יוצרים על האספקטים הוויזואליים של קוביות הדופלו. נראה שמתן זכות יוצרים זו יעניק להם מונופול או כמעט מונופול בתחום של קוביות פלסטיות המתחברות זו לזו, כאשר המדובר באבני בניין בסיסיות ביותר. ברוח הגישה שהוצגה לעיל אין לאפשר זאת, אף שהדבר מאפשר העתקת הצורה ולא רק הרעיון על-ידי מתחרים. כך הדבר באשר לצורתם המלבנית או המרובעת של הקוביות, שהרי גם אם קוביות משולשות יכולות לשמש את המטרה של קוביות המתחברות זו לזו, אין זה תואם את הפונקציה של בניית מבנים, כפי שהיא נתפסת על-ידינו. אותם דברים אמורים לגבי שאר האלמנטים הוויזואליים הבאים לידי ביטוי בקוביות. המרכיב הבעייתי ביותר בהקשר זה הוא מרכיב הפרופורציה. המשיבים העתיקו במדויק את הפרופורציות של קוביות הדופלו, ושאלה היא אם אין לראות מרכיב זה לפחות כזכאי לזכות יוצרים. כאן באה לידי ביטוי הטענה שכאשר מדובר באבני בניין פשוטות אין לתת בהן זכות יוצרים. מתן זכות יוצרים על פרופורציה פשוטה של מלבן או ריבוע נראית בעייתית ולא מוצדקת לאור ההגבלה על האינטרס הציבורי. יתרה מכך, משום שמדובר באבן בניין כה בסיסית, אין להניח שמתן זכות יוצרים יש בו כדי לקדם את הגיון וההפצה של ביטויים מקוריים.

אין הדבר אמור בשל היות הביטוי פשוט אלא בשל היות הפרופורציה במקרה זה אבן בניין יסודית. האינטרס הציבורי מחייב שלא תינתן זכות יוצרים בפרופורציה של קוביות הדופלו.

התוצאה היא כי אין המערערת זכאית להגנת זכות יוצרים מכוח היות היצירה "מעשה אמנות", ועל-כן, בהיעדר קטגוריות רלוואנטיות אחרות, אין היא זכאית להגנת זכות יוצרים על קוביות הדופלו כ"יצירה אמנותית".

זכות יוצרים בשרטוטים

18. המערערת טוענת שהמשיבה הפרה את זכות היוצרים שלה בשרטוטים של קוביות הדופלו. הקונסטרוקציה המשפטית שלה טוענת המערערת היא זו: (א) על-פי [סעיף 35\(1\) לחוק זכות יוצרים](#) זכאים שרטוטים להגנת זכות יוצרים כיצירה אמנותית, ובמונח שרטוטים יש לכלול גם שרטוטים טכניים.

(ב) העתקת יצירה שלא בהסכמה מהווה הפרת זכות יוצרים בה.

(ג) העתקת היצירה התלת-ממדית (קובי הדופלו) מהווה העתקה עקיפה של היצירה הדו-ממדית (השרטוטים) אשר שימשה בסיס ליחידה התלת-ממדית.

התיזה שעל פיה "העתקה עקיפה" כזו היא משום הפרת זכות יוצרים מוצאת תימוכין בלשון החוק, שעל פיו אסורה העתקה "in any substantial" ובמינוח העברי "בצורה של ממש". המערערת מביאה לחיזוק טענתה גם פסיקה אנגלית שלפיה בהעתקת המוצר התלת-ממדי יש משום הפרה של זכות היוצרים, אף אם היוצר כלל לא ראה את השרטוטים [41] B.l.m.c. [37] (plastics). L.b ולאחרונה: [42] (1992) h engineering v. F. Klucznik & son. Ltd & Court of justice high. לעומתה טוענת המשיבה כי הכללים בדבר הגנת המוצר הפונקציונלי במישור התלת-ממדי חלים גם בשרטוטי אותן יצירות, ואין לאפשר הגנה למוצרים פונקציונליים ב"דלת האחורית" דרך שרטוטים. באשר לפסיקה האנגלית, הרי שלטענתה פסיקה זו מתבססת על החוק האנגלי משנת 1956 ועל סעיף 9(8) שבו, שהוראותיו שונות מהחוק משנת 1911, שהוא החוק שעליו מבוסס החוק הישראלי. בית המשפט המחוזי אימץ במידה רבה את הנדבך הראשון לטענת המשיבה, תוך שהוא קובע שאין לאפשר הגנה עקיפה על מדגם בדרך של מתן זכות יוצרים על השרטוטים שלו.

צודקת המערערת בטענתה שהגנה על יצירה באמצעות זכות יוצרים פרושה גם על מצבים שבהם ההעתקה מתבצעת במדיום אחר מזה שבו מצויה היצירה המקורית (ע"א 23/81 הרשקו ואח' נ' אורבך ואח' [9], בעמ' 780). הדבר אמור הן לגבי שינוי האופן שבו היצירה מוצגת: סרט במקום ציור, ציור במקום שרטוט; הן לגבי שינוי חומרי הבנייה או הממדים; והן לגבי העברה מיצירה דו-ממדית לתלת-ממדית או להפך. העתקת "פופאי המלח" לדמות תלת-ממדית היא הפרה של הדמות הדו-ממדית שלו [43] (1941) M. Kleeman, Id & .king features syndicate. inc. V. O. באותה מידה תיחשב העברה של יצירה תלת-ממדית לדו-ממדית (כגון ציור של פסל) כהפרה. בנוסף לכך צודקת המערערת שחוק זכות יוצרים מגן גם נגד "העתקה עקיפה", קרי: העתקה המתבצעת מהעתק של המקור המוגן. הלכה זו, הבאה לידי ביטוי בפסק הדין בעניין [41] b. L. M. C., אף זכתה לעיגון מפורש בסעיף 16(3) לחוק האנגלי משנת 1988. במקרה שלפנינו טוענים המערערים ל"העתקה עקיפה" המתבצעת במדיום שונה, וגם העתקה כזו תיחשב הפרה לפי חוק זכות יוצרים.

הסוגיה שלפנינו נוגעת ל- reverse engineering הנעשה למוצר הסופי, כאשר מדובר במוצר פונקציונלי. הטענה היא כי על-ידי העתקת המוצר הסופי מופרת זכות היוצרים בשרטוטים הטכניים שהובילו ליצירתו. ההעברה אינה רק של מדיום, ובאמצעות העתקה עקיפה, אלא נדרש גם תהליך של "תרגום" השרטוט והכלול בו ליצירה תלת-ממדית, ולא די ב"נפיחת אוויר" לתוך הדמות הדו-ממדית של פופאי.

המערערת טוענת כי היא זכאית לזכות יוצרים בשרטוטים הן כיצירה אמנותית והן כיצירה ספרותית. זכות יוצרים לשרטוטים תיתכן בשתי הקטגוריות הללו, שכן בהגדרת יצירה אמנותית נכללת הקטגוריה של "שרטוט" ובהגדרת יצירה ספרותית קיימת הן

קטגוריה של "תרשימים" והן של "תכניות". עם זאת, ההגנה בכל סוג של יצירה מתייחסת למרכיבים שונים שלה. זכות יוצרים ביצירה אמנותית מגינה על האלמנט הוויזואלי של היצירה. לעומת זאת, זכות יוצרים ביצירה ספרותית מגינה על התוכן שבה: על האינפורמציה, על ההוראות או על ההנאה (זו ההגדרה המצמצמת שאומצה בפסק הדין *at* [44]427 (1894) *hollinrake v. Truswell*) המופקות מהתוכן ולא מהצורה. יוצא, שכדי להצליח בתביעה לזכות יוצרים המתבססת על היותם של השרטוטים "יצירה אמנותית", על המערערת להוכיח שקיימת זכות יוצרים באלמנט ויזואלי הקיים בשרטוטים המקוריים ושזו הופרה על-ידי עתקת המוצר המוגמר. לעומת זאת, כדי להצליח בתביעה המתבססת על היותם של השרטוטים "יצירה ספרותית", יש להראות שהופרה הזכות באלמנט ספרותי הקיים בשרטוטים ואשר הועתק.

לגישתנו, כאשר מדובר בזכות יוצרים ביצירה אמנותית, הרי שאם המוצר עצמו אינו זכאי להגנה של זכות יוצרים (וממילא לא תיתכן הפרה בהעתקתו), לא ניתן על-ידי העתקתו (להבדיל מהעתקת שלבי ביניים שלו) להפר זכות יוצרים בשלב הכנה כלשהו של המוצר ובכלל זה בשרטוטיו. זאת משום שאם העתקת המוצר עצמו אינה מהווה הפרה, סימן הוא שאין בו אלמנט הזכאי להגנת זכות יוצרים. במקרה כזה, גם אם יש בשרטוטים אלמנטים הזכאים להגנת זכות יוצרים, הרי שהם נוגעים כנראה לשרטוטים עצמם ולא למוצר המתבסס עליהם. במילים אחרות, אם השרטוט מציג צורה מקורית של המוצר עצמו, הרי שזה ישתקף במוצר, ועל-כן יהא היוצר זכאי לזכות יוצרים במוצר ולא רק בשרטוטים. אם אין המוצר עצמו בעל צורה הזכאית להגנה, סימן הוא שהועתקו מהשרטוט למוצר רק אלמנטים שאינם זכאים להגנה (ראה על כך *2nimmer, supra, at* 207, 2-22 (העמודים האחרונים בהקשר הספציפי של צעצועים)). במקרה כזה לא ניתן להעתיק את אותם אלמנטים בהעתקה עקיפה מהמוצר, כן אלו כלל אינם קיימים בו. תוצאה זו גם נתמכת בשיקולים של מדיניות, שכן היא אינה מאפשרת מצב שבו ניתן לעקוף את חוסר היכולת לקבלת זכות יוצרים במוצר על-ידי קבלת זכות יוצרים בשרטוטיו. במקרה של מוצר פונקציונלי "טהור" עשויה הלכה כזו להביא למצב האבסורדי שמוצר אשר אינו זכאי להגנה מכוח זכות יוצרים, ואף לא להגנה מכוח דיני המדגמים, יזכה להגנה לטווח זמן ארוך הרבה יותר מכוח שרטוטיו, אם כי המטרה המפורשת הן של דיני זכויות יוצרים והן של דיני המדגמים היא שלא לאפשר הגנה על האספקטים הצורניים של מוצרים אלו (ראה דעת המיעוט בפסק הדין *B. L. M. C. [41]* הנ"ל, בעמ' 647). הלכה זו גם מבקשת למנוע מצב שבו הזכות לקבלת זכות יוצרים מותנית בקיומם או בהיעדרם של שרטוטים. רעיון זה בא לידי ביטוי בסעיף 51(1) לחוק האנגלי משנת 1988.

ההצדקה לאי-הכרה בזכות יוצרים בגין היותם של השרטוטים יצירה אמנותית מקבלת חיזוק לאור מטרתו של [חוק זכות יוצרים](#) לתת עידוד ליוצר היצירה המקורית. מתן הגנה של זכות יוצרים לשרטוט כיצירה אמנותית נועד לתמרץ את היצירות שבהבעה הוויזואלית של השרטוט ולמנוע את מי שעושה שימוש במקורות שביצירותיו. הוא לא נועד לאפשר הגנה למיע המצוי ביצירה שאינו פרי יצירתיותו הוויזואלית של השרטוט. על-כן, אם האספקט הוויזואלי אינו בא לידי ביטוי במוצר הסופי, הרי שמתן הגנה לצורה כפי

שהיא באה לידי ביטוי במוצר הסופי אינו מגן על ההשקעה של השרטוט אלא על השקעת המהנדס, והשרטוט רק משתמש בכישוריו כדי להעביר הלאה את האינפורמציה שמקורה לא בו (בשרטוט) 8skone james, Interlego a.g;68- [34]365, at (supra, at& copinger).

ההפרדה בין האספקט הספרותי לאמנותי של השרטוט מבהירה שכאשר מדובר במוצר שצורתו מוכתבת אך ורק על-ידי שיקולים פונקציונליים, למעשה אין בשרטוט כל אספקט "אמנותי", כמובנו של ביטוי זה בחוק זכות יוצרים, וכל מטרתו של השרטוט היא העברת מידע בלבד. עם זאת, כאשר בוחנים את ערכו ה"אמנותי" של השרטוט כמבטא ביטוי ויזואלי הזכאי להגנה, הרי שכמו בעניין המוצר עצמו אין ליצור הבחנה חדה בין האלמנטים הפונקציונליים לוויזואליים שבשרטוט & skone james, ibid (copinger) אינה מתעוררת בענייננו, לנוכח הקביעה כי אין במוצר הסופי אספקט "אמנותי" הראוי להגנה.

הצגה זו של הדברים מייתרת את הצורך להתייחס לשינוי שחל בחוק האנגלי בשנת 1956. גם לפי החוק משנת 1956 משמש אותו סעיף 9(8) - ששינה את החוק לעניין היחס בין היצירה הדו-ממדית וההעתקה התלת-ממדית שלה - כהגנה בלבד, ואין לו תחולה מקום שלא הוכחה הפרה של זכות יוצרים, לא כל שכן כשנקבע שאין בכלל יצירה מוגנת. למען השלמת התמונה יש לציין שהסעיף הנדון נמחק בחוק האנגלי החדש משנת 1988.

19. מכאן לטענת המערער כי יש לראות בהעתקת צורת המוצר משום העתקה עקיפה של זכות היוצרים בשרטוטים כיצירה ספרותית. כאמור, מטרתה היא לקבל זכות יוצרים על המידע המביע את הצורה המצויה בשרטוטים אלה, בטענה שהמוצר הסופי וצורתו הם גלגול של אותו מידע ושבהעתקתו הופרו זכויותיהם באותו מידע. קיימים מספר קשיים ביישום דוקטרינת "ההפרה במימד אחר" על יצירות ספרותיות. ראשית, יש להשגיח שההגנה על תוכן היצירה הספרותית מפני מימוש במדיום אחר אינה חלה על הרעיון שעומד מאחוריהם (catnic components ltd. V. Hill & [45](1982). ltd.) , שנית, במקרה של שרטוטים טכניים, הרישומימושם בפועל כרוך במקרים רבים במקוריות שאינה מתבטאת בהעתקה גרידא. נדרש "תרגום" כלשהו שספק אם הוא נעדר מקוריות (interlego, a.g;[53] 471, at). שלישית, מתעורר ספק אם יש בכך משום העתקה, כאשר מדובר בממד אחר (12- copinger supra, at 8).

שלל נימוקים אלו הולוכו לגישה המקובלת באנגליה, ולפיה אין בהעתקת יצירה ספרותית למדיום אחר משום הפרת זכות יוצרים. גישה זו מעוגנת בחוק האנגלי משנת 1956 (סעיף 48(1)) ומוצאת ביטוי גם בחוק משנת 1988 (סעיף 17(2)). סעיפים אלו מציינים כי לעניין יצירה אמנותית תיחשב כהפרה גם העתקה הכרוכה במעבר מיצירה דו-ממדית לתלת-ממדית, או להפך. מכאן הסיקו בתי המשפט והמלומדים הסדר שלילי לגבי יצירות אחרות ובפרט יצירות ספרותיות (copinger 8skone james, supra, 101bainbridge, supra, at;12- brigid foley; ltd. V. Elliott (1982) [46] . Interlego, a.g;[34]373, at at& משנת 1911 והחוק הישראלי אינם מכילים הגבלה כזו.

החוק האמריקני אינו שולל את האפשרות שההפרה של זכות יוצרים תתבצע בממד

אחר ומסוג אחר. סעיף 106(2) לחוק האמריקני מקנה ליוצר את הזכות הבלעדית לייצור מוצרים נגזרים (derivative), ואלו מוגדרים בצורה רחבה ביותר.

דומה שתיאור מילולי של ביטוי זכאי להגנה בזכות יוצרים, ומימוש על-ידי הנתבע יהווה הפרה (nimmer, supra at; 571, at. 1goldstien, supra, vol) (196-2), בתנאי שהוא עומד בהגבלת סעיף 102(B) לחוק, הקובע כי In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation. Concept, principal, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work הידועה שזכות היוצרים מגינה על הביטוי ולא על הרעיון. אך הוא אינו שולל את ההגנה על ביטוי גם אם מדובר על מעבר ממדיום אחד לשני, ואין כל שוני לעניין זה בין סוגים שונים של יצירות, ובלבד שההגנה היא על הביטוי ולא על מה שעומד מאחוריו.

עם זאת, אותה הבחנה קשה בין מוצרים בני-שימוש (useful) למוצרים שאינם כאלה, החלה במקרה של המוצרים עצמם, שולטת גם בנושא זה. דו"ח רשם זכויות היוצרים האמריקני משנת 1961, קובע כי: Copyright in a pictorial, graphic or sculptural work, portraying a "Useful article as such, article itself does not extend to the manufacture of the useful" (וסעיף 113)ג) לחוק האמריקני מקבל הלכה זו. מכאן כי אף שהחוק האמריקני נכון להכיר בהעברה ממדיית ככלל, הרי שבתחום של מוצרים תועלתניים א תועיל זכות יוצרים בשרטוט, יהא אשר יהא אופיו. לענייננו יש לזכור שאין חפיפה בין מוצרים תועלתניים ומוצרים פונקציונליים (2nimmer, supra, at-209), ומכל מקום, צעצועים וכלי משחק אינם בגדר מוצר תועלתני (2ibid, at-210), ועל-כן ההלכה הכללית, שלפיה העברה ממדיית אסורה, עומדת בעינה, וייצורו של צעצוע בצורה תלת-ממדית יהווה הפרה של זכות היוצרים בשרטוטיו.

בישראל טרם נדונה סוגיה זו באופן ממצה. החוק הישראלי אינו מחיל את הסעיפים הקיימים בחוק האנגלי שמהם הסיקו הסדר שלילי לעניין זה, ועל-כן דומה שהעניין פתוח. עליי להעיר, כי שלא כטענת המערערת, אין לראות בע"א 23/81 [9] הנ"ל אסמכתא לכך שהעתקה של יצירה ספרותית לביטוי תלת-ממדי תהווה הפרה. זאת הן לאור העובדה שהדברים שם מסתמכים על פסק הדין king features, Inc[43]syndicate. הנ"ל שבו מדובר בהעתקת יצירה אמנותית, והן לאור התוצאה הסופית שאליה הגיע בית המשפט באותו מקרה. גם לצרכיו של ערעור זה אין צורך להכריע בשאלה הכללית באופן חד-משמעי. יש לזכור שעניין לנו בתחום מצומצם יחסית. ראשית, המדובר רק בנסיבות

--- סוף עמוד 194 ---

שבהן תוכן המידע, שבו מתבקשת זכות יוצרים, עוסק בצורתו של המוצר. כלומר, התוכן הספרותי המוגן מתורגם לצורה הוויזואלית. שנית, המדובר בסוג ספציפי של יצירות: יצירות פונקציונליות, ובסוג ספציפי של העתקה: העתקה לא ישירה. כאשר הצורה מוכתבת באופן בלעדי בידי הפונקציה של המוצר, אין כל מקום לראות בהעתקת המוצר הסופי משום הפרה של זכות יוצרים בשרטוטים, שכן

המידע "המועתק" אינו פרי מאמציו של השרטוט אלא של המהנדס - ומתן הגנה במקרה שכזה אין בה כדי להגן על ביטוי מקורי הבא לידי מימוש בשרטוט (654, b. L. M. C[41]at). עיון בשיקולים שנסקרו לעיל מראה כי גם כאשר מדובר במוצר פונקציונלי אשר צורתו היא תוצר של שיקולים מעורבים, פונקציונליים ואמנותיים, אין לראות בהעתקה של צורת המוצר משום העתקה עקיפה של שרטוטיו. דרך זו מאפשרת ליצרן להתחמק מעמידה בדרישת האמנותיות החלה על המוצר עצמו, שכן זו אינה קיימת ביצירה ספרותית. כך יושם לאל האיוון העדין שבונה החוק כאשר מדובר במוצרים פונקציונליים. החשש שהיוצר יזכה לזכות יוצרים לגבי רעיון, והחשש לקבלת מונופול או כמעט מונופול על צורה או לצמצום מספר האפשרויות למימוש פונקציונלי בצורה שיש בו כדי לפגוע בשימוש ברעיון, עולים בסיטואציה זו ביתר שאת. עם זאת, אין מקום לשלול לחלוטין את האפשרות שתהא סיטואציה שבה תהיה הצדקה להגן על זכות היוצרים בצורה שהיא גלגול של תיאור ספרותי, וכאמור, העניין אינו דורש הכרעה במקרה זה. על-כן, כאשר מדובר במוצרים פונקציונליים יש לקבוע כי לא תיתכן הפרה של זכות יוצרים בדרך עקיפה על-ידי העתקת השרטוטים, ללא שהופרה זכות היוצרים במוצר עצמו. דין אחד יהיה לשני סוגי היצירות (ספרותית ואמנותית), ותוצאה זו גם מונעת מצב שבו קיומה או היעדרה של הגנה ייקבעו לפי הצורה שבה הועברו הוראות הייצור: בכתב או על-ידי ציור. אין הצדקה לכך שהיקף ההגנה יהיה תלוי בקיומם של שרטוטים, או בסיווגם בדרך זו או אחרת (648, at b. L. M. C[41]).

כאמור, סעיף 51(1) לחוק האנגלי משנת 1988 פתר את הבעיה שלפנינו בכך שקבע שהעתקת מוצר המתבסס על שרטוטים או על דגמים אינה מהווה הפרת זכות יוצרים באותם שרטוטים או דגמים, כל זמן שאין אלו בעצמם בבחינת יצירות אמנותיות.

המסקנה היא שהמשיבה, בהעתיקה את קוביות הדופלו בדרך של engineering reverse, לא הפרה את זכות היוצרים בשרטוטי הקוביות. לאור מסקנה זו לא נדרשתי כלל לשאלה אם היו שרטוטים אלו זכאים לזכות יוצרים, בין כיצירה אמנותית ובין כיצירה ספרותית.

הערעור שכנגד

20. המשיבה ערערה על כך שבית המשפט המחוזי לא פסק לטובתה הוצאות. יש להזכיר שבבית המשפט המחוזי עמדו לדיון גם "בובות דופלו", ובנושא זה קבע בית המשפט שהדין עם התובעת (המערערת בענייננו). לטענת המשיבה, עיקר עיסוקן של בית המשפט המחוזי היה בסוגיית הקוביות, וההליך ארך זמן רב בשל טענות סרק של התובעת (המערערת לפנינו), ועל-כן היה צריך לפסוק לטובתה הוצאות.

--- סוף עמוד 195 ---

איני רואה מקום להתערב במסקנתו של השופט המלומד, הנוגעת להליכים בבית המשפט המחוזי.

התוצאה היא שהערעור והערעור שכנגד נדחים. תוצאות פסק הדין המחוזי עומדות בעינן.

לאור התוצאות האמורות, תישא המערערת בהוצאות המשיבה בסכום של 40,000

ש"ח; והמשיבה תישא בהוצאות המערערת בסכום של 10,000 ש"ח.

השופט ד' לוין: למקרא כתבי הטענות ופסק הדין של הדרגה הראשונה, גם אני סברתי כי ניתן היה לדחות את תביעת המעררים מהטעמים שפירטה חברתי, השופטת דורנר, בחוות-דעתה.

אולם משהועלו לפני בית המשפט הסוגיות המשפטיות ברוחב יריעה ובטיעון מלומד ומעמיק, תוך התייחסות לדין הישראלי ולמשפט ההשוואתי, התבקשה לדעתי ההתייחסות המקיפה לסוגיות כפי שנדונו בפסק-דינו של הנשיא.

מסכים אני כי יש לדחות ת הערעור. בראש ובראשונה מהטעמים שעמד עליהם הנשיא, אך גם מהטעם הנוסף שעמדה עליו השופטת דורנר.

השופטת ד' דורנר: 1. אני מסכימה לפסק-דינו של חברי, הנשיא שמגר.

עם זאת, אני סבורה כי בנסיבות המקרה שלפנינו אפשר לדחות את התביעה אף בלי לדון בטענות המערערת לגופן, שכן היא הייתה מושתקת מלטעון אותן.

2. חברי הנשיא הראה, כי מוצר עשוי לעמוד בתנאים המקנים הגנה הן לפי דיני זכויות היוצרים והן לפי דיני המדגמים. ואולם, במקרה כזה הוא יהיה זכאי להגנה על-פי דיני המדגמים בלבד, שכן, כאמור, [בסעיף 22 לחוק זכות יוצרים](#) נקבע כי אין להעניק זכות יוצרים למוצר הכשיר להגנה על-פי דיני המדגמים. ההסדר הוא אפוא דיכוטומי, ורק מוצר שאינו יכול להירשם כמדגם יוכל, בהתקיים התנאים הנדרשים, לזכות להגנת זכות יוצרים.

הגנת זכות יוצרים מקיפה פחות מן ההגנה הניתנת על-פי דיני המדגמים, אך משך ההגנה הוא ארוך יותר. בעוד שעל-פי דיני המדגמים משכה של ההגנה הוא 15 שנים ([סעיף 33 לפקודת הפטנטים והמדגמים](#) (להלן - הפקודה)), הרי שהגנת זכות היוצרים כנגד העתקה עומדת בתוקפה עד תום 70 שנה לאחר מות היוצר ([סעיף 4\(5\) לפקודת זכות יוצרים](#)).

3. בראשית שנות השבעים הגישה מערערת בקשה לרישום מדגמים על קוביות דופלו באנגליה, וטענה כי עומדות הן בתנאים הדרושים, הוזהים לתנאים הקבועים בפקודה. רשם הפטנטים האנגלי קיבל את טענותיה, והיא השיגה הגנה על דרך רישום מדגם על הקוביות

--- סוף עמוד 196 ---

באנגליה. בכך היא גם מנעה רישום מדגם על קוביות אלה על-ידי אחר בישראל. בעניין זה, מזכה [סעיף 36 לפקודה](#) כל מעוניין לפנות לרשם הפטנטים בבקשה לבטל רישום של מדגם שפורסם בישראל לפני רישומו. [בסעיף 52\(ב\)](#) לפקודה - שהוסף לה בשנת 1952 בעקבות הצטרפותה של ישראל לאמנת פאריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי - נקבע כי לצורך הוראת [סעיף 36](#) הנ"ל רואים את תאריך רישום המדגם באחת המדינות החברות באמנה (שעמן נמנית אנגליה) כתאריך רישום המדגם בישראל. משתמה תקופת ההגנה על-פי דיני המדגמים, ביקשה המערערת, בתביעה שהגישה בישראל, לזכות בהגנה של זכות היוצרים, ולצורך כך טענה טענות הפוכות לטענות שטענה לפני רשם הפטנטים האנגלי, שכן, כאמור, [חוק זכות יוצרים](#) מונע הגנה כפולה. וכך נאמר בפסק-דינו של בית המשפט המחוזי:

"נראה איפוא כי התובעת מאמצת לה את הגירסה הנוחה לה באותה שעה. כאשר היתה מעוניינת שמדגמיה יירשמו אמרה מה שאמרה... ואילו עתה כשהיא רוצה להנות מזכות יוצרים נוח לה לטעון כי אין

same deed. It would be playing fast and loose with justice if the turn and win the new suit upon a diametrically opposit [49]: . Harrison v; גם construction of "court allowed that . Industrial(1977) [51] banque de moscou v. Kindersleg (1950) wells(1966[50]properties v. A.e.i. ltd; האנגלי משתיק בעל דין מלטעון טענה הפוכה מזו שטען בעבר והביאה לו טובת הנאה. וכך מסוכמת ההלכה בספרם של bower and a. K. Turner, the law relating to estoppel by representation g. Spencer 360 1977,rd ed) ... The elector has accepted a benefit which could be : (3,london Not be allowed to reverse his choice and to his only because" follow the second course he has followed one course rather than Followed the first course. The the other. In such a case he will principle which brings about this result available, while he retains the benefit which could be his only if he . Is sometimes stated as declaring that a man may not simultaneously"approbate במשפט האמריקני 6. and reprobate, or may not 'blow hot and cold מכונה עיקרון זה בשם, "judicial estoppel", והוא חל במרבית

--- סוף עמוד 198 ---

מדינות ארצות-הברית. ההשתק השיפוטי נבדל מהשתק מכוח מצג או מכוח הבטחה, שכן בהשתק שיפוטי מושתק בעל דין מלהעלות טענות הסותרות טענות שמהן הוא נהנה בהתדיינות עם בעל דין אחר, וזאת אף כאשר הצד המשתק לא הסתמך על הטענות הקודמות ולא שינה את מצבו לרעה.

עמד על כך השופט culverבפסק הדין של בית המשפט העליון של מדינת טקסס (long v. Knox(1956) [31] 295, at).

The doctrine of judicial estoppel is not strictly speaking estoppel at" all but arises from positive rules of procedure based Based on inconsistency in judicial proceedings on justice and because the elements sound public policy. It is to be distinguished from equitable estoppel Of reliance and injury Party invoking this essential to equitable estoppel need not be doctrine should have been a party to the former present ... It has likewise been held that it is not necessary that the "proceeding בדומה לאנגליה, גם בארצות-הברית מותנה ההשתק השיפוטי בכך שבעל הדין המושתק הצליח בטענתו הראשונה.

עמד על כך השופט romitiבפסק הדין של בית המשפט לערעורים של מדינת אילינוי בעניין [32]1118, at finley v. Kesling:(1982) ... A party can not play 'fase and loose' with the court ... Or blowing" position in a legal proceeding and succeeds in maintaining 'hot and cold'... During the course of litigation... When a party assumes "that position, he may not thereafter assume a contrary position ההשתק השיפוטי הוחלה בארצות-הברית גם על הליכים בפני גופים מינהליים ומעין-שיפויים. בפסק הדין בעניין department of transp

"לרבינו האי תבעוהו בחפץ פלוני, והשיב אינו שלך אלא של פלוני, אינו הודאה להוציא השני מידו... אבל הכא שיחה בעלמא היא, ולא היתה הודאה, שהרי יכול לומר: 'אינו שלך', ולא היה צריך לומר: 'אלא של פלוני'. והרבה דברים שיחה בעלמא הם ואינו מזיק כלום".

לסיכום, עמדת המשפט העברי היא כי בעל דין אינו רשאי להתכחש לטענות שטען בהליך קודם, שהיו דרושות להצלחתו באותו הליך.

8. אף בפסיקה בישראל יש דוגמאות להשתקת בעל דין מלטעון בהליך משפטי טענה

--- סוף עמוד 200 ---

סותרת לטענה שעל פיה זכה לסעד בהליך קודם, וזאת אף כאשר בעל הדין השני לא היה צד להליך הראשון, לא פעל על סמך הטענה שהתקבלה באותו הליך ולא שינה את מצבו לרעה. בהימנעותו של בעל הדין שכנגד מלהתנגד להעלאת הטענה אין כדי לשלול את ההשתק.

בע"א 594/80, 658[1] ציין הנשיא י' כהן (מעבר לדרוש להכרעה באותו עניין) - ולדעה זו הצטרף מ"מ הנשיא שמגר - כי צד שזכה בתביעה על סמך טענה מסוימת, מנוע מלטעון טענה סותרת לטענתו זו בהליך אחר. באותו מקרה זכה האיש בתביעתו לקצין התגמולים שקבע כי לקה במחלת לב עקב שירותו הצבאי, ואילו בתביעה נגד חברת הביטוח, שהושתתה על פוליסת מנהלים שפטרה את החברה משיפוי גין אי-כושר שנגרם עקב שירות צבאי, טען היפוכו של דבר.

חברת הביטוח לא הייתה צד להליך הקודם, ואף לא פעלה לאור הטענה המקורית ולא שינתה את מצבה לרעה, ולמרות זאת סבר הנשיא י' כהן כי התובע היה מנוע מלהעלות את הטענה הנוגדת. וכך אמר, בעמ' 551-552:

"בנוסף לכך ניתן לטעון, שהוראת סעיף 39 של חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, לפיה 'בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה', מחייבת, שלא יוכל צד לחוזה לטעון לצורכי קבלת תגמולים על-פי חוק 95 הנכס... שמחלתו נגרמה עקב השירות הצבאי, ואחרי שזכה על-פי טענה זו - לטעון את ההפך בדיון בתביעה על-פי חוזה עם חברת הביטוח".

ראו גם: ע"א 132/86 ג'ורי נ' מדינת ישראל ואח' [10], בעמ' 561; ת"א (י-ם) 673/90 [17]. בע"א 1393/92 [2] מנע בית-משפט זה - מטעמים של תקנת הציבור - העלאת טענות סותרות, אף שבעל הדין היריב הסכים לכך.

באותו מקרה קוימה צוואה על-פי הסכם בין היורשות, אך בהסכם נקבע כי אחת היורשות תהא זכאית להשיג בתביעה אזרחית על כשרות המצווה. הנשיא שמגר, שמפיו ניתן פסק הדין, קבע, בעמ' 358:

"דינו של הערעור להידחות, וזאת כל טעמים של תקנת הציבור השוללים טיעון סותר, מבחינת ימין מקרבת ושמאל דוחה, לפיו היה המצווה לצורך הליך משפטי אחד כשיר לצוות, ולצורך הליך אחר באותו עניין ממש - בלתי כשיר...".

"תקנת הציבור סולדת מן המניפולציה בהליכי משפט, בדרך של הסכמה שקרית או השגה שקרית, לפי העניין, שהרי שתי הגירסאות שהועלו על-ידי המערערת אינן יכולות לדור בכפיפה אחת..."

--- סוף עמוד 201 ---

השוו גם לדברי השופט ד' לוין בע"א 151/85 י' רודן נ' א' רודן, קטין באמצעות אמו ואח' [11], בעמ' 193, כי-

"מנועה המשיבה 2 מלהעלות טענה זו (כנגד תוקפו של הסכם - ד' ד')... לאחר שהיא קיבלה את מה שההסכם העניק לה..."

העלאת טענה זו בשלב כה מאוחר הינה שימוש בזכות שלא בתום-לב, דבר העומד בסתירה לסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

וראו תקנה 72 לתקנות סדר הדין האזרחי, האוסרת העלאת טענות עובדתיות

חלופיות בכתבי הטענות.

ד' פרידמן ו-נ' כהן, בספרם חוזים (אבירם, כרך א, תשנ"א) 95, 96, רואים בפסיקה זו הרחבה של דיני ההשתק ותום הלב.

9. לדעתי, ההשתק מלטעון טענה סותרת לטענה שמכוחה זכה הטוען לסעד בהליך קודם חל במשפטנו מכוח חובת תום הלב הקבועה בסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. חובה זו הורחבה בסעיף 61(ב) לחוק זה אל כלל החיובים, והפסיקה הוסיפה והרחיבה אותה וראתה בה עיקרון אוניברסלי, המתפרש על כל תחומי המשפט. בד"נ 7/81 פנידר, חברה להשקעות פתוח ובנין בע"מ ואח' נ' קסטרו [12], בעמ' 687, אמר הנשיא שמגר:

"אמת המידה, המוגדרת בסעיף 12, היא תולדה של עקרון-יסוד משפטי, החולש על כל תחומי המשפט... והיא חורגת מן התחומים של היחסים החוזיים".

וכן ראו דברי השופט אלון בבג"צ 566/81 עמרני נ' בית הדין הרבני הגדול ואח' [13], בעמ' 9-10:

"סעיף 39 האמור אמנם מטיל את החובה לנהוג בתום-לב לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה, אך לאור הוראות סעיף 61(ב) לחוק הנ"ל משמשות ההוראות שבסעיף 39 - 'ככל שהדבר מתאים לענין ובשינויים המחוייבים' - כעקרון התנהגות וכמדיניות משפטית מחייבים לעניין פעולות משפטיות וחיובים שבכלל המערכת המשפטית בישראל".

ראו גם: ע"א 700/81 מ' פז נ' א' פז [14], בעמ' 742; ע"א 2896/90 טרוצקי ואח' נ' דיין ואח' [15].

10. מחובת תום הלב נובע האיסור על שימוש לרעה בהליכי משפט. העלאת טענות סותרות היא פן אחד של איסור זה.

מטרתו של השתק זה היא כפולה: (א) במישור המשפט הציבורי, הוא נועד לשמור על טוהר ההליך המשפטי, ולמנוע מבעל דין לנצל לרעה את בתי המשפט ובכך לפגוע בהשלטת הצדק; (ב) במישור המשפט הפרטי, תכליתו היא למנוע תוצאות בלתי צודקות המתחייבות לכאורה על-פי הדין (בהנחה שהטענה המאוחרת היא הטענה הנכונה), וזאת על-ידי השתקת בעלי הדין מלטעון ומלהוכיח בבית המשפט טענות עובדתיות ומשפטיות גם אם הן נכונות. כאמור, השתק זה, שביסודו גם שיקולים במישור המשפט הציבורי, רחב מן ההשתק מכוח מצג או מכוח הבטחה, שלהקמתו נדרשים הסתמכות בעל הדין על הטענה המקורית שבעטייה ניתן הסעד, ושינוי מצבו לרעה עקב כך. ראו: פרידמן וכהן, בספרם הנ"ל, בעמ' 96, המשווים השתק זה לאיסור במשפט הקונטיננטלי על טענות סותרות, שנקבע על סמך חובת תום הלב; א' רביליו, פרקים בדיני חיובים (המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, תשל"ז) 146-147.

11. במקרה שלפנינו, טענת המערערת, כי היא זכאית לרישום קוביותיה כמדגם, נטענה ונתקבלה בהליך שנתקיים באנגליה, שעניינו רישום כמדגם באנגליה, ואילו בישראל לא נרשמו הקוביות כמדגם. מתעוררת אפוא השאלה אם עומדת למערערת הטענה, כי הואיל ובישראל לא בחרה היא ברישום כמדגם, פתוחה לפניה הדרך לטען לזכות יוצרים.

נראה לי, כי לנוכח המאטריה מושא התביעה - זכויות יוצרים לסוגיהן הזכיה במדינה אחרת בסעד על סמך טענה סותרת אינה שוללת את תחולת ההשתק השיפוטי. תכליתה של אמנת פאריס בדבר הגנת הקניין התעשייתי, שאליה הצטרפה ישראל, היא ליצור הרמוניה בין מערכות דיני זכויות היוצרים במדינות השונות. בעולמנו כיום, המכונה "כפר גלובלי", הרמוניה כזו היא הכרחית לשמירה אפקטיבית על זכויות הממציא והיוצר.

אינטרס ברור במערכת דינים עולמית הרמונית יש גם למדינות, בתור שכאלה, שכן אם מדינה אחת לא תכבד את זכויותיהם של יוצרים ממדינות אחרות, היא תהיה צפויה ליחס דומה בנוגע לזכויות של יוצריה. זאת ועוד: מדינה שלא תגן על זכויות יוצרים ממדינות אחרות, לא תזכה לקבל מידע ממדינות אלה.

ראו national research council global dimensions of intellectual property rights (1993, washington).

12. תכלית הוראות הפקודה (סעיף 52(ב)) יחד עם (סעיף 36), החוסמות את הדרך בפני רישום מדגם בישראל שנרשם קודם לכן באחת המדינות החברות באמנה, הייתה להביא להרמוניה בין הדין בישראל לבין הדינים במדינות אלה.

נמצא, כי בכך שההליך הקודם שבו הייתה העותרת מעורבת נגע לרישום מדגם באנגליה אין כדי למנוע את השתקתה מלטעון טענות סותרות באשר לרישום זכויותיה.

מסקנתי היא אפוא כי המערערת נתפסת בהשתק שיפוטי כאמור, ואף מטעם זה יש לדחות את ערעורה.

הוחלט כאמור בפסק-דינו של הנשיא.

ניתן היום, ל' בסיוון תשנ"ד (9.6.94).

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו -
הקש כאן

-

עא 513/89 S/interlego a נ' lines bros. S.a-exin, פ"ד מח(4)
133

www.nevo.co.il

-